

► Paulo Gustavo Guedes Fontes

O **MANUAL** DEFINITIVO
PARA ENTENDER A

FILOSOFIA DO DIREITO

DE ACORDO COM O
ANEXO VI, "D", DA
RESOLUÇÃO CNJ 75 DE
12/05/2009

2ª edição

O MANUAL DEFINITIVO PARA ENTENDER A
FILOSOFIA DO DIREITO

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

2ª EDIÇÃO

O manual definitivo para entender a Filosofia do Direito

De acordo com o Anexo VI, "D", da Resolução CNJ 75/2009

Paulo Gustavo Guedes Fontes

Copyright © 2020 Paulo Gustavo Guedes Fontes

All rights reserved

The characters and events portrayed in this book are fictitious. Any similarity to real persons, living or dead, is coincidental and not intended by the author.

No part of this book may be reproduced, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without express written permission of the publisher.

ISBN-13: 9781234567890

ISBN-10: 1477123456

Cover design by: Art Painter

Library of Congress Control Number: 2018675309

Printed in the United States of America

A meu amor Lena Raquel, por seu generoso e constante incentivo

Aos meus filhos Yuri e Natália, com amor, orgulhoso das pessoas que se tornaram.

Ao meu filho Luiz Paulo, de vida tão breve e sentida lembrança.

Ao querido amigo José Carlos Francisco, renovo meus agradecimentos por sua acolhida e precioso incentivo.

Contents

[Title Page](#)

[Title Page](#)

[Copyright](#)

[Dedication](#)

[Dedication](#)

[NOTA DO AUTOR À 2ª EDIÇÃO](#)

[PREFÁCIO](#)

[Direito, Moral e Justiça](#)

[1. O conceito de direito](#)

[1.1. O direito como meio de controle social](#)

[1.2. O carácter coercitivo do direito](#)

[1.3. As correntes jusfilosóficas e os critérios de identificação e validade do direito](#)

[1.4. O elemento moral](#)

[2. Direito e moral](#)

[2.1. Conceito de moral](#)

[2.2. Fundamentos da moral](#)

[2.3. Correntes da filosofia moral](#)

[2.4. Relações entre o direito e a moral](#)

[2.4.1. A questão da conexão conceitual](#)

[2.4.2. Conexão histórica ou contingencial](#)

[2.5. Distinções entre o direito e a moral](#)

[2.6. Teorias dos círculos](#)

[2.7. Direito, moral e liberdade individual](#)

[3. Direito e Justiça](#)

[3.1. Conceito de justiça \(sentido lato, estrito, divergências sobre o conteúdo do conceito\)](#)

[3.2. A justiça e sua relação com o direito](#)

[3.3. Justiça e aplicação do direito](#)

[3.4. A equidade](#)

[Correntes da Filosofia do Direito](#)

[1. O jusnaturalismo](#)

[1.1. Definição. Características gerais](#)

[1.2. Principais autores](#)

[1.3. Tese da conexão ou vinculação entre direito e moral](#)

[1.4. A questão das leis injustas e a fórmula de Radbruch](#)

[1.5. Fundamentos epistemológicos](#)

[2. O positivismo jurídico](#)

[2.1. Definição. Características gerais](#)

2.2. Evolução histórica

2.3. Principais autores

2.4. Principais teses do positivismo jurídico

2.4.1. A tese do fato social ou das fontes sociais do direito (social thesis)

2.4.2. A tese da separação entre direito e moral (separation thesis)

2.5. Outras questões relevantes

2.5.1. A questão da norma fundamental

2.5.2. O dever de obediência

2.5.3. A questão dos princípios

2.5.4. O argumento da democracia

2.6. Positivismo inclusivo, exclusivo e normativo

2.6.1. Positivismo inclusivo

2.6.2. Positivismo exclusivo

2.6.3. Positivismo ético ou normativo

2.7. Fundamentos epistemológicos

2.7.1. Postulados relativos ao conhecimento ético

2.7.2. Postulados relativos ao conhecimento do próprio direito. A questão da “neutralidade científica”

2.7.3. O enfoque descritivo do positivismo jurídico é possível? É suficiente?

3. O realismo e o pragmatismo jurídicos

3.1. Definição. Características gerais

3.2. Realismo jurídico como descrição do direito

3.3. Realismo como proposta normativa

3.4. Fundamentos filosóficos e epistemológicos

4. Neoconstitucionalismo – Dworkin – Alexy

4.1. O neoconstitucionalismo

4.2. Ronald Dworkin

4.3. Robert Alexy

4.4. Avaliação crítica do neoconstitucionalismo

A Interpretação do Direito

1. Interpretação e hermenêutica. Conceito e relação com a Filosofia do Direito

1.1. Conceito

1.2. A relação da interpretação com as correntes jusfilosóficas

2. Classificação e métodos de interpretação

2.1. Interpretação autêntica e doutrinal

2.2. Métodos de interpretação

2.3. Classificação quanto ao alcance da interpretação

3. A superação dos métodos de interpretação mediante puro raciocínio lógico-dedutivo

3.1. O método de interpretação pela lógica do razoável

3.2. Teorias modernas da argumentação jurídica

4. Teoria do ordenamento jurídico. Integração do direito

BIBLIOGRAFIA

About The Author

[Praise For Author](#)

[Books By This Author](#)

[Books By This Author](#)

NOTA DO AUTOR À 2ª EDIÇÃO

Estamos felizes em apresentar aos leitores uma nova edição do nosso livro, agora com o título *O Manual definitivo para entender a Filosofia do Direito*. O diferencial que cremos ver na obra é a tentativa de expor o tema de maneira objetiva e sistemática e ao mesmo tempo abrangente. Além dos autores clássicos, incluímos no estudo autores contemporâneos europeus e em particular do mundo anglo-saxão, onde a Filosofia do Direito tem encontrado grande desenvolvimento com nomes como Dworkin, Raz, Jeremy Waldron, Andrei Marmor, Leslie Green, etc.

Apesar de a obra não se dirigir apenas aos que se preparam para os concursos jurídicos, procuramos atender rigorosamente ao conteúdo estabelecido no Anexo VI, “D”, da Resolução CNJ 75/2009. Os temas previstos pela Resolução foram tratados nas Partes I e III do livro (*Parte I - Direito, moral e justiça e Parte III – A interpretação do Direito*). Como a resolução é sucinta, tais partes incluem mas não se resumem ao que ela previu, fornecendo um quadro mais amplo da Filosofia do Direito e mesmo de ramos correlatos, como a filosofia moral e política. São notícias e noções importantes presentes no texto ou em notas de rodapé que, além de solidificar a formação do leitor, vão auxiliar no desempenho nas provas subjetivas, sejam elas de Filosofia do Direito ou de matérias como Direito Constitucional e Direitos Humanos.

A Parte II da obra (*Correntes da Filosofia do Direito*) não está expressamente contida na Resolução, mas é útil a um maior aprofundamento. Elegemos aquelas que nos parecem as correntes mais relevantes da Filosofia do Direito – o Jusnaturalismo, o Positivismo, o Realismo e o Pragmatismo jurídico, além de acrescentar um capítulo referente ao Neoconstitucionalismo e aos autores hoje muito estudados Ronald Dworkin e Robert Alexy.

Cada parte do livro, ou mesmo seus capítulos, podem ser lidos de forma independente.

PREFÁCIO

A aplicação do Direito às situações concretas traz necessidade de sua compreensão, o que exige o conhecimento de seus grandes padrões, de seus vetores, de uma visão de conjunto consistente. Mesmo a simples e cotidiana subsunção de um fato a uma regra jurídica analítica depende da coerência extraída do sistema normativo, o que leva à inevitável utilização de modelos ou teorias de concepção do Direito e de Justiça, necessidade ainda maior em casos nos quais a solução de problemas somente pode ser construída a partir de preceitos que tenham elevado grau de abstração e baixa densidade normativa.

Esses grandes padrões que permitem a visão de conjunto dependem da Filosofia do Direito, porque é essa área do conhecimento jurídico que dá sentido de direção à utilização de todos preceitos trazidos pelo sistema jurídico, de tal modo que a solução de problemas concretos é obrigatoriamente vinculada padrões, correntes e teorias filosóficas. Acidentalmente ou episodicamente, qualquer pessoa pode intuir soluções adequadas e justas para problemas jurídicos, mas a solução profissional exige consistência e o emprego de referenciais jurídicos capazes de resolver não apenas um mas múltiplos casos, o que passa pelo uso de teorias viáveis e com raízes na Filosofia do Direito. Em suma, a resolução de uma questão concreta, da mais simples à mais complexa, de Direito Civil, de Direito Administrativo, de Direito Penal, de Direito Processual, de Direito Ambiental e de muitos outros âmbitos temáticos necessita de padrões teóricos sólidos da Filosofia do Direito, para que a atividade profissional não seja especulativa ou voluntarista.

Na atualidade, é um grande desafio pensar em Filosofia do Direito, pois nos vemos em um período marcado pela velocidade das mudanças, no qual o novo é substituído pelo mais novo, por ideias que se propõem a ser transitórias porque reconhecem suas iminentes superações, pelo ensino e pesquisa jurídica *on line* e com metodologias ativas, por canais de comunicação que limitam quantidade de palavras, pela fragilidade da veracidade de informações em mensagens, posts, vídeos, jornais e textos, por grupos em bolhas, pela atrevida desvalorização da educação e da cultura, e também pela encantadora e ao mesmo tempo ameaçadora presença da inteligência artificial no campo jurídico. Mas é justamente nesse complexo ambiente contemporâneo que a Filosofia do Direito se mostra ainda mais importante, porque precisamos de seus vetores para superar (minimamente) a sensação de incerteza e de risco e para que tenhamos uma visão menos turva do caminho a seguir.

Os trabalhos sobre Filosofia do Direito também devem se redesenhar, criando signos para que a comunicação emissor-receptor seja eficaz, fazendo com que o valioso conteúdo do conhecimento de autores clássicos e também dos

contemporâneos cheguem a múltiplos destinatários, não só àqueles iniciados que procuram o pensamento filosófico em textos densos (embora ricos) mas também a todos os demais ávidos e necessitados pela imprescindível compreensão ampla e consistente de teorias do Direito, da Moral e da Justiça. Para o que nos interessa, os estudos de Filosofia do Direito devem ser, sobretudo, contextualizados com o sistema jurídico brasileiro atual, de maneira que teorias antigas, modernas e recentes sejam vistas sob o prisma do *Civil Law* com a extensão da interseção que temos com o *Common Law*. Reconhecendo relevância no conhecimento acadêmico e igualmente na experiência prática extraída em várias carreiras jurídicas (como advocacia consultiva ou processual, magistratura etc.), há frutos expressivos em casos nos quais esses dois campos dialogam na realidade brasileira.

É nesse conjunto de necessidades, exigências e objetivos que emerge *O Manual definitivo para entender a Filosofia do Direito* de Paulo Gustavo Guedes Fontes. Do autor há muito de bom a dizer, mas me limito ao reconhecimento de suas qualidades como intelectual, pessoa de verdadeira leitura e de cultura jurídica (mas não só), ponderado, lúcido, firme e íntegro em suas avaliações (consequências de seu amplo conhecimento), com formação acadêmica em respeitáveis instituições do Brasil e da França, e também de suas experiências profissionais (notadamente como Procurador da República, compondo o Ministério Público Federal, e agora como Desembargador no Tribunal Regional Federal da 3ª Região). Mais do que titulação e cargos, Paulo Gustavo Guedes Fontes têm os atributos e as experiências necessárias para a produção de conteúdo sobre Filosofia do Direito combinando profundidade acadêmica e sua utilização concreta, com linguagem didática e voltada para a realidade brasileira contemporânea. Friso sua generosidade, dedicando seu tempo escasso para a produção deste livro com a única e exclusiva finalidade de partilhar o melhor o seu conhecimento.

Relendo a presente obra, lembrei-me de uma referência corrente dentre pedagogos, segundo a qual um experiente professor pediu desculpas a seus alunos por ter dado uma aula longa, dizendo que não havia tido tempo suficiente para prepará-la. A capacidade de alinhar ideias complexas a partir de seus aspectos centrais, explicando ao leitor o significado e a utilidade prática de correntes filosóficas, sempre de maneira clara e objetiva, são qualidades que dependem de importante preparação, construída por Paulo Gustavo Guedes Fontes ao longo de sua consistente e dedicada vida acadêmica e profissional, como facilmente é possível constatar neste e em outros de seus livros.

Esta obra toma como ponto de partida a exposição didática das ideias essenciais de Direito como meio coercitivo de controle social, cuidando de suas principais correntes filosóficas e de seus critérios de identificação e de validade, para depois tratar dos fundamentos da Moral e de também de suas correntes filosóficas, estabelecendo padrões comparativos pelos quais o autor aponta suas áreas de conexão e de distinção. Nesse mesmo padrão de análise, a obra prossegue conceituando Justiça e sua relação com o Direito, auxiliando o leitor a conhecer esse

complexo problema prático, presente e relevante em sociedades pluralistas como a brasileira.

O Manual definitivo para entender a Filosofia do Direito prossegue apresentando as principais correntes da filosofia do Direito, começando pelos jusnaturalismos, passando para os positivismos jurídicos, depois para os realismos e para os pragmatismos, chegando aos neoconstitucionalismos. Além de um leitor dedicado das múltiplas obras que documentam sua pesquisa bibliográfica (necessárias para apresentar objetivamente o conteúdo de trabalhos como os de John Austin, Hans Kelsen, Herbert Hart, Tom Campbell, Jeremy Waldron, Norberto Bobbio, Richard Posner, Ronald Dworkin e Robert Alexy), Paulo Gustavo Guedes Fontes também exhibe elevado padrão crítico, conforme se pode notar por sua análise dos neoconstitucionalismos (objeto de outros de seus estudos).

Em sua parte final, o autor expõe a hermenêutica à luz das correntes jusfilosóficas, e, dialogando com as partes anteriores deste *Manual* classifica e apresenta métodos interpretativos e da moderna argumentação jurídica (dentre elas a de Neil MacCormick), concluindo com a integração de lacunas segundo a teoria do ordenamento jurídico (contribuição do positivismo jurídico à teoria geral do Direito) e seus elementos de unidade, coerência e completude.

Uma outra qualidade deve ser sublinhada neste *Manual*, a isenção. Descrevendo correntes, teorias, métodos e demais objetos da Filosofia do Direito, e mesmo quando tece inevitáveis críticas, o autor reconhece e respeita a representatividade de ideais opostas, sem induzir o leitor (sequer implicitamente). Essa marca pluralista do conteúdo da presente obra é um alento e um guia para que os leitores se orientem na escolha de qual corrente e teoria do Direito deverá adotar, porque é justamente esse rigor metodológico que traduzirá a coerência de cada um dos profissionais da área jurídica, evitando mesclas ou junções de frações incompatíveis e convertendo o trabalho jurídico em práticas especulativas, decisionistas, voluntaristas e incoerentes.

É um privilégio testemunhar a expressiva obra *O Manual definitivo para entender a Filosofia do Direito*, e do talento de Paulo Gustavo Guedes Fontes, pela pesquisa e pela redação clara e objetiva, auxiliando todos aqueles que veem a importância da consistência do saber jurídico a partir de seus padrões filosóficos.

Agosto de 2020.

José Carlos Francisco

Professor na Universidade Mackenzie/SP, Líder do grupo de pesquisa CNPq Cidadania, Constituição e Estado Democrático de Direito, Diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais – IBEC, Membro do Instituto Pimenta Bueno – Associação Brasileira dos Constitucionalistas, Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo - USP, Estágio de Pós-Doutorado na Universidade de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), e Desembargador no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Direito, Moral e Justiça

Parte I

1. O conceito de direito

O conceito de direito depende diretamente da perspectiva filosófica que se adote. Ele irá variar, por exemplo, conforme se prefira o positivismo, o jusnaturalismo, o realismo jurídico, correntes que serão analisadas na Parte II desta obra, dentre outras. Contudo, o presente capítulo será relevante para apresentar ao leitor noções e problemas que serão retomados adiante com maior profundidade.

1.1. O direito como meio de controle social

O direito é usualmente considerado um meio ou forma de *controle social*. Abstraindo-se considerações de cunho religioso, o homem é o único ser, entre seres vivos e inanimados, que não tem as características de sua existência determinadas inteiramente pela própria natureza. Os animais estão presos a um determinismo biológico, que irá ditar de forma peremptória como é (e não como *deve ser*) a vida de um indivíduo de determinada espécie: o que irá comer, como irá se acasalar, como é seu comportamento dentro do grupo. Também os seres inanimados estão sujeitos a leis constantes, senão imutáveis, como os planetas em seu movimento. Já os homens, apesar de também estarem submetidos a leis biológicas, possuem certa liberdade em escolher e fixar um modo de vida, do que é testemunho a diversidade de culturas existentes. Eles podem adotar diferentes maneiras de compreender o mundo, o seu papel nele, de como devem agir, de como devem organizar-se a família e a sociedade, enfim, do que é certo, errado, bom, mau, justo e injusto.

A existência de algumas características humanas intrínsecas, como a vulnerabilidade física, e do seu meio, como a escassez de recursos, obrigam as sociedades a estabelecer *regras de conduta* que incluem sempre um mínimo de *abstenções*, sem as quais a vida em comum seria impossível, sendo a mais importante dentre elas a que impede os homens de matar ou ofender a integridade física dos demais. Daí o famoso brocardo “*ubi societas, ibi jus*”(onde há sociedade, há direito).

Não é só o direito que se apresenta como forma de controle das condutas dos indivíduos em sociedade. A moral também o faz, bem como a religião, as normas de trato social, e existe possivelmente um conjunto de condutas que é incentivado ou proibido em todas essas esferas. É razoável supor que em estágios mais primitivos do desenvolvimento humano, essas formas de controle social mostrem-se amalgamadas e menos distinguíveis entre si; assim, a religião teve – e ainda tem em alguns Estados – um papel preponderante em termos morais, podendo mesmo apresentar o caráter coercitivo que depois será peculiaridade do direito. O direito é, pois, uma dessas formas de controle, que se destacou das demais e possui algumas características próprias.

1.2. O caráter coercitivo do direito

Para a maioria dos autores, o direito seria o conjunto de normas ou regras que regulam as relações entre os homens numa dada sociedade, cuja observância é obrigatória e garantida de forma coercitiva. Na definição de Ihering, o direito é “*o conjunto das condições de vida da sociedade asseguradas pelo Poder Estatal por meio de coação externa.*”^[1]

A coerção ou coação é o elemento que diferencia o direito das demais esferas normativas da vida humana, notadamente das normas morais. A coação existente na obrigação jurídica materializa-se na *sanção*: ela consiste na ameaça de imposição de um mal, a penalidade imposta a quem descumprir a norma jurídica. Essas penalidades variam bastante: na esfera penal podem consistir em multas, prestação de serviços à comunidade, privação da liberdade; na esfera cível, o devedor, se não realizar o pagamento de suas dívidas de forma espontânea, pode vir a ser expropriado de seus bens por meio do processo de execução.

Pode-se argumentar que as normas morais e aquelas conhecidas como de trato social também preveem sanções. Alguém que apresente uma conduta moralmente reprovável pode ver-se privado de amigos e até ser alvo de medidas de retaliação, como a negativa de obtenção de um emprego. O comportamento imoral pode também acarretar remorso e arrependimento, pois o indivíduo geralmente introjeta as regras morais como parte de sua psique, o que a psicanálise chama de superego ou *ideal do eu*. No entanto, essas sanções distinguem-se da sanção jurídica, pois são difusas, internas e não incluem o uso da força física. Diz-se também da sanção jurídica que ela é externa e institucionalizada.

Dessa forma, ao admitir-se a sanção como característica que distingue as normas jurídicas das morais, está-se a reconhecer que o direito, em última instância, é garantido por meio da força física exercida pelo Estado. Com efeito, como assevera o sociólogo alemão Max Weber, a característica marcante do Estado é o monopólio legítimo ou legal da força física.^[2] Só o Estado pode utilizar-se legalmente da força física, com exceção de alguns casos em que seu uso é autorizado também ao particular, como a legítima defesa no Direito Penal e o desforço possessório na seara cível.

Como dito, divergências existem quanto ao conceito de direito e suas características essenciais; alguns autores não concordam que a sanção figure entre elas. Há áreas do direito em que a sanção não é tão nítida, como nas normas que definem competências ou que estipulam as condições de validade de determinados atos jurídicos, como o casamento, o testamento, etc. Nesses casos incidiria um outro tipo de sanção, que seria a *nulidade* dos atos que deixarem de observar as normas respectivas. Essas normas consistiriam em condições para que determinados institutos

e atos possam ser considerados válidos e, então, contar com o aspecto sancionatório propriamente coercitivo do direito: o beneficiário de um testamento feito conforme as disposições legais poderá acionar o Judiciário para vê-lo cumprido, podendo o juiz exercer a coação legal em face de alguém que detenha indevidamente os bens em questão. Nesse sentido, também é importante a distinção de Hart, um dos mais influentes autores positivistas, entre as normas primárias e secundárias de um sistema jurídico; as primeiras dirigem-se aos cidadãos e estipulam obrigações e sanções, enquanto as secundárias dizem respeito ao próprio direito e à sua aplicação, dividindo-se em normas de reconhecimento, modificação e julgamento.^[3]

1.3. As correntes jusfilosóficas e os critérios de identificação e validade do direito

Até aqui, vimos as características gerais do direito como realidade social. Da forma como expostas – *o direito seria uma forma de controle social, composto por regras de conduta que se diferenciam das demais regras desse tipo por seu caráter coercitivo* –, poderiam ser aceitas sem maior dificuldade pela maioria das correntes da Filosofia do Direito. Constituiriam o elemento, por assim dizer, empírico do conceito.

Os problemas aparecem logo em seguida, quando nos perguntamos, por exemplo, qual é o direito válido em determinada sociedade e quais os critérios para identificá-lo.

Como veremos na Parte II, de maneira mais aprofundada, para o positivismo jurídico o direito é uma construção humana, convencional, social e, pois, deve ser buscado nas normas emanadas do Estado. Para o positivismo, o direito é o *direito positivo*, aquele posto pelo Estado e geralmente associado ao *direito escrito*, consubstanciado nos códigos e nas leis em geral. Essa visão sobre o positivismo jurídico é um tanto simplificador, olvidando aspectos importantes, mas expressa parte das formulações dessa corrente.

A validade de uma norma, para o positivismo jurídico, dependeria de sua conformidade com os critérios internos do próprio sistema jurídico de que faz parte (*legalidade conforme o ordenamento*).

Já para o jusnaturalismo, ou teoria do Direito Natural, o direito não se resume ao direito positivo, posto pelo Estado. Ao lado do direito positivo, ou melhor, acima dele, haveria o *Direito Natural*, um conjunto de leis derivadas da natureza do homem e das coisas, universais e imutáveis. Essa lei natural superior é que emprestaria à lei positiva seu fundamento e validade, desde que esta última esteja em conformidade com ela. O jusnaturalismo pode apresentar-se sob matizes variados e o Direito Natural pode derivar da própria natureza, de Deus ou da razão, ou ainda da ideia ou sentimento do *justo*.

Essa corrente, contudo, não nega a existência e a validade do direito positivo. Só em caso de colisão entre as normas do Direito Natural e aquelas do direito positivo é que estas últimas deveriam ceder, com base na máxima atribuída a São Tomás de Aquino segundo a qual “*lex iniusta non est lex*” (*a lei injusta não é lei*), abrandada pela chamada fórmula de Radbruch, de acordo com a qual “a lei extremamente injusta não é lei.”

Assim, segundo o jusnaturalismo, existiria ainda outro critério de validade para a norma jurídica: o critério ético ou moral da validade, isto é, a conformidade da norma com a justiça e com o Direito Natural.

Já a corrente conhecida como *realismo jurídico*, da mesma forma que o positivismo, rejeita a existência de um Direito Natural, considerado metafísico e ilusório. Contudo, seus autores rejeitam também o positivismo normativista de Kelsen, considerado igualmente idealista. Não basta que uma norma conste de um código ou lei formal para ser considerada direito. Para identificar o que é o direito em uma dada sociedade, os realistas adotam sobretudo o critério da *eficácia*, no sentido mesmo de efetividade, e conferem papel de especial relevo às decisões judiciais. Para eles, os juízes não apenas aplicam o direito, mas o criam; alguns desses autores postulam que o direito não existe antes da decisão judicial que efetivamente o consagra.

Para o realismo jurídico, e para o *sociologismo jurídico* que com ele guarda alguma proximidade, o critério de validade preponderante é o da validade social ou sociológica. Vale aquilo que é efetivo numa dada sociedade.

Embora, como vimos, no positivismo jurídico prepondere o critério *jurídico* da validade (*legalidade conforme o ordenamento*), essa corrente também confere importância ao referido critério da *eficácia social*. Para Kelsen, a validade não se confunde com a eficácia, mas esta, se não é *causa* da validade, é dela uma *condição*. Tanto o sistema jurídico global quanto uma norma particular perdem a validade caso se mostrem totalmente ineficazes; assim, para o autor austríaco, a *desuetudo* – lei escrita em desuso – é como um costume negativo que leva à perda de validade da norma.^[4]

Esses três critérios de validade da norma – *jurídico, ético e sociológico* –, na base de teorias distintas da validade ou, diríamos, das próprias correntes da Filosofia do Direito, respectivamente o positivismo, o jusnaturalismo e o realismo, são referidos por Robert Alexy, que de alguma forma admite todos eles.^[5]

Assinala-se a proximidade dessa formulação com as do filósofo brasileiro Miguel Reale, com sua teoria tridimensional do direito, ao considerar indissociáveis para a compreensão do direito as dimensões de *fato, valor e norma*.

Observe-se que Reale não quer dizer apenas que toda norma jurídica versa sobre determinados fatos e alberga valores. O fato a que se refere é o “fato do direito”, isto é, o direito como fato social, dotado de eficácia, que é o critério de validade para as correntes sociológicas; o valor é o direito como realidade valorativa que, segundo as correntes moralistas, não se desprende totalmente dos parâmetros éticos; o direito como norma é como concebido pelo positivismo ou normativismo. A teoria tridimensional diz respeito, pois, no exato sentido mencionado por Robert Alexy, aos critérios de validade adotados pelas diversas correntes da Filosofia do

Direito, consideradas reducionistas por Reale ao elegerem apenas um desses critérios, vislumbrando-se a seguinte correspondência: *fato* – critério sociológico de validade; *valor* – critério ético e *norma* – critério jurídico. ^[6]

1.4. O elemento moral

Vimos nos itens 1.1. e 1.2 supra que o direito possui algumas características gerais, como o aspecto coercitivo, que podem ser admitidas pelas diversas correntes filosóficas. Contudo, no item 1.3., verificamos que tais correntes divergem sobre a origem dessas regras coativas (*o Estado, o Direito Natural*), seus fundamentos, como identificar o direito, etc.

O principal aspecto dessa divergência reside nas relações entre direito e moral e direito e justiça, que serão objeto dos dois próximos capítulos. Dissente-se principalmente se o direito poderia ser conceituado de forma independente da moral ou se o elemento moral persistiria de alguma forma no conceito de direito. Uma definição do direito que inclui o elemento moral de forma explícita seria a do jurisconsulto Celso, segundo a qual “*jus est ars boni et aequi*” (*o direito é a arte do bom e do justo*).

Os positivistas defendem a *tese da separação* entre direito e moral, enquanto jusnaturalistas e mesmo autores modernos como Robert Alexy defendem a *tese da conexão ou vinculação* entre essas duas realidades.

2. Direito e moral

2.1. Conceito de moral

Inicialmente, devemos esclarecer que utilizaremos com a mesma significação os termos moral e ética, pois não se distinguem do ponto de vista etimológico, um advindo do grego (*ethos*) e outro do latim (*mores*), mas ambos remetendo à mesma ideia de costumes.^[7] Há, contudo, autores modernos que lhes conferem significados distintos, considerando a ética uma concepção do mundo, do que seja a “vida boa”, tal como era debatida pelos filósofos gregos, deixando à moral as obrigações de conduta que ela impõe em relação aos outros.

A ética, na filosofia grega, está de fato voltada a estabelecer o que é a vida boa, o “sumo bem”, a felicidade, e isso inclui não só desvendar a finalidade ou sentido da vida, como também as regras que devem orientar nossa relação com os outros. Podemos lembrar, a título de exemplo, duas escolas filosóficas que se opuseram na Antiguidade, o estoicismo e o epicurismo. Para os estoicos, a felicidade é atingida pela prática da virtude e pela aceitação resignada dos acontecimentos que não dependam da nossa vontade. Já Epicuro afirmava que a felicidade consistia em obter prazer e evitar a dor, o que, no entanto, não aconselhava a uma conduta dissoluta; o prazer dos epicuristas era calmo e sereno. Já na filosofia moderna, como se vê em Kant, as ideias de felicidade e moral irão de alguma forma dissociar-se.

Assim, a ética ou moral, como disciplina ou área do conhecimento, diz respeito à conduta humana, sobre o que se *deve* fazer, sobre os fins que devem ser buscados, as regras que devem reger as relações entre as pessoas, os seus fundamentos. Alguns autores podem falar nesse sentido amplo em *eticidade*, que abrangeria a moral e o próprio direito.

2.2. Fundamentos da moral

Segundo Roger-Pol Droit, existem três tipos de resposta para a pergunta “*de onde vem a ética?*”. A primeira seria que a ética vem de Deus, é por Ele estabelecida; o autor inclui também aqui a fundamentação não religiosa, mas metafísica da ética, como o platonismo. A segunda resposta seria que a ética é algo natural, provém da natureza, do que seria manifestação o sentimento espontâneo de piedade. Por fim, para a terceira corrente, a ética teria fundamento meramente convencional e seus preceitos seriam criados pela razão e sensibilidade do homem.^[8]

Acresceríamos à classificação acima a menção a um fundamento *racional* da ética. As escolas do Direito Natural por vezes recorrem a essa justificativa, considerando que as leis naturais derivariam da razão humana. Também Kant irá esforçar-se por conferir à ética um fundamento laico, não religioso, baseado igualmente na razão. Teríamos assim uma justificativa da ética que, por um lado, dispensa a religião e, por outro, não se contenta com a ideia de que ela deriva da mera vontade ou convenção dos homens. Ao explicar a filosofia moral de Kant, Perelman diz: “*O imperativo religioso é substituído pelo de nossa própria consciência.*”^[9]

Os fundamentos que se possa dar à ética ou moral relacionam-se de forma relevante com a Filosofia do Direito. Com efeito, como acima asseverado, o jusnaturalismo ou teoria do Direito Natural baseia-se na dedução de alguns princípios de conduta, a um tempo moral e jurídicos, que seriam *naturais* ao homem e passíveis de ser conhecidos e estabelecidos pela razão. Já o positivismo jurídico tende a conferir à moral e ao direito um caráter meramente convencional.

Isso nos leva à questão das mais relevantes, tanto para a filosofia moral quanto para a Filosofia do Direito, sobre a possibilidade do conhecimento ético. Discute-se se os valores e as obrigações morais podem ser conhecidos de forma racional, objetiva – temos aí o *realismo ou objetivismo moral* – ou se, ao contrário, não podem sê-lo, pois dependeriam da subjetividade do agente e seriam sempre controversos – o chamado ceticismo ou *relativismo axiológico ou moral*.^[10]

Para o relativismo moral, é importante a chamada *lei de Hume*, do filósofo escocês do século XVIII David Hume, que distingue *juízos de fato* e *juízos de valor*. Os juízos de fato poderiam ser objeto da resposta “verdadeiro ou falso”, mas não os juízos de valor. Os valores pertenceriam a uma ordem distinta, correspondendo aos *fins* da vida humana, sobre os quais não se poderia realizar uma demonstração racional. Assim, por exemplo, segundo o relativismo, uma questão como a da eutanásia não pode ser dirimida de forma racional, isto é, não há uma resposta *verdadeira*; o tema levaria à confrontação de valores talvez incomensuráveis, como a

inviolabilidade da vida humana, a compaixão pelo enfermo, a dignidade da pessoa humana, quiçá ainda envolvendo pontos de vista religiosos.

Ainda segundo a lei de Hume, de um fato não se pode derivar um valor, de um “é” não se pode chegar a um “*deve-se*” qualquer. A constatação de determinada lei natural ou ocorrência factual não implica de forma necessária num valor correspondente ou numa norma de conduta. Entre o mundo dos fatos e o dos valores haveria um intervalo não transponível de forma lógica ou causal. A questão tem importância, por exemplo, na discussão sobre a *eficácia social* como critério de validade do direito – admitido pelas correntes realistas e sociológicas, mas rejeitado tanto pelo jusnaturalismo como pelo positivismo normativista.^[11]

As teorias do Direito Natural, como veremos, albergam um componente de realismo ou objetivismo moral, enquanto, no campo do positivismo, é mais frequente o relativismo axiológico, como em Kelsen.

2.3. Correntes da filosofia moral

Existem muitas correntes no âmbito da filosofia moral e aqui pretendemos dar notícia de apenas duas delas, consideradas as mais importantes, o kantismo e o utilitarismo. Ambas são do século XVIII, século do Iluminismo, e trazem desse contexto filosófico uma especial deferência à razão – postulam para si, pois, um caráter racional.

Kant (1724-1804) é talvez o principal filósofo da modernidade. Sua obra pode ser dividida em duas partes principais, aquela em que trata dos fundamentos do conhecimento – teoria da *razão pura* – e a que trata da moral e do Direito – teoria da *razão prática*. No que concerne a seus estudos sobre a moral, Kant acredita que a lei moral é algo absoluto, que se impõe ao homem, e distingue-se de outros aspectos da conduta humana, como os sentimentos e os interesses. Trata-se do *imperativo categórico*. Para ele, uma ação não tem valor moral se for comandada por um sentimento, mesmo que seja um sentimento positivo como o amor e a compaixão; da mesma forma, não tem valor moral a conduta adotada em razão de um interesse ou conveniência. A ação moral, para receber esse predicativo, é orientada unicamente pelo dever. Podemos dizer que Kant, como Kelsen buscou fazer em relação ao direito, formula uma “teoria pura da moral”.

Kant não se debruça sobre o conteúdo que devem ter as leis morais, o que leva alguns autores a criticarem sua teoria como formalista. Isso não é totalmente verdade, pois o filósofo chega a definir o imperativo categórico, segundo o qual uma ação, para ser correta, deve ser “universalizável”, isto é, devemos questionar se determinada ação pode ser adotada por todos os homens; se ela passar no teste, trata-se de uma ação correta, dotada de valor moral.^[12] Essa definição aproxima o imperativo categórico da chamada “regra de ouro”, presente em várias religiões, que recomenda não fazer ao próximo o que não gostaríamos que fosse feito conosco.

A corrente que disputa com o kantismo a preferência dos filósofos da moral é o *utilitarismo*. A doutrina foi formulada por Jeremy Bentham (1748-1832) e desenvolvida entre outros por John Stuart Mill (1806-1873). Bentham quis também dar à moral um fundamento secular e científico e buscou basear-se em critérios supostamente objetivos como o prazer e a dor, e no conceito de felicidade, que seria justamente a obtenção de prazer e a evitação da dor. Para ele, a ação moralmente correta seria simplesmente a que trouxesse mais felicidade, não apenas para o indivíduo, mas para o maior número de pessoas: maior felicidade para o maior número. Sendo assim, o critério para se avaliar o valor moral de uma conduta são as *consequências* que dela advêm – será melhor a conduta que gerar mais felicidade. Fala-se, portanto, em relação ao utilitarismo, de uma *ética consequencialista*, em oposição à *ética de princípios* ou deontológica de inspiração kantiana. O utilitarismo representou um progresso na medida em que, ao desvincular a moral da religião ou da

tradição, permitiu ao indivíduo uma maior liberdade; também os utilitaristas foram precursores na defesa dos direitos das mulheres e dos animais.

O utilitarismo sofre críticas por pensar numa felicidade *global*, que pode vir em detrimento das minorias e dos direitos individuais. Exemplo de discussão que contrapõe as éticas deontológica e consequencialista é o dilema do vagão (*trolley dilemma*). Proposto por Philippa Foot em 1967^[13], o dilema propagou-se no meio acadêmico anglo-saxão, a ponto de se falar em *trolleyology*.^[14] Com variações que vão acrescentando complexidade ao problema, o dilema propõe um vagão desgovernado e um “agente moral” do lado de fora, com a mão na alavanca que pode acionar a bifurcação dos trilhos: se nada fizer, o vagão seguirá seu curso e matará cinco trabalhadores; no outro trilho, que o vagão tomará com a intervenção do agente, matará apenas um trabalhador. O que ele deve fazer?

O utilitarismo, ao lado do positivismo jurídico e do ceticismo, foi alvo das críticas do filósofo do direito norte-americano Ronald Dworkin, de quem trataremos na Parte II.^[15]

2.4. Relações entre o direito e a moral

Como já asseverado, um dos temas mais relevantes, senão o principal, da Filosofia do Direito é o das relações entre o direito e a moral. A polêmica gira em torno da existência de uma conexão *conceitual* entre as duas realidades (2.4.1), pois a existência de uma conexão *contingencial* ou histórica é em geral admitida pelos próprios positivistas (2.4.2).

2.4.1. A questão da conexão conceitual

Por conexão conceitual ou classificatória, entende-se aquela em que o próprio conceito de direito confundir-se-ia de alguma forma com o conceito de moral. Direito e moral seriam, em determinado ponto da reflexão, a mesma coisa. O brocardo jusnaturalista “*lex iniusta non est lex*” (a lei injusta não é lei) exprime o que seria essa conexão, em que se tocam as realidades do direito e da justiça, forma como a moral aparece com mais frequência no mundo jurídico.

Os positivistas entendem que para definir o direito não é necessário recorrer a noções próprias do campo moral, como a justiça: eles adotam a **tese da separação** entre direito e moral. O direito é definido a partir de critérios formais e a validade da norma jurídica independe de sua coincidência com as regras da moral. Uma lei pode ser injusta ou até muito injusta sem deixar de ser lei. John Austin, um dos precursores do positivismo jurídico, afirmou que “*a existência do direito é uma coisa, seu mérito ou demérito, outra*”^[16], no que foi seguido por Hart, ao distinguir “*o que o direito é do que ele deveria ser.*”^[17]. Nas palavras de um positivista atual, Leslie Green,

O fato de uma política mostrar-se justa, inteligente, eficiente ou prudente nunca é razão suficiente para pensar que ela é realmente a lei, e o fato de esta última mostrar-se injusta, tola, ineficiente ou imprudente não é razão suficiente para duvidar disso.^[18]

Já os jusnaturalistas, defensores das teorias do Direito Natural, e também outras correntes ditas moralistas da Filosofia do Direito, como por vezes são consideradas as formulações de Dworkin e Alexy, entendem que o conceito de direito inclui necessariamente o elemento moral: adotam a **tese da conexão ou da vinculação** entre direito e moral. Para o jusnaturalismo, o conceito de direito remeteria ao que consideram ser sua essência, propiciar a realização da justiça e a convivência harmoniosa entre os homens. Daí um autor como Radbruch, que fora positivista antes da Segunda Guerra Mundial, ter aderido ao pensamento jusnaturalista após o conflito, adotando a célebre *fórmula de Radbruch*, que é uma modalidade atenuada do brocardo latino lembrado acima; para ele, a lei *extremamente injusta*, como foram algumas das adotadas sob o regime nazista, não deve ser considerada direito.

Entre os autores que defendem a tese da conexão existem algumas diferenças. O jusnaturalismo, bem como um autor moderno como Alexy, veem a conexão no próprio conceito. Alexy afirma que o direito tem sempre uma “pretensão à correção”, isto é, sempre postula uma legitimidade do ponto de vista moral, mesmo que não a satisfaça. Seria impensável, diz Alexy, uma Constituição cujo primeiro artigo fosse “X é uma república soberana, federal *e injusta.*”^[19]. Essa pretensão à correção teria reflexos importantes em temas como a argumentação jurídica e a própria teoria dos princípios.

Outros autores vislumbram a conexão entre direito e moral, de forma mais nítida, nos procedimentos de aplicação do direito, portanto, no momento interpretativo, como seria o caso de Ronald Dworkin. Para este autor, nos chamados casos difíceis (*hard cases*), quando a lei não é clara e o tema envolve grandes indagações morais, o juiz deve se valer dos princípios, que são a um tempo morais e jurídicos, e integram o direito segundo a concepção dworkiniana do “*direito como integridade*” (*law as integrity*). [\[20\]](#)

2.4.2. Conexão histórica ou contingencial

Mesmo negando a existência de uma conexão conceitual entre direito e moral, os positivistas admitem a existência de uma conexão histórica ou contingencial, isto é, apesar de as noções poderem ser distinguidas, na prática das sociedades elas estão, sim, associadas – mas essa associação não é necessária, imprescindível, existente sempre em todos os casos. Assim, segundo Hart,

não se pode negar em sã consciência que o desenvolvimento do direito tem de fato sido influenciado, em todos os tempos e lugares, tanto pela moral quanto pelos ideais convencionais de grupos sociais específicos(...) ^[21]

É evidente que a moral de determinado grupo, a chamada moral positiva ou social, que inclui valores e normas, influencia o direito, sendo em parte absorvida por ele. O direito também pode influenciar a moral, quando um padrão normativo adotado pelo sistema jurídico provoca mudanças nas convicções morais da sociedade. Mas, em geral, o sistema jurídico desenvolve-se a partir das concepções morais de dada sociedade, incorporando *a posteriori* a evolução e mudanças operadas nesse campo. A lei nem sempre é justa ou precisa ser justa para ser lei, mas na maioria das vezes o é, satisfazendo os critérios dominantes de moralidade. Com efeito, a maior parte das regras de um sistema jurídico coincide com as da moral, com aquilo que é considerado justo pela maioria das pessoas. Assim, tomando como exemplo o Direito Civil, a maioria das pessoas entende que a propriedade é justa, ou consideram justo que o pai pague pensão alimentícia a seus filhos quando não resida com eles; já em relação ao Direito Penal, também na ótica dominante é justo que alguém seja preso por praticar um homicídio ou desviar dinheiro público.

A ligação entre o direito e a moral, na concepção de Hart, vai ainda além. Com efeito, este autor admite que existe no direito positivo, nas mais variadas épocas e lugares, um “*conteúdo mínimo do direito natural*” ^[22], isto é, normas comuns ao direito e à moral, como as mencionadas abstenções consistentes em não matar ou ofender a integridade física de outrem e respeitar a propriedade alheia; tais normas, por sua vez, derivariam de características intrínsecas da existência humana, como a vulnerabilidade física e os recursos materiais limitados, entre outras. Contudo, mesmo assim, Hart continua a defender a tese da separação conceitual entre direito e moral.

A questão sobre a existência do elemento ético ou moral no conceito de direito relaciona-se com aquela outra, mais própria da filosofia política, referente aos fins do Estado e à sua legitimidade. Santo Agostinho perguntava: “*O que são os Estados sem justiça, senão grandes bandos de ladrões?*” ^[23]. Qual a função do Estado? Será mesmo que ele objetiva a realização do bem comum? Ou deveríamos adotar uma perspectiva crítica, como a do marxismo, entre outras, de que o Estado serve fundamentalmente aos interesses de uma classe dominante?

O direito e o Estado, embora nem sempre possam ser associados à ideia de justiça ou bem comum (pensemos num direito escravagista!), realizam quase sempre em alguma medida o interesse coletivo pois, mediante a coação, impõem uma ordem que garante às pessoas um mínimo de segurança, com a preservação de sua vida e integridade física. Mesmo um precursor do positivismo como Hobbes atribuía uma finalidade ética ao contrato social e ao Estado que se constitui a partir dele, que seria a de preservar a vida dos súditos. Também Kelsen, o mais conhecido dos positivistas modernos, entendia que a consecução da segurança coletiva e da paz seria o objetivo da ordem jurídica, ao menos no Estado moderno, que representa uma ordem jurídica centralizada. [\[24\]](#),[\[25\]](#)

2.5. Distinções entre o direito e a moral

Já mencionamos que a principal diferença entre o direito e a moral, destacada pela maioria dos autores, é a existência da sanção, e uma sanção de caráter coercitivo, capaz de autorizar mesmo o uso da força física (ver item 1.2 supra). As normas morais e mesmo as de trato social também preveem sanções, mas estas são difusas e não podem incluir o uso da força, consistindo nas diversas formas de reprovação social da conduta imoral.

Diz-se também que o direito é heterônomo, no sentido de que a regra jurídica “vem de fora”. A norma moral seria autônoma, trata-se de uma regra que o próprio indivíduo se impõe. Daí também dizer-se que a moral tem um caráter “interno”, distinto do direito. A norma moral, para ser bem atendida, exige uma concordância interior do agente, uma adesão verdadeira àquele agir; já o direito contenta-se em geral com o mero adimplemento “externo” da norma, sem necessidade da concordância interna do agente. Nada obstante, os aspectos internos podem, sim, ter relevância para o direito, sendo frequente a sua consideração no Direito Penal, quando, por exemplo, cogita-se se o agente agiu com culpa ou dolo, se tinha consciência da ilicitude, etc.

2.6. Teorias dos círculos

Alguns autores recorrem à geometria para espelhar as relações entre direito e moral. Um deles é o jurista francês Claude Du Pasquier, segundo o qual a relação entre as duas realidades seria adequadamente descrita por dois *círculos secantes*, isto é, que se superpõem apenas parcialmente. Haveria normas jurídicas que seriam indiferentes à moral, normas morais que, por sua vez, não interessariam ao direito, como, por exemplo, o dever de gratidão, e um conjunto de normas que pertenceria ao mesmo tempo aos dois grupos.

Jeremy Bentham, o principal autor utilitarista, de quem falamos acima, propõe a teoria dos *círculos concêntricos*. Aqui, o círculo que representa o direito estaria englobado pelo círculo de maior raio representando a moral. Nessa perspectiva, a moral é mais extensa que o direito e o abrange, de maneira que as normas jurídicas coincidem com parte do sistema moral.

Teoria próxima dos círculos concêntricos de Bentham é aquela que concebe o direito como um *mínimo ético*. O direito integraria o sistema normativo maior representado pela moral, conferindo a algumas normas morais, por sua importância para a convivência social, o caráter coercitivo próprio do direito.

A teoria dos círculos concêntricos e do mínimo ético parece-nos fornecer uma descrição satisfatória das relações entre direito e moral. É verdade que algumas normas jurídicas são indiferentes do ponto de vista moral – por exemplo, aquelas que definem a competência dos diversos órgãos. É indiferente à moral se determinada competência cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou ao Ministério da Saúde. Mas, valendo-nos da terminologia proposta por Hart, acima mencionada, as normas primárias de um sistema jurídico, as que preveem abstenções e obrigações dirigidas aos cidadãos, correspondem em geral à moral dominante. Além disso, para alguns teóricos, e é o caso do próprio Kant, é a moral mesma que investe o legislador positivo na sua autoridade, fornecendo-lhe como que um “cheque em branco” para o exercício do seu mandato, de maneira que o direito positivo apareceria sempre realçado pela obrigatoriedade moral.^[26] Essa perspectiva, é verdade, corresponderia a um positivismo jurídico ideológico, a nosso ver condenável, mas não deixa de coincidir com uma intuição simples, a de que obedecer à lei de forma escrupulosa, nas nossas sociedades, tem também um valor moral.

Por outro lado, podemos enxergar nessas duas teorias – dos círculos concêntricos e do mínimo ético – uma perspectiva normativa^[27] e consentânea com os postulados do liberalismo, de que o direito deve limitar-se a alguns aspectos da vida social, deixando os demais na esfera moral e, portanto, da liberdade individual. Anoto, aqui, que Carlos Maximiliano adota a teoria dos círculos concêntricos.^[28]

Por fim, já se afirmou que, em razão da tese da separação entre direito e moral, o positivismo descreveria as relações entre eles com círculos independentes, que não se tocam.^[29] A afirmação seria aceitável em se tratando apenas da conexão conceitual, negada pelo positivismo. Mas as teorias dos círculos querem na verdade demonstrar o grau de coincidência ou não entre as normas jurídicas e morais, e nesse sentido tanto a ideia dos círculos secantes como a dos concêntricos seriam compatíveis com a visão positivista, pois, como visto, o positivismo não nega a existência de expressiva coincidência entre as normas dos dois campos, ainda que na modalidade da conexão histórica ou contingencial.

2.7. Direito, moral e liberdade individual

Admitindo-se que o direito é influenciado pela moral e que pelo menos parte dos dois sistemas se superpõe, coloca-se o problema, sob a perspectiva normativa, de saber o *quantum* de interação que seria permitido ou recomendável. A incorporação pelo direito de conteúdos morais que, como vimos, é normal e inevitável, poderia acontecer de maneira excessiva, ferindo a esfera de autonomia ou independência moral do indivíduo e, da mesma forma, empobrecendo o próprio agir moral, que pressupõe a liberdade.

O direito evoluiu em parte incluindo regras que antes pertenciam apenas ao mundo moral, ou dando novas dimensões aos princípios morais e concretizando-os na regulação jurídica das relações sociais, mas também excluindo do seu âmbito determinados preceitos morais e religiosos. O que é assim excluído do direito passa a integrar um campo em que as condutas dependem da vontade individual, livres da interferência estatal, terreno de escolhas coincidente com as diversas liberdades reconhecidas ao indivíduo a partir da Reforma, do Iluminismo e das Revoluções Liberais.

Interessante nesse sentido o famoso debate entre o positivista Herbert Hart e o *Lord* Patrick Devlin, no final dos anos 50, no Reino Unido. Os dois polemizaram a respeito da descriminalização da homossexualidade, recomendada pelo relatório Wolfenden de 1957. *Lord* Devlin opôs-se à medida, defendendo que o direito deve espelhar a moral dominante e nunca passar à frente dela. Hart apoiou as conclusões do relatório, utilizando entre outros o argumento do *harm principle*, o “princípio do prejuízo” de John Stuart Mill, segundo o qual o Estado só pode proibir ao cidadão condutas que causem danos a terceiros. [\[30\]](#), [\[31\]](#)

3. Direito e Justiça

3.1. Conceito de justiça (sentido lato, estrito, divergências sobre o conteúdo do conceito)

A justiça foi considerada desde a Antiguidade uma das *virtutes cardeais*, ao lado da prudência, da temperança e da coragem.^[32] Mas ela tem lugar de destaque entre todas, pois às vezes chega a confundir-se com o conceito mesmo de virtude. Segundo Sponville, a justiça é a única, entre as virtudes cardeais, que é boa em si mesma. As demais, como a coragem, podem até servir a maus propósitos (pense-se na coragem de um terrorista suicida!), mas tal não pode acontecer com a justiça.^[33] É possível até pensar num excesso de justiça – quando ela é aplicada de forma muito rigorosa, como no brocardo latino “*summum jus, summa injuria*”^[34], o que pode ser remediado pela equidade, como veremos abaixo. Ainda aqui, a justiça não lograria confundir-se com o mal, mas cometeria talvez o erro de desconsiderar outras virtudes, como a compaixão, a moderação, a prudência.

No mesmo sentido, podemos lembrar a definição de virtude para Aristóteles, que é o *justo meio* entre dois extremos que, afastando-se da virtude, tornam-se vícios. Assim, a coragem é virtude, situando-se entre os extremos viciosos da covardia, de um lado, e da temeridade, do outro. Portanto, vemos que para a própria definição da virtude, Aristóteles vale-se do conceito de “*justo meio*”, ou seja, de critério que advém da própria noção de justiça. Esse é talvez o conceito mais lato e universal de justiça, que a aproxima do conceito de virtude ou de bem.

Mas, para o próprio Aristóteles^[35] e outros filósofos, a justiça assume também a condição de uma virtude específica e distinguível das demais. Podemos dizer de alguém que agiu de forma caridosa que agiu bem, ou de acordo com a virtude ou o bem. Mas não se segue necessariamente que agiu de forma justa, entendida a justiça, aqui, como essa virtude específica. Nesse conceito mais restrito, podemos nos perguntar o que é a justiça, uma regra justa ou um homem justo.

A justiça talvez seja a mais racional das virtudes, porque no seu conceito insere-se uma noção matemática, de equivalência ou proporcionalidade. Aristóteles, na obra citada, ao tratar da justiça, destaca que ela consiste em agir com igualdade nas relações humanas. Ele classifica a justiça em duas subespécies: a justiça distributiva e a justiça reparadora, também conhecida como comutativa, corretiva ou compensatória.

A justiça distributiva é aquela que deve presidir a distribuição “*das honras, da fortuna e de todas as vantagens que podem ser divididas entre os membros da cidade.*”^[36] Essa justiça não exige, para Aristóteles, uma divisão igualitária dos bens, mas sua divisão proporcional aos méritos e outras características dos destinatários. Consiste em tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na

medida de sua desigualdade. Já a justiça comutativa interviria nas relações entre duas pessoas, quando fosse necessário restabelecer uma condição de igualdade que foi quebrada, ou por inadimplemento contratual, ou por outro agir ilícito de natureza cível ou penal.

Aos caracteres essenciais da justiça enunciados por Aristóteles corresponde, a nosso ver, a célebre definição de Ulpiano: “*Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuere*” (*Justiça é a vontade firme e perpétua de dar a cada um o que é seu*). São Tomás de Aquino faz um acréscimo a tal definição, introduzindo de forma mais explícita a concepção aristotélica: a justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido, *segundo uma igualdade*.

O problema deste conceito, como se pode imediatamente intuir, é que ele nada diz sobre aquilo que pertence a cada um. Por isso se diz tratar-se aqui de um *conceito formal* de justiça, oposto ao que seria o seu *conceito material ou substancial*. De fato, o conceito formal não é utilizável de forma imediata, pois depende de um esclarecimento sobre aquilo que é devido a cada qual.

Dessa forma, o conceito formal de justiça – *dar a cada um o que é seu* – pode ensejar grande controvérsia, justamente por lhe faltar a definição material. É possível aplicá-lo e ainda assim obter resultados que hoje consideraríamos extremamente injustos. É dizer-se que Aristóteles, ao tratar da justiça, exclui de seu domínio a relação com os escravos, por serem propriedade dos senhores.^[37]

Nesse sentido, é importante salientar que a regra de tratar desigualmente os desiguais não possui necessariamente o caráter progressista com que hoje geralmente é lembrada e associada às chamadas “ações afirmativas”. Ela é cogitada, como visto, pelo próprio Aristóteles e consiste numa mera derivação da regra que manda tratar igualmente os iguais; não sendo iguais, seria injustiça tratá-los com igualdade, sendo, portanto, justo o tratamento desigual. Tal regra pode realizar valores morais igualitários ou, ao contrário, discriminatórios, pois não traz em si um conteúdo material, tendo já servido para legitimar regimes de escravidão e de discriminação racial, religiosa e de gênero. Precisamente por considerar que o escravo era naturalmente diferente do proprietário, e inferior, é que Aristóteles justificava a escravidão. A regra pode ter, contudo, aplicação orientada para a realização de valores igualitários, como quando se dispensa um tratamento privilegiado aos deficientes físicos nos concursos públicos: aqui se considera que eles são desiguais e se lhes confere tratamento diferenciado, mas com o objetivo de, com isso, propiciar-lhes direitos e resultados similares àqueles usufruídos pelos demais.

Perelman entende de duas maneiras as limitações do que chama a *regra de justiça*, que traduziriam o seu caráter meramente formal:

Em primeiro lugar, não diz quando diferenças devem ou não ser consideradas essenciais; em segundo, diz-nos somente que é preciso tratar da *mesma forma* os seres essencialmente semelhantes, mas não indica *como* é preciso tratá-los.^[38]

Assim, o conteúdo material da regra de justiça é precisamente saber quais as pessoas e situações que podem ser consideradas iguais ou desiguais para determinados fins, e isso irá variar conforme os sistemas morais e jurídicos. É preciso saber quais os aspectos que devem ser considerados essenciais, relevantes ou pertinentes para considerar pessoas iguais ou desiguais na aplicação de determinada norma, distribuição de alguma vantagem ou aplicação de penalidade. Segundo a nossa Constituição, por exemplo, no art. 3º, IV, é objetivo fundamental da República *promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação* e, da mesma forma, o art. 5º, *caput*, aduz que *todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza*. Ora, o texto constitucional considerou, pois, irrelevantes para a fruição dos direitos as diferenças de origem, raça, sexo, etc. Mas isso não quer dizer que elas sejam sempre irrelevantes e ilegítimas na aplicação da lei. Por exemplo, as mulheres aposentam-se, segundo a legislação previdenciária, com um tempo de trabalho menor do que o exigido do homem. Aqui, há a consideração de uma desigualdade, que é julgada essencial ou pertinente para estipular-se o tempo exigido para a aposentadoria; ela baseia-se nas diferenças entre homem e mulher, como a maternidade e os encargos que disso decorrem, levando a um maior desgaste físico. A lei reconhece tais diferenças e desigualdades e trata desigualmente homens e mulheres, como forma de igualá-los em termos das exigências necessárias à fruição de um direito. Estamos da mesma forma diante desse tipo de raciocínio na questão das ações afirmativas, como as cotas raciais. Também aqui a lei acolhe desigualdades na esfera dos fatos – por exemplo, as consequências sócio-econômicas da escravidão que vigeu no Brasil – que, aliadas à igualdade constitucional e relativa aos fins e direitos assegurados pela ordem jurídica, aconselham o tratamento diferenciado.

Quanto às limitações do conceito formal de justiça e seu inevitável preenchimento por concepções morais, assevera também Hart:

Torna-se claro, portanto, que os critérios que envolvem semelhanças e diferenças pertinentes podem variar com frequência conforme a perspectiva moral básica de determinado indivíduo ou sociedade.^[39]

Essas limitações do conceito de justiça levam alguns autores a minimizar sua importância, pelo menos em relação ao direito. É o caso de Kelsen. Para ele, é impossível definir o que é justiça de forma objetiva, para além do conceito formal já estudado, até porque ela faz parte do mundo dos valores, que não permite um conhecimento racional, segundo o relativismo axiológico que adota. Haveria na História e nas diversas sociedades concepções distintas e até opostas do que seria a justiça, não sendo possível “desempatar” tais pontos de vista. Por essa razão, Kelsen considera que o conceito de justiça não é relevante para definir o direito. Em suas palavras,

Uma teoria do direito positivista, isto é, realista, não afirma - e isto importa acentuar sempre - que não haja qualquer justiça, mas que de facto se pressupõem muitas normas de justiça, diferentes umas das outras e possivelmente contraditórias entre si. Ela não nega que uma ordem jurídica positiva possa ser determinada - e, em regra, é-o de facto - pela representação de

qualquer das muitas normas de justiça. (...) sustentando ao mesmo tempo que uma ordem jurídica positiva é, quanto à sua validade, independente da norma de justiça pela qual possam ser apreciados os actos que põem as suas normas.^[40]

Contudo, para outros autores, é possível definir a justiça, mesmo em sentido substancial. Isso será mais comum entre os jusnaturalistas e entre aqueles que, na filosofia moral, adotam a concepção realista ou objetivista, isto é, que consideram ser possível conhecer de forma objetiva o que é o bem, a justiça e outros valores.

A título de exemplo, podemos citar o jusnaturalista moderno John Finnis. Influenciado pelo pensamento de Aristóteles e São Tomás de Aquino, Finnis estabelece o que seriam os bens humanos básicos, que para ele apresentam uma natureza objetiva e constituem *fins em si mesmos*. Esses bens seriam: a vida, o conhecimento, o jogo (o aspecto lúdico da existência humana), a experiência estética, a sociabilidade e amizade, a razoabilidade prática e a religiosidade. Eles levariam à definição das condutas que são moral e juridicamente aceitáveis e, portanto, também serviriam para definir o que pode ser considerado justo e injusto na vida social.

Otfried Höffe reconhece a dificuldade de conferir uma definição substancial à justiça distributiva, mas afirma que, em termos da justiça compensatória ou comutativa, aquela que deve regular as relações de troca entre os homens, a ideia de “troca justa” não seria controversa, pois baseada no igual valor entre dar e receber.^[41] Höffe também entende como universais – não relativos ou sujeitos à controvérsia, portanto – princípios ligados aos procedimentos, também conhecidos como *justiça procedimental*. Cita como exemplos a necessidade de “ouvir o outro lado” (*audiatur et altera pars*) e a proibição de ser juiz em causa própria (*nemo iudex in sua causa*), que podem ser reunidos no princípio da *imparcialidade*. Por sua vez, a imparcialidade consiste em julgar “sem consideração das pessoas” – como a deusa da justiça, representada com a venda nos olhos –, isto é, desconsiderando quaisquer aspectos que poderiam desigualar o julgamento de forma indevida.^[42]

Tais aspectos procedimentais não seriam em si mesmo a justiça substancial, mas consistem em condições para que ela possa ser atingida. Nesse sentido, é importante mencionar a contribuição de John Rawls para o direito e principalmente para a filosofia política. O filósofo norte-americano, no seu *Uma teoria da justiça*, de 1971, tenta responder de forma racional à questão sobre o que seria uma sociedade justa; ele parte de elementos que poderiam ser associados à justiça procedimental, como o *véu da ignorância*. Retomando a ideia do contrato social, Rawls introduz a ideia do véu da ignorância, como uma *posição inicial* ideal, em que os contratantes não conhecem qual posição social ou hierárquica ocuparão na futura sociedade (por exemplo, se serão pobres ou ricos), o que os levaria a deduzir princípios justos e válidos de forma universal. Pode-se comparar a ideia rawlsiana com o procedimento do juiz que insta um dos herdeiros a estabelecer os quinhões que serão partilhados, sendo este herdeiro o último a escolher o seu – e, como a sabedoria não é apanágio de grandes, procedimento similar já se viu entre pescadores, quando trabalham em conjunto, para dividir o pescado.^[43]

3.2. A justiça e sua relação com o direito

Sobre a relação entre justiça e direito, pode-se dizer muito do que já se afirmou sobre a relação do direito com a moral, afinal a justiça é a forma como a moral se manifesta de forma mais frequente nas questões jurídicas. Com efeito, quando os filósofos do direito controvertem se a moral integra ou não o conceito de direito (item 2.4 supra), em geral não estão falando de toda a moral, mas de uma virtude específica, que é a justiça.

Para os positivistas, como visto acima, essa relação não é necessária e o direito pode ser definido sem recurso à concepção de justiça, a partir de suas fontes sociais e mediante critérios formais de validade. Já o jusnaturalismo, embora não negue a importância do direito positivo ou legislado, entende que o conceito de direito sempre inclui a noção de justiça.

O problema mais direto colocado por essa divergência conceitual refere-se às chamadas **leis injustas**. Para o positivismo, se atendidos os pressupostos formais de validade, elas continuam tendo o caráter de leis e de direito. Isso não significa, para o positivismo mais moderno, que haja uma obrigação de obedecê-las. No dizer de Hart, poderíamos chegar à seguinte conclusão: *“Isto é uma lei; mas é demasiado injusta para ser aplicada ou obedecida.”*^[44]

Para as teorias do Direito Natural, vale o princípio adotado por São Tomás de Aquino de que *“lex iniusta non est lex”* (a lei injusta não é lei). Contudo, o jusnaturalismo não prega a desobediência a quaisquer leis injustas; ao contrário, essa corrente em geral é complementada, no plano da filosofia política, pela teoria do contrato social, que legitima a existência dos governos e funda um dever de obediência às leis positivas.^[45] De maneira que somente às leis *extremamente* injustas, ou seja, que cheguem a um patamar inaceitável de injustiça, seria possível negar o caráter de lei e mitigar o dever de obediência. Esta é a *fórmula de Radbruch*, jusfilósofo alemão que era positivista e tornou-se jusnaturalista após a Segunda Guerra Mundial.

A questão das leis injustas não se coloca de forma muito concreta ou corriqueira, pois em geral as leis são consideradas justas pelos juristas das diversas correntes ou, se consideradas injustas, não o são a ponto de autorizar sua desobediência por parte de juízes e cidadãos. A questão adquire maior relevância na chamada *“justiça de transição”*, quando um regime ditatorial, autocrático, que tenha cometido abusos e violências contra os cidadãos, vem a ser substituído por um regime democrático. Nesse caso, coloca-se para os tribunais do novo regime a questão de saber como lidar com a legislação *injusta* produzida pelo governo deposto e com situações jurídicas que foram constituídas sob sua égide.

A questão foi posta, por exemplo, na Alemanha do pós-guerra, após a derrocada do nazismo. Os tribunais enfrentaram a questão da validade do 11º Decreto da Lei de Cidadania do Reich, de 25 de novembro de 1941, que privava os judeus emigrados da nacionalidade alemã. O Tribunal Constitucional Federal adotou nesse caso a fórmula de Radbruch, já mencionada, para declarar o decreto nulo *ab initio*, isto é, considerou que o decreto, por incidir em gravíssima injustiça, não podia ser considerado como lei ou direito.^[46]

O problema apresenta-se também quando se trata de julgar pessoas que, em cumprimento a leis e ordens emanadas do regime deposto, cometeram atos reprováveis que são submetidos a julgamento no novo governo. Caso famoso é o dos *denunciantes invejosos* que, por razões pessoais, às vezes mesquinhas, denunciaram ao regime nazista pessoas que tinham infringido as leis injustas então vigentes. Uma decisão da justiça alemã do pós-guerra, em 1949, condenou a mulher que havia provocado a prisão de seu esposo após denunciá-lo pela transgressão de uma lei nazista de 1934.^{[47],[48]}

Para Hart, positivista, em casos que tais seria de aplicar-se o raciocínio “*isto é lei, mas é muito injusta para ser aplicada.*” Ele defende que essa maneira de tratar o problema, mantendo o direito e a moral em campos distintos, facilita a tarefa de quem deseja negar aplicação à lei injusta: a seu ver seria um esforço teórico considerável e desnecessário argumentar que aquela lei, além de injusta, não chega a ser lei. Assim, advoga um conceito abrangente de direito, que inclua as normas iníquas, preferindo-o a outro, mais restrito, que repila tais normas.^[49]

Pode-se questionar se é mesmo relevante a diferença entre as duas posições e se elas podem levar a resultados práticos distintos ou se, ao contrário, tratar-se-ia apenas de um desacordo linguístico e convencional. Abordaremos a questão com mais detença na Parte II, assinalando apenas que Robert Alexy defende a importância da fórmula de Radbruch, analisando e rejeitando os diversos argumentos utilizados contra ela pelos positivistas, entre os quais o da inutilidade.^[50]

Por ora, basta afirmar que nos parece compreensível que os tribunais em geral recorram à fórmula de Radbruch, quando confrontados com os problemas da justiça de transição. Com efeito, pelo princípio da separação dos poderes, os juízes não podem criar ou revogar leis, ou deixar de aplicá-las, funções que seriam exclusivas dos legisladores. Estes, por sua vez, nem sempre se debruçam sobre todas as leis do regime anterior, revogando-as expressamente de forma retroativa, podendo remanescer questões jurídicas que serão suscitadas diretamente perante os tribunais. A fórmula de Radbruch oferece um quadro mais cômodo para os tribunais, ao não considerar lei a norma injusta que não se deseja aplicar; a solução proposta por Hart exigiria dos tribunais uma liberdade que, em razão da separação dos poderes, eles consideram não possuir.

Independentemente da questão conceitual, ou de qual o fundamento de validade da norma jurídica, é inegável – como se disse sobre as relações entre direito e moral, e talvez aqui com maior razão – que o direito tem notável proximidade com a justiça, sendo sobretudo este o valor que o direito busca realizar, ainda que se possa divergir sobre o que ela significa. Pode-se dizer que o direito, a norma jurídica, sempre realiza ou alberga uma concepção qualquer de justiça. Uma pergunta sempre possível a respeito de determinada norma de direito, talvez a primeira ou a mais importante que se possa fazer, é “*esta norma é justa?*”. Por isso, mesmo um positivista como Hart assevera:

A justiça é um segmento da moral primordialmente afeto não à conduta individual, mas às formas de tratar classes de indivíduos. É isso que confere à justiça sua especial pertinência na crítica do direito e de outras instituições públicas e sociais. É a mais pública e jurídica das virtudes. [\[51\]](#)

Outro aspecto que demonstra a estreita ligação entre direito e justiça é o da *aplicação* do direito, como veremos no próximo item.

3.3. Justiça e aplicação do direito

Como vimos, a justiça possui um conceito formal – *dar a cada um o que é seu, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais* – e conteúdos materiais que são mais controversos e que dizem mais de perto com os valores morais, na medida em que estes se mostram necessários para estabelecer as noções de igualdade e desigualdade que serão utilizadas.

A regra de justiça é por si só uma regra de julgamento, sobretudo na modalidade aristotélica da justiça distributiva – a regra já se confunde ou se dirige a alguém que tem a tarefa de distribuir ou julgar. Nas nossas sociedades, a regra de justiça é cogitada inicialmente pelo legislador, ao elaborar a lei (*lato sensu*); o legislador coloca-se com certa liberdade diante da regra de justiça, podendo preenchê-la com seus valores e visões de mundo, e isso é particularmente verdade em relação ao legislador constituinte. Mas, estabelecida a regra legal, ainda será necessário aplicá-la ao caso concreto, função que cabe aos juízes.

Assim, a regra de justiça incide primeiramente na formulação da norma, mas não sai de campo quando se trata de aplicá-la. Pode-se ser justo ao fixar uma norma – por exemplo, *não matar ou não haverá homicídio se o homem agir em legítima defesa* –, mas o juiz ainda poderá ser justo ou injusto ao aplicá-las, reconhecendo a autoria de um delito ou a incidência ou não de uma excludente de antijuridicidade. Quanto à autoria, terá que lidar com questões probatórias, marcadamente empíricas mas sujeitas a dificuldades; para aplicar a excludente, com noções normativas, avaliativas, como “agressão injusta”, “moderadamente”, “meios necessários.”

Nelson Saldanha concorda que o sistema jurídico inclui um substrato de valores e uma concepção referente à justiça. Mas, nas suas palavras,

o sentir concernente à justiça, que jamais exclui sua representação ou sua imagem, refere-se geralmente à sua “aplicação”, isto é, à sua realização nas concretesas da vida. Ou seja, aos atos (ou situações) que aparecem como justos. E no plano do real, o justo está mais nas condutas das pessoas do que no dizer das normas. O que há de justo nas normas (e aqui concedemos algo à egologia) provém da intenção dos que as emitem; ou se acha, de certa forma, em potência, em relação ao que vão fazer aqueles que as cumprem ou descumprem.^[52]

Mesmo diante da norma clara, o juiz terá a tarefa de sopesar, em relação aos fatos concretos, os critérios nela estabelecidos de igualdade ou desigualdade, de *pessoas e situações*, realizando a chamada subsunção dos fatos à norma. O papel do julgador é ainda mais relevante quando a norma não é clara ou emprega conceitos imprecisos, como os *conceitos jurídicos indeterminados*, ou noções ainda mais abstratas, próximas aos valores, como o princípio da dignidade da pessoa humana.^[53]

Tanto Hart como Alexy, em campos distintos da Filosofia do Direito, introduziram a necessidade de diferenciar, num sistema jurídico, as perspectivas do

observador e do participante, o ponto de vista interno ou externo. O observador pode contentar-se com uma abordagem meramente descritiva do direito, pois ele não se envolve com os valores em questão e nem com a aplicação da norma: seriam exemplos o do historiador que descreve as instituições do direito romano ou do estudioso que analisa o direito de um país estrangeiro. Sob o ponto de vista interno, que para Hart inclui os próprios cidadãos destinatários da norma, analisa-se o direito de uma forma mais valorativa. Assim também faz o participante, noção que tem em Alexy uma abrangência menor, a englobar os encarregados da criação e aplicação das normas, tendo o juiz um papel preponderante.

Talvez o participante, em especial o juiz, como o vê Alexy, não possa contentar-se com uma visão puramente *descritiva* do direito – do que ele *é*, como faria um observador –, não podendo dispensar uma visão *normativa*, valorativa – do que o direito *deve ser*. Isso em razão da amplitude ainda considerável que lhe remanesce na aplicação da lei, como vimos, tendo que recorrer à regra de justiça para bem adequá-la às situações fáticas e por vezes concretizar valores quando a norma jurídica oferece essa abertura. Dessa forma, na aplicação do direito, mesmo com limitações, o juiz terá que lidar novamente com o arcabouço moral e político de que cogitou o legislador, em especial com a noção de justiça.

3.4. A equidade

A equidade é já tratada por Aristóteles. Significa a própria justiça, considerada não como regra geral, mas aplicada ao caso particular. É a transmutação da justiça no percurso que faz entre a regra geral e o caso concreto. Aristóteles compara-a à *régua de Lesbos*, um tipo de régua que conhecera nessa localidade, que era flexível, própria para medir rochas, adaptando-se à forma de cada uma, para que todas pudessem ser medidas.

A equidade por vezes é entendida como uma correção da regra geral de justiça, ou mesmo da lei, destinada a aparar-lhe os excessos e fazer justiça no caso concreto. É contraposta ao brocardo “*summum jus, summa injuria*”, já referido, remediando-o, entendendo-se que a aplicação estrita da regra geral ao caso concreto pode resultar em injustiça.

O positivismo triunfante do século XIX viu com desconfiança a equidade, associada ao jusnaturalismo, e buscou descartá-la como fonte formal do direito, o que se pode entrever ainda no art. 140, parágrafo único, do nosso Código de Processo Civil de 2015, que repetiu o disposto no art. 127 do Código anterior: *O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.*

Aproximação interessante faz Eros Roberto Grau quando, ao analisar os princípios muito em voga da proporcionalidade e da razoabilidade – a que ele, a nosso ver de forma correta, nega o caráter de princípios, considerando-as *pautas normativas de aplicação do direito* –, afirma que na verdade são manifestações da conhecida equidade.^[54] Como ela, manifestam-se no momento da aplicação do direito, da transição da regra abstrata para a norma de decisão do caso concreto.

Correntes da Filosofia do Direito

Parte II

1. O jusnaturalismo

1.1. Definição. Características gerais

O jusnaturalismo, também conhecido como escola ou teoria do Direito Natural, é talvez a corrente mais antiga da filosofia do direito. Alguns autores consideram Platão o precursor da ideia de direito natural.^[55]

Apesar de a denominação “jusnaturalismo” ser hoje pouco utilizada e por vezes associada a uma doutrina ultrapassada, a corrente foi revitalizada sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, com autores importantes como Radbruch, que era positivista antes do conflito, Leo Fuller e John Finnis. Existe ainda alguma similitude entre certas teses e características do jusnaturalismo e doutrinas modernas como as de Ronald Dworkin, Robert Alexy e Gustavo Zagrebelsky.^[56] Talvez por isso alguns considerem o jusnaturalismo e os últimos autores citados como fazendo parte das “correntes moralistas” da Filosofia do Direito.^[57]

O jusnaturalismo baseia-se numa dualidade – criticada por Kelsen – entre o *direito natural* ou as leis naturais e o direito positivo e as leis positivas. Esse direito natural existiria para além do direito positivo, isto é, para além das leis escritas, das ordens do soberano ou mesmo dos costumes observados numa dada comunidade. Em caso de conflito entre um e outro, deveria prevalecer o direito natural, pois conteria as regras próprias da *essência* humana e da vida social. O conflito entre direito positivo e direito natural é frequentemente ilustrado com a tragédia Antígona, de Sófocles. Diante do decreto do rei Creonte, que privava seu irmão revoltoso do sepultamento, Antígona argumenta que leis religiosas há muito observadas prescreviam o direito a um funeral digno.

Como dito, o jusnaturalismo experimenta uma renovação ao final da Segunda Guerra Mundial, em razão dos regimes nazista e fascistas marcadamente injustos que, no entanto, haviam operado através de sistemas legais, com leis aprovadas pelos parlamentos. A possibilidade da *lei injusta* tornou-se palpável, com autores como Radbruch – que se assumia positivista antes da guerra – aderindo em certa medida ao jusnaturalismo como forma de cautela contra os horrores do nazismo.^[58]

Aqui, contudo, cabe destacar que a associação do positivismo jurídico ao nazismo dá margem a dúvidas. Enquanto autores como Perelman admitem-na, outros a rejeitam, tendo em vista que os nazistas não professavam o positivismo jurídico, mas uma espécie de moralismo avesso às garantias individuais, segundo o qual o juiz alemão devia considerar o direito e a moral nazista uma só coisa.^[59]

As teorias do direito natural através dos tempos apresentam semelhanças, mas também diferenças. Assim, pode-se falar de um direito natural inspirado pela religião, em que as regras transcendentais, isto é, que estão além (e acima) do direito positivo, teriam um caráter religioso, sendo ditadas por Deus. Temos também correntes no

jusnaturalismo em que as leis naturais seriam propriamente naturais, comandadas pela natureza biológica do homem e pelas principais características do seu mundo físico. Por fim, há um direito natural de base racional, em que as leis naturais seriam impostas pela razão; a este último grupo pertence certamente o jusnaturalismo moderno, aquele formulado a partir de fins da Idade Média e, após, na Idade Moderna e no contexto do Iluminismo, com autores como Hobbes, Locke e Rousseau.

Nesse ponto, convém sublinhar a pretensão de universalidade do direito natural. As leis naturais valeriam para toda e qualquer sociedade e estariam para além das culturas e das convenções. Tanto na forma de leis divinas, como naturais ou racionais, todas elas postulam a universalidade. Com efeito, como é corrente na antropologia, o que é natural do homem é universal, compartilhado por todas as culturas, enquanto o que é cultural é particular e não se reproduz em todos os tempos e lugares. O mesmo vale para a razão, que seria comum aos homens e, por isso, teria também o atributo da universalidade.

No jusnaturalismo, as leis naturais coincidiriam também com a virtude da justiça. Sem observância das leis naturais, o direito positivo acabaria por infringir o próprio valor da justiça. A justiça teria em comum com as leis naturais a universalidade, pois também se impõe como uma ideia natural ou racional, inata ao homem, que pode ser conhecida e deve ser observada tanto do ponto de vista moral quanto pelas leis positivas. Também a noção de bem comum, como finalidade intrínseca do direito, coincidente com a moral, está presente no jusnaturalismo, sobretudo nos escritos de São Tomás de Aquino.

1.2. Principais autores

Platão (428-348 a.C.), como dito, é considerado um precursor do direito natural. A filosofia política e jurídica que expressa nas obras *A República* e *As Leis* manifesta sua inquietação com o caos político das cidades-estados gregas. Platão considera que existem modelos ou paradigmas de organização política e jurídica da sociedade que estão além da vontade humana e das convenções, e podem ser conhecidos através da razão e implementados na vida social. Ele critica as concepções democráticas então existentes, de modo que o filósofo liberal Karl Popper, do século XX, vê o seu direito natural como tentativa de recriar um “*modo de vida social ‘natural’, isto é, tribal e coletivista.*”^[60]

Aristóteles (384-322 a.C.) é em geral apresentado como tendo uma abordagem mais empírica, em contraste com o idealismo platônico, mas “*também compartilha a crença em que há uma certa estrutura ontológica na base da natureza humana e do cosmo.*”^[61] Mesmo rejeitando o método platônico de buscar essências puras, e baseando seu raciocínio na observação, ele continua a buscar a *natureza* essencial das coisas. Para Aristóteles, a essência é o “*fim*” ou função de cada coisa, e o fim é o “bem”, de maneira que sua visão do mundo e do homem é teleológica. A teoria da justiça de Aristóteles foi ventilada na Parte I, sendo de destacar aqui que ele faz a distinção entre “*o que é natural e o que é puramente legal(...) O que é puramente legal é tudo que, em princípio, pode ser indiferentemente de uma maneira ou de outra, mas que cessa de sê-lo quando a lei dispôs.*”^[62]

Cícero (106-43 a.C.), em Roma, baseando-se na filosofia estoica de uma lei natural universal, formula com rigor a ideia de uma lei de conduta baseada na natureza e na racionalidade, superior ao direito positivo. Diz que “*a verdadeira lei é a razão superior em conformidade com a natureza*” e que “*o direito é a razão mais alta, inculcada na natureza, que determina o que deve ser feito e proíbe seu contrário.*”^[63]

Santo Agostinho (354-430), na transição do classicismo para a Idade Média, faz uma síntese da filosofia platônica com a fé cristã, transformando o direito natural num *direito natural teológico*. Enquanto para os estoicos, as leis da natureza eram forças impessoais e racionais, para Agostinho a lei eterna era a razão e a vontade do Deus cristão. Ele argumentava que “*se as leis do Estado não estiverem em harmonia com o direito e a justiça naturais, não terão o caráter de verdadeiras leis nem haverá, no caso, um Estado verdadeiro.*”^[64]

São Tomás de Aquino (1225-1274) é tido como havendo “cristianizado Aristóteles.” Da mesma forma que o filósofo grego, São Tomás distingue comportamentos que são errados porque proibidos pelas leis da natureza, como o

homicídio, e outros que o são por mera determinação da lei positiva. Relevante também é a concepção tomista do Estado, aduzindo que “*uma vida comum não poderia existir, a menos que houvesse alguém que detivesse o controle, encarregando-se do bem comum.*”^[65]

Na Idade Moderna, sobretudo a partir da Reforma e das guerras de religião, a visão religiosa do mundo entra em crise e os filósofos e juristas passam a buscar um fundamento laico e racional para a existência do Estado e do direito. Surgem então teorias do direito natural racional, em que as leis naturais decorreriam da razão humana, como em Hugo Grócio e Pufendorf. No campo mais abrangente da filosofia política, mas com grande influência sobre o direito, deve-se destacar a *teoria do contrato social* e seus principais autores Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), além de Kant (1724-1804). Em apertada síntese, tal teoria baseia-se na dualidade *estado de natureza x estado civil ou político*, fornecendo, mais que uma explicação histórica, um fundamento de legitimação para o Estado moderno; sobretudo em Locke, surge a ideia de *direitos naturais individuais* já existentes no estado de natureza e que caberia ao Estado tutelar.

O jusnaturalismo restou obscurecido durante todo o século XIX, em que prevaleceram as concepções positivistas, apresentando alguma recuperação a partir do início do século XX e após a Segunda Guerra Mundial. Já mencionamos o filósofo alemão Gustav Radbruch (1878-1949) e voltaremos logo adiante à sua célebre fórmula de que “*a lei extremamente injusta não é lei.*”

Leo Fuller (1902-1978) foi professor da Universidade de Harvard e publicou em 1964 o seu livro “*The Morality of Law*”, chegando a travar com Hart um conhecido debate. Para Fuller, para ser eficaz o direito deve atender na sua estrutura algumas regras que ele considera uma forma de “moralidade interna do direito.” Alguns desses aspectos seriam: a própria existência da “*rule of law*”; a publicidade da lei; sua clareza; sua não-retroatividade, não-contradição, etc. O direito natural para Fuller exibiria assim um aspecto procedimental.

John Finnis (1940) retoma aspectos das obras de Aristóteles e São Tomás de Aquino e, de forma relevante, a distinção entre regras naturais que se impõem à legislação e regras puramente legais. Esclarece que o direito romano denominava *ius gentium* essas regras inarredáveis da convivência, encontráveis em todos os sistemas jurídicos, que no direito moderno seriam “*os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas*” (*Statute of International Court of Justice*, art. 38), *ius cogens erga omnes*, “*a mais alta lei*” ou “*direitos humanos fundamentais.*” Aduz ainda que para São Tomás de Aquino, tais aspectos são referidos como conclusões ou implicações dos princípios morais mais elevados. Na *common law*, por sua vez, a infração a tais regras consistiriam *mala in se*, distintos de

mala prohibita – coisas erradas em si mesmas, distintas das que são erradas porque foram proibidas pela lei positiva.^[66]

Como aspectos de suma importância que unem os diversos autores mencionados, trataremos adiante, em tópicos separados, da *tese da conexão ou vinculação entre direito e moral* e da questão das *leis injustas*.

1.3. Tese da conexão ou vinculação entre direito e moral

Como já tivemos oportunidade de abordar na Parte I, enquanto o positivismo adota a *tese da separação* entre direito e moral, o jusnaturalismo e as correntes ditas moralistas adotam a *tese da conexão* ou vinculação entre as duas realidades.

A conexão pleiteada pelo jusnaturalismo é a conceitual, isto é, direito e moral distinguem-se em parte, mas não logram diferenciar-se completamente, e isso no plano do próprio conceito. Essa vinculação estaria presente até mesmo no aspecto linguístico, onde a palavra *direito* também pode ter uma conotação moral. Alexy assevera que seria absurdo pensar numa constituição cujo primeiro artigo dissesse “X é uma república soberana, federal e injusta” e que haveria redundância na disposição constitucional de que “X é um Estado justo.”^[67]

O direito não lograria se desvincular completamente da noção moral de justiça, o que leva o jusnaturalismo a negar o caráter jurídico de determinadas leis injustas, segundo o adágio “*lex iniusta non est lex*”. Para Alexy, o direito sempre apresenta uma “*pretensão à correção*” – e correção aqui entendida em sua acepção propriamente moral –, mesmo que não a realize, como no caso das leis ou regimes jurídicos injustos. Para o autor alemão, enquanto elemento de uma conexão conceitual ou classificatória, a pretensão à correção não teria tanta relevância, até porque, como acabamos de ver, o direito pode descumpri-la. Seu papel seria mais relevante ao revelar uma “conexão qualificadora”, capaz de provocar uma avaliação crítica do direito que não albergue de forma suficiente a pretensão à correção, considerado então como um direito defeituoso. Essa mesma pretensão à correção é que, diante da textura aberta do direito e dos casos duvidosos, levaria à cogitação do aplicador sobre os princípios e os traria para dentro do próprio conceito de direito.^[68] Ainda segundo Alexy, “a pretensão à correção leva a uma dimensão ideal, necessariamente vinculada ao direito.”^[69]

Trata-se da tese alexyana da “natureza dual” do direito, que teria uma dimensão real, como direito positivo, e uma dimensão ideal representada pela pretensão à correção. A pretensão à correção dá lugar a um conceito não-positivista de direito que se desdobra em cinco aspectos, o “*pentágono da dimensão ideal*”: i) a fórmula de Radbruch; ii) a tese do caso especial; iii) a ideia de direitos humanos; iv) a ideia de democracia deliberativa; e v) a teoria dos princípios.^[70]

O positivismo não nega, como vimos na primeira parte, a estreita relação entre direito e moral, mas entende que essa conexão é histórica ou contingencial, isto é, o direito pode albergar, e de fato em geral o faz, princípios e normas morais, mas não de forma necessária, podendo-se conceber um direito que ofenda regras de moral ou de justiça. Segundo Kelsen, de fato, o direito pode ter qualquer conteúdo e mesmo assim continua a ser direito.

Para os jusnaturalistas, o direito, em certa medida, confunde-se conceitualmente com a moral. Mas apenas “em certa medida”, porque as duas esferas continuam possuindo certa autonomia. Com efeito, a maioria dos jusnaturalistas endossa a fórmula de Radbruch e só nega caráter jurídico às normas positivas que forem “extremamente injustas”, retirando o caráter de juridicidade somente daquelas normas cuja injustiça seja intolerável. Tais autores adotam uma postura de certa forma minimalista, reconhecendo a conexão conceitual, mas dentro de limites estreitos. Isso se pode constatar nos autores jusnaturalistas quando passam a enumerar as leis naturais que não poderiam ser olvidadas pelos sistemas jurídicos positivos. Trata-se de aspectos básicos, nucleares da existência humana, consistentes em geral nas regras de abstenção que impedem a violência e a fraude.

O próprio Hart, um dos maiores positivistas do século XX, admite que o direito positivo tem sempre um “*conteúdo mínimo de Direito Natural*.” Para ele, haveria uma conexão racional entre alguns “fatos naturais” e o conteúdo das normas jurídicas e morais.^[71] Tais fatos ou circunstâncias da existência humana, capazes de conferir esse conteúdo mínimo não só ao direito como à moral, de forma universal, seriam para Hart os seguintes: i) *a vulnerabilidade humana*; ii) *a igualdade aproximada*; iii) *o altruísmo limitado*; iv) *recursos limitados*; v) *compreensão e força de vontade limitadas*.

A título de exemplo da reflexão de Hart, tomemos a “igualdade aproximada” entre os homens. Ele assevera que a desigualdade física entre os homens não é de monta a que alguns possam se considerar, nesse aspecto, superiores a ponto de dispensar o sistema de abstenções mútuas adotado pelo direito e pela moral.^[72]

Por sua vez, John Finnis, jusnaturalista contemporâneo, estabelece o que seriam os bens humanos básicos, que para ele apresentam uma natureza objetiva e constituem fins em si mesmos. Esses bens seriam: a vida, o conhecimento, o jogo (o aspecto lúdico da existência humana), a experiência estética, a sociabilidade e amizade, a razoabilidade prática e a religiosidade. Eles levariam à definição das condutas que são moral e juridicamente aceitáveis. Os procedimentos e instituições do direito, segundo Finnis, estão a serviço de propósitos substantivos tais como: a restrição da violência, roubo e fraude, a recuperação das coisas ilegalmente tomadas de seus legítimos proprietários e possuidores, e das perdas erroneamente impostas, proteção dos bens intangíveis, tais como a reputação contra a difamação indevida, e dos imaturos, como os mentalmente incapacitados e outras pessoas vulneráveis contra a exploração sexual ou outras formas de exploração e assim por diante.^[73]

1.4. A questão das leis injustas e a fórmula de Radbruch

O jusnaturalismo não só prevê e respeita o espaço próprio do direito positivo, mas ainda o adorna com um dever de obediência derivado da moral. Por outro lado, essa obrigatoriedade é “presumível e anulável”, isto é, pode ser afastada quando a lei positiva colidir de forma suficientemente clara com os bens humanos básicos pressupostos e princípios e normas morais básicas.^[74]

Na segunda metade do século XX, Radbruch também buscou conciliar a necessidade de segurança jurídica, representada pela lei positiva, com o imperativo da justiça. Fê-lo da seguinte forma:

O conflito entre a justiça e a segurança jurídica pode ser resolvido da seguinte maneira: o direito positivo, assegurado por seu estatuto e por seu poder, tem prioridade mesmo quando, do ponto de vista do conteúdo, for injusto e não atender a uma finalidade, a não ser que a contradição entre a lei positiva e a justiça atinja um grau tão insustentável que a lei, como “direito incorreto”, deva ceder lugar à justiça.^[75]

O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha sediado em Karlsruhe, no pós-guerra, como já mencionado, reconheceu a nulidade *ab initio* do 11º Decreto da Lei de Cidadania do Reich, que privava da cidadania alemã os judeus emigrados. Nesta decisão, podemos dizer que foi adotada a fórmula de Radbruch:

O direito e a justiça não estão à disposição do legislador. A ideia de que um legislador constitucional tudo pode ordenar a seu bel prazer significaria um retrocesso à mentalidade de um positivismo jurídico desprovido de valoração, há muito superado na ciência e na prática jurídicas. Foi justamente a época do regime nacional-socialista na Alemanha que ensinou que o legislador também pode estabelecer a injustiça. Por conseguinte, o Tribunal Constitucional Federal afirmou a possibilidade de negar aos dispositivos “jurídicos” nacional-socialistas sua validade como direito, uma vez que eles contrariam os princípios fundamentais de justiça de maneira tão evidente que o juiz que pretendesse aplicá-los ou reconhecer seus efeitos jurídicos estaria pronunciando a injustiça, e não o direito.

O 11º Decreto infringia esses princípios fundamentais. Nele, **a contradição entre esse dispositivo e a justiça alcançou uma medida tão insustentável** que ele foi considerado nulo *ab initio*. [...] ^[76]

A fórmula de Radbruch é considerada um clássico do não positivismo e poderia ser assim resumida: “*a lei extremamente injusta não é lei.*”

Um positivista como Hart – que não prescreve obediência à lei positiva, adotando uma teoria que se quer apenas *descritiva* (e não *normativa*) do direito –, entende correto dizer num caso que tal: “*isto é lei, mas é muito injusta para ser aplicada.*”^[77]

Existe dúvida se uma das alternativas – que guardam estreita relação com a tese da separação ou da conexão entre direito e moral – pode ser considerada mais correta do ponto de vista analítico ou conceitual, ou se a questão apenas admitiria uma solução normativa, isto é, que considere a melhor adequação ou conveniência de uma delas.^[78]

Alexy enumera e discute as diversas objeções dos positivistas contra a fórmula de Radbruch, como os argumentos linguístico, da clareza, da efetividade, da segurança jurídica, do relativismo, da democracia, da inutilidade e da honestidade.^[79]

Tais argumentos representam as próprias teses do positivismo jurídico em geral, que o contrapõem ao jusnaturalismo. Alguns dos argumentos são rebatidos por Alexy com a alegação de que a fórmula de Radbruch é uma espécie de “tese fraca” do jusnaturalismo, pois somente em caso de injustiça extrema é que permitiria afastar a aplicação da lei positiva – de modo que não ofenderia de forma grave, por exemplo, a segurança jurídica e a democracia, compensando-se a pequena instabilidade trazida com a maior preocupação com a justiça.

O argumento da efetividade, brandido pelos positivistas, assevera que diante do sistema jurídico injusto, como o nazista, um conceito de direito não positivista como o de Radbruch não teria o condão de alterar a situação política e jurídica. Alexy responde, e nesse ponto concordamos com ele, que o conceito de direito não positivista pode desestimular determinadas autoridades, como juízes, a aplicarem a legislação injusta, pois poderão ser julgados quando o regime autoritário cair, as leis em que se tenham baseado vindo a ser declaradas nulas e não lhes servindo como defesa; seria um “efeito de risco.”

O argumento da inutilidade, por sua vez, sustenta que, para se remediar situações que tenham sido produzidas por leis injustas, ou se punirem autores de atos reprováveis que tenham atuado com base nessas leis, não é necessário um conceito de direito como o de Radbruch – bastaria que os legisladores do novo regime aprovassem leis retroativas. Aqui entra também o argumento da honestidade, pois segundo os positivistas seria mais honesto reconhecer a retroatividade de determinados provimentos do que a disfarçar sob o procedimento da fórmula – considerando que a lei não é lei.

Parece-nos, como já afirmado na Parte I, que a fórmula de Radbruch é relevante nos casos da justiça de transição, quando da superação de regimes autocráticos e abusivos por ordenamentos democráticos. Os tribunais em geral não têm o poder de revogar leis ou deixar de aplicá-las; a possibilidade de negar o caráter de lei ou de direito às leis consideradas extremamente injustas é uma forma de superar tais injustiças nos casos que lhes forem submetidos. Do contrário, os juízes teriam que esperar a atuação legislativa, que nem sempre ocorre e que pode não dar conta de todas as situações constituídas sob o regime anterior. Sem falar, como lembra Alexy, quando se trate de processos criminais contra agentes do regime anterior, que no Direito Penal vigora o princípio da irretroatividade da lei incriminadora.

1.5. Fundamentos epistemológicos

Por epistemologia, entende-se “o conhecimento do conhecimento”. Podemos dizer que o tecido de uma poltrona é da cor grená e a afirmação traduz um certo conhecimento. A epistemologia está um nível acima e se pergunta “*posso mesmo saber se a poltrona é grená?*”, “*o que é uma cor?*” ou, ainda, “*o que é conhecer algo?*”. Na literatura anglo-saxã sobre a filosofia moral e do direito será comum a distinção entre questões de primeira ordem (*first order questions*), como aquelas da ética normativa (*como devemos viver? qual a ação moralmente correta?*) e questões de segunda ordem (*second order questions*) que possuem justamente um caráter epistemológico, como aquelas próprias da chamada *metaética*, como, por exemplo, se podem ser estabelecidas verdades no campo da moral.

Ora, as diversas correntes da Filosofia do Direito adotam diferentes premissas epistemológicas, e esse aspecto revela muito das características de cada uma. Elas divergem sobretudo em relação à *epistemologia da moral ou dos valores* ou *metaética*, acima referida. Discute-se se o conhecimento ético ou moral é possível, isto é, se as questões morais comportam um conhecimento racional e se, no limite, existem respostas certas ou erradas para dilemas éticos. Exemplificamos, quando tratamos dos fundamentos da moral na Parte I, com a questão da eutanásia. Podemos ter um posicionamento diante dessa questão: *é certo*, *é errado*, etc. No nível epistemológico a pergunta seria não mais se isso é certo ou errado mas, por exemplo, se existe mesmo uma resposta correta para a questão ou como é possível alcançá-la. Para o relativismo moral ou axiológico, por vezes tratado como *não-cognitivismo*, o conhecimento racional não é possível no campo da ética, dos valores; estes constituem questão de preferência, subjetiva, que chega a tocar a esfera emocional, como no *emotivismo* de Alfred Jules Ayer. Essa a postura que predomina entre os positivistas jurídicos. O jusnaturalismo, contudo, adota em geral o objetivismo ou realismo moral, ou ainda cognitivismo moral, que acredita na existência de verdades morais.

O jusnaturalismo tem suas origens na Grécia e de alguma forma comunga da concepção platônica da verdade. A concepção platônica do mundo pode ser resumida na compreensão de que *existe* a verdade, que ela está oculta, mas os homens podem atingi-la através do conhecimento e da razão. Esse é o significado do mito da caverna e da cisão entre o mundo sensível e inteligível. Já se considerou que Platão, mais que Hegel ou Schmitt, foi o verdadeiro adversário de Kelsen.^[80] Com efeito, Kelsen critica o dualismo existente na visão platônica, que teria passado à Filosofia do Direito com o jusnaturalismo.

A nosso ver, não é errôneo associar o jusnaturalismo ao platonismo, sobretudo sob o aspecto da dicotomia que instaura entre o direito natural e o direito positivo, um direito natural verdadeiro e perene, mas que se faz ausente no direito positivo, quando

este o contrária, ou que sob ele se oculta e lhe confere o fundamento. Da mesma forma, ao postular a *teoria da conexão* entre direito e moral, admite a existência de uma moral objetiva, de um *justo* que pode ser conhecido, com validade *intersubjetiva*. Assim, podemos considerar que o jusnaturalismo adere a uma espécie de objetivismo ou realismo moral, distanciando-se do relativismo axiológico.^[81]

Os autores jusnaturalistas entendem que existe algo como o bem e a justiça, e não só isso, que eles podem ser conhecidos pela razão e impõem-se à conduta humana como obrigação moral. Assim, Zagrebelsky afirma ser “*próprio, com efeito, de qualquer visão jusnaturalista autêntica assumir a tríade: verdadeiro, justo, obrigatório.*”^[82]

Assim, para o jusnaturalismo, a flagrante ou extrema injustiça de uma norma pode ser detectada. Também, como vimos, existem condições humanas básicas que implicam a objetividade e validade universal de certos valores, por exemplo, a não-violência. Esse objetivismo às vezes é mínimo, refere-se a questões-limite em que o que é justo ou injusto, certo ou errado impõe-se à consciência humana; mas, mesmo assim, a existência e o conhecimento desses valores são afirmados.^[83]

2. O positivismo jurídico

2.1. Definição. Características gerais

A definição do que seja o positivismo jurídico não é fácil. Há aspectos que são enfatizados mais por determinados autores do que por outros. Alf Ross elenca seis maneiras de conceber o positivismo jurídico:

- a) A distinção entre direito e moral;
- b) A concepção *imperativista* das normas jurídicas, ou seja, a convicção de que as normas jurídicas consistem em *ordens* dirigidas por alguns seres humanos (os legisladores, em sentido amplo) a outros (os súditos);
- c) A ideia de que o direito é um conjunto de normas que se aplicam por meio da força;
- d) A concepção mecanicista da função judicial e a ideia de que os juízes aplicam, mas não criam o direito;
- e) A ideia de que todo ordenamento jurídico deve ser obedecido;
- f) A negação da existência do direito natural como um direito anterior e superior ao direito positivo.^[84]

Nem todos os autores, como dito, defendem todas essas teses, sendo que o próprio Ross parece concordar apenas com a primeira e a última.

Leslie Green afirma que o positivismo jurídico “*é a tese de que a existência e conteúdo do direito dependem de fatos sociais e não dos seus méritos*”^[85]. Baseia-se, pois, na conhecida lição de Austin, um dos precursores do positivismo, de que “*a existência do direito é uma coisa, seu mérito ou demérito, outra*”^[86].

Campbell, por sua vez, assevera:

Na teoria do direito, o positivismo jurídico é geralmente entendido como a visão de que o conceito de direito pode ser elucidado sem referência à moral e de que é dever dos juízes determinar o conteúdo e aplicar a lei sem recorrer a julgamentos morais.^[87]

Essa última definição aproxima-se do que seria o senso comum entre os juristas a respeito do positivismo jurídico. Além da referência à legislação, como veiculando todo o direito, é muito presente a concepção de que os juízes deveriam aplicar as leis de forma objetiva, sem espaço para considerações subjetivas ou de ordem moral que não estejam contidas na norma.

Contudo, o que já denota a complexidade do tema, alguns positivistas modernos rejeitam o que chamam de “positivismo ideológico”, na terminologia de Bobbio, isto é, rejeitam a tese “e” elencada acima, de que o ordenamento jurídico deve sempre ser obedecido.

2.2. Evolução histórica

O positivismo jurídico não é apenas uma corrente de pensamento filosófico sobre o direito. Ele é também, como deixa claro Norberto Bobbio^[88], uma realidade do mundo jurídico e político que se impõe a partir das revoluções liberais.^[89] Ocorre a partir daí uma centralização maior dos Estados – que já vinha acontecendo desde fins da Idade Média – e também uma maior centralização da produção jurídica, com a promulgação, sobretudo, dos códigos civis, como o famoso *Code Napoléon* de 1804, na França.

Durante a Revolução Francesa, são constantes as manifestações dos revolucionários sobre a necessidade de condensar o direito num código simples e claro, como imperativo político que derivava do reconhecimento dos direitos do homem e do cidadão. Foi no calor da revolução que os deputados comprometeram-se com a ideia do Código Civil, cuja redação incumbiu primeiramente a Cambacérès e passou depois à responsabilidade de Portalis, um liberal moderado que chegou a ser preso sob o governo de Robespierre. O *Code Napoléon* foi promulgado em 1804 e terá influência em todo o mundo, dando início à era em que floresceram a prática e as principais concepções do positivismo jurídico. Bobbio não cansa de enfatizar que o positivismo jurídico, para além de uma filosofia do direito, é resultado do processo histórico da codificação.^{[90],[91]} Atualmente, a ideia de condensar o direito e simplificá-lo como forma de garantia ainda pode ser encontrada em Luigi Ferrajoli, que defende, em relação ao direito penal, uma “reserva de código”.^[92]

Pode parecer surpreendente, mas nesse processo fica claro que tanto o contratualismo como o jusnaturalismo, que eram as filosofias política e jurídica dominantes no cenário pré-revolucionário, estiveram de certa forma ligados ao surgimento do positivismo jurídico. A ideia da codificação surge como concretização dos direitos naturais universais, sua fixação clara e definitiva, para que não mais fossem olvidados na organização da sociedade. Tal conexão fica clara na redação do art. I do projeto preliminar do Código Civil francês, depois suprimido, que declarava: *"Existe um direito universal e imutável, fonte de todas as leis positivas: não é outro senão a razão natural, visto esta governar todos os homens."*

Os autores iluministas criticavam a discricionariedade dos juízes do *Ancien Régime*, a arbitrariedade de suas decisões com base em um direito não codificado, oriundo do direito romano e de provimentos medievais de origem variada, enfim, proveniente de fontes diversas, diferentemente do que ocorre hoje.

A codificação, pois, está ligada à afirmação dos direitos individuais, que eram considerados pelo iluminismo como “direitos naturais”, sendo o jusnaturalismo uma das facetas desse movimento.^[93]

2.3. Principais autores

Como Filosofia do Direito, as origens do positivismo jurídico podem ser buscadas na Grécia antiga, com os sofistas e sua concepção relativista e convencionalista do que são a justiça e o direito, contraposta às teses de Sócrates, Platão e Aristóteles, que são considerados precursores das teorias do direito natural. A denominação *direito positivo*, em oposição ao direito natural, apareceu segundo Bobbio primeiramente na filosofia medieval.^[94] Segundo o mesmo autor, a denominação da escola não teria relação com o positivismo sociológico de Comte ou com o positivismo filosófico – derivando mesmo da expressão *direito positivo*.

Autores da filosofia política moderna como Hobbes e Hume, a quem Green atribui o caráter de convencionalistas, podem ser considerados igualmente precursores do positivismo jurídico.^[95]

Contudo, a escola tem sua formulação mais moderna e explícita nos trabalhos de Jeremy Bentham (1748-1832) e, sobretudo, do já referido John Austin (1790-1859), que adotou, modificou e popularizou as ideias do primeiro. Eles representam o *positivismo imperativista*, segundo o qual o direito e a lei são *ordens* ou *comandos* emanados do *soberano*.

Hans Kelsen (1881-1973) é talvez o autor moderno mais importante do positivismo jurídico. Ele rejeita alguns aspectos do positivismo imperativista de Austin, sobretudo a concepção da norma jurídica como mero comando do soberano. Considerando tal concepção insuficiente para explicar a complexidade do direito, ele propõe o que ficou conhecido como positivismo *normativista*. Para Kelsen, a norma jurídica não pode ser entendida senão como inserida em um *sistema* escalonado de normas, em que o fundamento de validade de uma norma reside em uma norma superior e assim sucessivamente, até chegarmos à *norma básica ou fundamental* (*Grundnorm*), que é a norma superior do sistema, cuja validade é pressuposta. Voltaremos ao tema no item 2.5.1 abaixo.

Em sentido contrário à visão de Bobbio de que o “positivismo jurídico” não deriva do positivismo sociológico ou filosófico, talvez devamos reconhecer que o positivismo jurídico de matriz kelseniana está, sim, ligado ao positivismo filosófico do Círculo de Viena. Esse grupo de filósofos sustentava o *positivismo lógico*, corrente filosófica que se debruça sobre o significado e as condições da verdade, repelindo como não-científica boa parte das chamadas ciências humanas, pois permeadas por valores morais. Parece-nos que Kelsen insere-se nesse contexto, esforçando-se por construir uma ciência jurídica rigorosa que afaste na sua formulação os valores morais e políticos.

Outro autor de grande importância para o positivismo jurídico moderno é o inglês H.L.A. Hart (1907-1992), a que já fizemos referência ao longo deste trabalho e que influenciou fortemente a filosofia jurídica de língua inglesa. Seu positivismo inclui interessantes elementos sociológicos que o distinguem da teoria kelseniana, como sua “norma de reconhecimento”, sobre a qual discutiremos abaixo. Hart rejeita também o positivismo *imperativista* de John Austin.

Por fim, podemos lembrar, por sua importante contribuição ao direito, o filósofo italiano Norberto Bobbio (1909-2004), segundo o qual o positivismo jurídico pode ser de três tipos:

- Um certo modo de abordar o estudo do direito;
- Uma certa teoria do direito;
- Uma certa ideologia do direito.^[96]

Como modo de abordar o direito, o positivismo teria um caráter epistemológico, seria um modo de conhecer o direito. A principal característica aqui seria o propósito de realizar uma abordagem científica do direito, definir o que o direito *é*, e não o ele que *deve ser*. Essa abordagem científica quer-se avaliativa – o positivista nesse caso despe-se de seus valores pessoais, de sua avaliação sobre o direito, limitando-se a descrevê-lo. Emite sobre as normas um “juízo de validade” e não um “juízo de valor.” Fala-se de uma abordagem *descritiva* do direito, contraposta a uma abordagem *normativa* ou prescritiva.

Como teoria do direito, segundo a exposição de Bobbio, o positivismo objetiva – a partir também dos postulados epistemológicos acima – construir um todo coerente sobre a validade e aplicação das normas, definindo as fontes, a hierarquia e as relações entre elas, os procedimentos para lidar com incompletudes e antinomias do ordenamento jurídico, etc.

Por fim, como *ideologia*, o positivismo exprime uma *forma de querer* o direito. Não se trataria apenas de enunciar o direito, como no caso da abordagem epistemológica, mas de defender uma compreensão do direito a partir de um juízo avaliativo, do que ele *deve ser*. Aqui, o positivista defenderia que o direito deve ser unicamente o direito positivo, porque, por exemplo, isso traz mais segurança jurídica, é consentâneo com a democracia, evita a subjetividade do juiz, etc. Esse positivismo ideológico – atribuído por vezes aos precursores Bentham e Austin – pode aparecer com uma roupagem moderna no chamado *positivismo ético* ou *normativo*, defendido por autores como Tom Campbell e Jeremy Waldron.^[97] Abordaremos esses pontos mais abaixo, no item 2.6.

Parte dos positivistas modernos adota a perspectiva epistemológica, insistindo em que a enunciação do que é o direito não implica num *dever de obediência* às normas jurídicas, como veremos melhor adiante.

2.4. Principais teses do positivismo jurídico

Partindo da definição já citada de Green, de que o positivismo jurídico “*é a tese de que a existência e conteúdo do direito dependem de fatos sociais e não dos seus méritos*”, temos o que nos parecem ser as duas principais teses dessa escola.

2.4.1. A tese do fato social ou das fontes sociais do direito (social thesis)

Segundo esse postulado, o direito é um *fato social* e pode ser identificado numa sociedade de forma objetiva. Podemos falar, assim, historicamente, do que era o direito na Grécia ou em Roma e, similarmente, podemos descrever o que é o direito na nossa sociedade ou em outra sociedade contemporânea.

Por ser uma construção social, o direito pode encontrar suas fontes definidoras em fatos e instituições sociais, como a legislação, os precedentes judiciais, até mesmo os costumes. São as *fontes sociais* do direito. Dworkin, ao demarcar seus posicionamentos em relação ao positivismo jurídico, afirma que para essa corrente o direito é uma “questão de fato”. Assim, para saber qual a velocidade máxima permitida nas estradas de nosso país, perguntaríamos pela existência de uma norma específica, inserida num diploma legislativo. Esse raciocínio estaria ligado ao que Hart chamou de “regra de reconhecimento”, tratada adiante, e que Dworkin, ainda polemizando, chamou de “teste de pedigree”, isto é, a pesquisa em busca da origem ou da fonte autorizada para emitir as normas. Dworkin associa o positivismo ainda a uma ideia *convencional* do direito, convenção esta que autorizaria determinadas fontes. ^[98]

Assim, a tese das fontes sociais exclui a dependência do direito de leis naturais e de postulados morais do que seja certo ou errado, justo ou injusto, de forma que está ligada à outra tese fundamental do positivismo, que veremos a seguir, da separação entre direito e moral. Com efeito, os argumentos *convencionais* mencionados por Dworkin têm o efeito imediato de afastar a autonomia dos juízos individuais, de natureza moral, que possam ser formulados pelos juízes.

2.4.2. A tese da separação entre direito e moral (separation thesis)

Essa tese já foi abordada em tópicos precedentes, referentes às relações entre direito e moral, aos quais remetemos o leitor (*Parte I*). Segundo ela, para o positivismo jurídico, embora se admitam as muitas conexões entre direito e moral, elas seriam contingenciais, históricas, mas não conceituais. O conceito de direito não dependeria de uma consideração moral qualquer, como o fato de ser ou não justo, bom, conveniente, etc.

Por isso, a *fórmula de Radbruch* é incompatível com os postulados positivistas e, sobretudo, com a tese da separação, pois em alguma medida, mesmo que diminuta, reconhece a vinculação conceitual entre direito e moral, ao negar que *leis extremamente injustas* possam ser consideradas leis.

Green minimiza a importância da tese da separação na conceituação do positivismo jurídico. E o faz por reconhecer que os positivistas admitem inúmeras e relevantes relações entre direito e moral, rejeitando apenas que a lei dependa, para sua existência, de seus méritos (morais ou de outra ordem).^[99] Quanto às relações entre direito e moral, admite que são compatíveis com o positivismo diversos postulados comuns ao jusnaturalismo e enumera três aspectos que considera relevantes: i) o direito necessariamente lida com problemas morais; ii) necessariamente, o direito inclui um apelo moral ou tem de si próprio uma imagem moral, mesmo que seja na prática falível do ponto de vista moral (sublinhamos a proximidade dessa afirmação com a *pretensão à correção* de Alexy); iii) o direito tem, necessariamente, uma aptidão à justiça, virtude mais próxima de suas considerações, como já indicamos na Parte I ao tratar das relações entre direito e justiça.

2.5. Outras questões relevantes

2.5.1. A questão da norma fundamental

Aspecto relevante do positivismo jurídico, objeto sobretudo das análises de Kelsen, mas também de Hart, é o da norma fundamental.

Kelsen, como vimos, defende a ideia de um sistema jurídico escalonado de forma hierárquica, em que a validade de uma norma é conferida pela existência de uma norma superior, como no seguinte raciocínio: por que o ato administrativo é válido? Porque a lei em sentido formal autorizou sua emissão. Por que a lei é válida? Porque a Constituição a autorizou. Por que a Constituição é válida? No nível constitucional as dificuldades começam a aparecer. Podemos dizer que a Constituição é válida porque foi adotada pelo poder constituinte originário. Mas que norma autorizou o poder constituinte originário a atuar validamente? Kelsen admite que possamos recuar o raciocínio para as constituições anteriores, até a primeira constituição histórica. Mas em algum momento, seja em relação à primeira constituição histórica, seja porque houve quebra da ordem constitucional, não teremos uma norma positiva capaz de conferir o fundamento de validade das normas superiores e, por conseguinte, de todo o sistema jurídico. É aí que Kelsen formula a necessidade de uma norma que não existe no mundo dos fatos, uma norma pressuposta, que seria justamente a *Grundnorm* (*basic norm* em inglês ou, entre nós, a norma fundamental). A norma fundamental diria algo como: “deve-se obedecer à primeira constituição histórica” ou “deve-se obedecer ao poder constituinte originário.”^[100]

Podemos nos perguntar, e muitos teóricos o fizeram, se a noção da norma fundamental seria mesmo necessária. Kelsen procura manter-se fiel ao método de construir uma *teoria pura* do direito, em que a validade seja definida a partir de critérios próprios do direito, sem fazer apelo a argumentos morais ou sociológicos. Poderíamos dizer que a constituição vale porque foi imposta de forma eficaz por determinado grupamento político, ou porque representou um consenso político suficiente quando foi adotada, mas, no sistema kelseniano, tais assertivas representariam uma concessão a aspectos outros da realidade que não o direito. O autor parece adotar a chamada “lei de Hume”, segundo a qual um juízo qualquer de fato não pode ser comutado em juízo de valor – valores e fatos pertenceriam a ordens distintas e independentes. Um “é” não pode se transmutar num “deve-se” de forma automática. Assim, o mero fato da eficácia de uma constituição, imposta pelo poder, não pode implicar na sua validade. É por isso que ele lança mão de uma norma pressuposta, *lógico-transcendental*, na tradição kantiana, para fechar o sistema.^[101]

Hart, por sua vez, ao lado de Kelsen, um dos positivistas mais influentes do século XX, tinha uma abordagem mais sociológica do direito. Ele vê no sistema jurídico normas primárias e secundárias, sendo que as primeiras estabelecem obrigações jurídicas entre os indivíduos e organizações, enquanto as outras

constituem normas de reconhecimento, modificação e julgamento, isto é, são normas que já incidem sobre a própria realidade do direito, consistindo em normas de reconhecimento do que pode ser considerado direito, aquelas que estabelecem como o direito pode ser modificado e as regras de julgamento dos conflitos. Das normas secundárias, tem maior destaque a regra de reconhecimento (*rule of recognition*), que se parece com a norma fundamental kelseniana.

Contudo, embora esteja no ápice do sistema jurídico e contenha em si os critérios de validade das demais normas, a norma de reconhecimento de Hart é uma norma empírica, de natureza sociológica ou costumeira – é a regra, aceita pela comunidade, que estabelece *quem* pode criar validamente o direito. Na Inglaterra, Hart afirma que a norma de reconhecimento seria “*é direito o que é aprovado pelo Parlamento, com a intervenção da Rainha*” (*Queen-in-parliament*).^[102] Esta norma é reconhecida principalmente pelos integrantes do Estado, como juízes, que orientam sua atuação a partir dela. No Brasil, poderíamos dizer atualmente que a norma de reconhecimento seria “é direito a Constituição de 1988 e o que ela estabelece como tal.” Observe-se que se trataria de uma norma acima da própria Constituição, estabelecendo a sua validade, mas ela seria sociológica, pois admitida como um consenso entre os aplicadores do direito e a própria sociedade como um todo. Por essa razão, Hart é considerado por alguns autores como um convencionalista.^[103]

Kelsen nega que sua norma fundamental tenha um caráter normativo, que estabeleça um dever de obediência à constituição e à ordem jurídica; ela permaneceria tendo caráter descritivo, sendo necessária à descrição do sistema jurídico.

Por outro lado, autores não positivistas também neste ponto questionam a possibilidade de o direito apartar-se totalmente da moral. Para Carlos Santiago Nino, a competência do poder constituinte originário não pode a rigor ser considerada uma competência no sentido jurídico, pois essa noção demandaria uma norma jurídica válida que a estabelecesse. Trata-se, pois, de um poder de fato, e a validade jurídica dos seus atos dependeria de uma avaliação política e moral. Segundo o autor argentino:

Isso é assim, em última instância, porque não existe uma justificação jurídica de atos e decisões que seja independente de considerações de índole moral. A justificação jurídica é uma espécie de justificação moral que se distingue por levar em conta (como dados fáticos relevantes) a vigência de certas normas. (tradução nossa)^[104]

2.5.2. O dever de obediência

O positivismo jurídico muitas vezes sustenta que suas formulações têm caráter descritivo e não normativo, isto é, que o fato de constatar que determinada regra é *direito* não implica em concitar à sua obediência. Hart é explícito nesse sentido; ao tratar da “norma extremamente injusta”, ele diz preferir à fórmula de Radbruch a seguinte assertiva: “isto é lei, mas é muito injusta para ser aplicada.”^[105]

O positivismo que prescreveria a obediência às leis seria aquele que Bobbio chamou de *positivismo ideológico*.

Kelsen também nega que sua teoria pura do direito contenha uma prescrição à obediência. Segundo ele, sua teoria poderia ser sustentada por um professor anarquista. Nega, pois, que possua um caráter ideológico qualquer, que ele vê, ao contrário, no jusnaturalismo. Ao defender que a conformidade com a moral confere ao direito sua obrigatoriedade, o jusnaturalismo, sempre que não estiver diante daquela norma extremamente injusta, à qual negará o caráter de direito, acabaria por conferir uma legitimação moral a todas as demais normas. Ao conferir ao direito um fundamento metafísico, acabaria servindo para legitimar ideologicamente o sistema jurídico vigente.^[106] Já o positivismo jurídico, ao rejeitar a conexão do direito com a moral, ou pelo menos o fundamento moral da validade jurídica, permitiria em maior grau a crítica moral e política do sistema jurídico.

Idêntico raciocínio pode ser encontrado em Hart^[107], inclusive ao discordar da fórmula de Radbruch com o argumento *da clareza*, como denominou Alexy, segundo o qual manter a moral separada do direito facilitaria a tarefa de quem quisesse fazer a crítica deste último. Também encontramos esse argumento no chamado positivismo *exclusivo*, sobre o qual falaremos adiante.

2.5.3. A questão dos princípios

O positivismo de Hart atraiu seguidores e também despertou críticas, como as formuladas por Ronald Dworkin. Este autor, estudado mais adiante, traz como sua original contribuição à Filosofia do Direito a concepção de que os princípios políticos e morais de uma comunidade integram o direito e por isso são, e devem ser, levados em conta pelos juízes no julgamento dos casos. Dworkin critica Hart, pois a sua “regra de reconhecimento” do direito seria baseada num teste de *pedigree*, segundo o qual apenas as normas provenientes de determinadas fontes constituiriam direito. Tal regra de reconhecimento seria incapaz de incluir no conceito de direito os princípios de moralidade política, que não provêm de uma fonte determinada.

Hart responde a Dworkin no famoso *Pós-escrito* ao seu *O conceito de direito*, aduzindo que a regra de reconhecimento poderia, sim, incluir a referência a determinados princípios. Ele aduz que

em alguns sistemas legais, como nos Estados Unidos, os critérios últimos de validade legal incorporam explicitamente princípios de justiça e valores morais substantivos...[\[108\]](#)

Essas linhas de Hart fundam dentro do positivismo uma corrente chamada de *soft positivism*, ou de incorporacionismo ou ainda *positivismo inclusivo* (*inclusive positivism*), de que voltaremos a falar novamente abaixo no item 2.6.

2.5.4. O argumento da democracia

A ideia dos direitos individuais, da liberdade e da igualdade perante a lei é talvez a mais presente nas revoluções liberais, o que se materializa nas primeiras declarações de direitos, como a *Déclaration des droits de l’homme e du citoyen* de 1789, da Revolução Francesa.

Ao lado da defesa dos direitos individuais, encontramos nas revoluções liberais a ideia da democracia, da representação política, isto é, de que os cidadãos devem participar na formação dos governos e do poder em geral. Exemplo disso seriam os escritos do abade Sieyès na Revolução Francesa, sobretudo o famoso “*O que é o Terceiro Estado?*”.

Isso vai fortalecer igualmente a concepção de um direito escrito, proveniente dos parlamentos representativos, ao ponto de chegar-se a uma sacralização da lei, como expressão que era ou deveria ser da vontade geral. Além da necessidade de os direitos individuais serem explicitados na legislação, de forma definitiva, para que fossem conhecidos, reivindicados e respeitados, somente a lei emanada da autoridade representativa teria o poder de vincular os cidadãos. Esse é o ponto de encontro e de separação entre as doutrinas modernas do direito natural e do positivismo jurídico nascente.

O positivismo jurídico encerra, pois, desde os seus primórdios e até hoje, uma preocupação com a legitimidade democrática do direito. O juiz deve cumprir a lei porque não lhe cabe criá-la. Daí a reserva dos positivistas diante das teses do direito natural e da fórmula de Radbruch, de que “*a lei extremamente injusta não é lei.*” Confira-se, à guisa de ilustração, o que diz Hoerster:

É que, ao contrário do que sempre sugerem os adversários do positivismo jurídico, existe não apenas o juiz ou o cidadão que, confrontado com “leis nazistas”, preferiria obedecer a uma moral humana. Existe também o juiz ou cidadão que, confrontado com leis “democráticas” (por exemplo, aquelas da República de Weimar ou da República de Bonn) preferiria obedecer a uma moral nazista!^[109]

2.6. Positivismo inclusivo, esclusivo e normativo

2.6.1. Positivismo inclusivo

Como já vimos, Hart responde às críticas de Dworkin no famoso *Pós-escrito* ao seu livro “O conceito de direito.”^[110] Para ele, é possível que princípios de moralidade venham a fazer parte do direito, mas desde que sejam incorporados, “incluídos” pela regra de reconhecimento, explicada acima (2.5.1). Hart não abre mão, assim, do que Dworkin chamou de “teste de pedigree”. O autor positivista admite que a regra de reconhecimento venha a albergar esses princípios morais, que passam então a fazer parte do direito; segundo ele, isso acontece com as cláusulas de direitos fundamentais da Constituição americana e lembra que o próprio Dworkin reconhece que a liberdade de expressão prevista na Primeira Emenda seria um princípio.^[111]

A posição de Hart, admitindo que o direito positivo de determinado país possa incorporar princípios de justiça e valores morais substantivos, deu origem a uma corrente do positivismo jurídico chamada de *positivismo inclusivo* (*inclusive positivism*) ou *soft positivism*.

2.6.2. Positivismo exclusivo

Ao positivismo inclusivo opõe-se o *positivismo exclusivo* (*exclusive positivism*), que segue negando que o direito possa incorporar os princípios morais. Para essa corrente, o fato de a norma legal delegar ao juiz uma ponderação moral qualquer não faz que essa ponderação se torne por isso jurídica; ela continuaria a ser moral, como um cálculo matemático determinado por lei não deixa de ser matemático, estando a lei impossibilitada de alterar-lhe as características matemáticas. Para os exclusivistas, esse entendimento, que insiste na separação entre direito e moral, seria mais adequado, por razões que incluem a clareza já defendida por Hart e acima mencionada. ^[112]

O positivismo *exclusivo*, no sentido daquele que *exclui* os princípios morais do campo do direito, está associado sobretudo a Joseph Raz. ^[113] Os autores dessa corrente insistem ainda no seu caráter meramente *descritivo* e não *normativo*, do que o direito *é*, sem pretensão de dizer o que ele *deve ser*. Jean-Yves Chérot põe em evidência esse aspecto e afirma que a tese da “inércia normativa” do positivismo exclusivo “*não dá qualquer direção sobre o que o juiz deve fazer em termos de argumentação jurídica, sobretudo nos casos difíceis.*” ^[114]

2.6.3. Positivismo ético ou normativo

Essa espécie de positivismo propõe-se a lidar justamente com a questão de ser o positivismo meramente descritivo ou não. Percebendo a impossibilidade ou insuficiência do modelo descritivo, alguns positivistas passam a defender que o positivismo deve ser um *positivismo ético ou normativo*, ou ainda *programático*, isto é, esta teoria pode ser defendida com argumentos propriamente normativos, do que *deve ser* o direito. O direito concebido como algo distinto da moral, portanto, a própria *tese da separação* não seria algo dado, aferível no mundo dos fatos, a partir do enfoque descritivo ou científico, mas uma construção teórica, que deita suas bases na filosofia política de cunho normativo, como a de Hobbes e de Bentham. *Quer-se* essa compreensão do direito, como algo distinto da moral, adotando-se a tese da separação, *porque é melhor que seja assim*, por razões de segurança jurídica, etc.

O positivismo jurídico, nessa modalidade, afirma-se não como ponto de vista científico, mas como concepção propriamente moral e política. [\[115\]](#) Voltaremos a essa questão no próximo item.

2.7. Fundamentos epistemológicos

2.7.1. Postulados relativos ao conhecimento ético

Vimos que o jusnaturalismo baseia-se em uma compreensão objetivista dos valores morais – isto é, admite em certa medida a verdade moral, em cujo âmbito as obrigações poderiam ser reconhecidas e estabelecidas de forma objetiva, independentemente da compreensão de cada um sobre o que é correto, justo, etc. O jusnaturalismo reconhece, pois, um núcleo de verdades – como a proibição da violência ou a compreensão de que ela é um mal – que é compartilhado pela moral e pelo direito.

Já o positivismo jurídico na maioria das vezes baseia-se no relativismo axiológico ou moral, isto é, na impossibilidade de estabelecerem-se verdades objetivas no campo moral, onde os valores seriam relativos, isto é, dependeriam da compreensão de cada um, de cada sociedade, sem que um “ponto de vista” possa prevalecer sobre outro. Com efeito, Kelsen considera “*o relativismo axiológico como ponto de partida da teoria positivista do direito.*”^[116] Isso significa dizer que, se a moral fosse objetiva, isto é, se pudéssemos dizer o que é ou não justo e correto de forma objetiva, o direito seria desnecessário ou teria que espelhar essas verdades morais; é por não haver verdades morais que o direito faz-se necessário, selecionando pontos de vista de alguma forma dominantes e tornando-os obrigatórios. Essa imbricação entre a filosofia moral e a Filosofia do Direito é destacada pelo próprio Radbruch, em passagem consentânea com suas posições anteriores à Segunda Guerra, próximas do positivismo:

Agora ficou demonstrado para nós ser impossível responder à pergunta acerca da finalidade do direito de outro modo que não seja a enumeração das variadas opiniões sectárias a respeito – e, justamente, apenas por essa impossibilidade de um direito natural a validade do direito positivo pode ser fundamentada; o relativismo, que até agora era somente o método da nossa análise, entra, aqui mesmo, como elemento estrutural de nosso sistema.^[117]

Outros autores positivistas, contudo, entendem que a questão da epistemologia da moral não é tão relevante ou mesmo não importa para a tomada de posição quanto ao positivismo jurídico. Mesmo em se admitindo uma moral objetiva, ainda assim direito e moral permaneceriam distintos e tal distinção continuaria sendo da mesma forma justificada.^[118]

2.7.2. Postulados relativos ao conhecimento do próprio direito. A questão da “neutralidade científica”

Por outro lado, se em relação à moral o positivismo jurídico assume uma postura relativista, o mesmo não se pode dizer em relação ao conhecimento do próprio direito. O positivismo, aqui, concebe que é capaz de conhecer como o direito *realmente é*. Essa pretensão científica pode-se notar já em Austin, mas, sobretudo, em Kelsen, que combate o jusnaturalismo atacando o seu caráter platônico, metafísico e ideológico. Como asseverado acima, este autor insere-se no Círculo de Viena, cujos filósofos sustentavam o positivismo lógico e cultivavam uma concepção rigorosa da ciência.

Aqui entra a questão da “neutralidade científica”, reivindicada pelos positivistas. Os positivistas em geral sustentam realizar um estudo *descritivo* do que é o direito – descrevem o direito vigente como descreveriam o direito grego ou romano antigos ou o direito de um país estrangeiro. Cultivariam uma postura *avaliativa*, que deve ser a do cientista, evitando fazer avaliações ou emitir juízos de valor sobre o objeto de estudo.

Isso não significa, para o positivismo jurídico, que o direito seja isento de valores – ao contrário, Kelsen admite que considerações morais são legítimas e mesmo naturais, por exemplo, por parte do legislador. Esse aspecto também é destacado por Green.^[119] *O que deve ser isento de valoração é a ciência jurídica, a teoria do direito*, enfatizando-se o seu caráter descritivo, em contraposição ao caráter normativo ou prescritivo que seria próprio das concepções jusnaturalistas – que pretendem dizer o que o direito deve ser.

Portanto, dentro da tricotomia proposta por Bobbio acima indicada (de que o positivismo pode ser uma forma de conhecer o direito, uma teoria do direito ou uma ideologia do direito), a maioria dos autores positivistas reivindica fazer parte da primeira e da segunda classificação – isto é, pretendem que suas teses têm caráter meramente descritivo, que representam um conhecimento sobre o direito e não uma avaliação sobre ele.

Vemos, no positivismo, conjugarem-se uma concepção relativista quanto ao conhecimento moral e uma concepção científicista em relação ao conhecimento do próprio direito. Uma rara crítica ao que seria essa concepção *essencialista* em relação ao próprio direito – isto é, de que o direito teria uma essência, uma realidade objetiva – pode ser vista em Carlos Santiago Nino, ao propor que o conhecimento do direito pode abrigar tanto o ponto de vista descritivo próprio do positivismo quanto o ponto de vista normativo.^[120]

2.7.3. O enfoque descritivo do positivismo jurídico é possível? É suficiente?

Esse aspecto é objeto da preocupação de alguns autores. Primeiramente, pode-se questionar se as ciências humanas seriam capazes de despir-se totalmente de valores, à maneira das ciências físicas ou naturais; os temas e problemas com que lidam, carregados de subjetividade, bem como a figura do observador – que como homem insere-se na própria realidade estudada – podem tornar inviável essa pretensão. Tais aspectos foram largamente estudados e discutidos nas ciências humanas e na filosofia do conhecimento no século XX, sendo conhecidos a respeito os trabalhos de Max Weber, Thomas Kuhn e de Michel Foucault.

Por outro lado, o enfoque meramente descritivo do positivismo parece não corresponder à realidade e à prática da doutrina e da jurisprudência, isto é, dos estudiosos do direito e dos juízes. Não pretendemos discorrer longamente a respeito, mas basta um lançar de olhos a um livro de direito para constatar que o doutrinador não se limita a uma atitude descritiva do que seja o direito – *a descrição vai de par com argumentos avaliativos, normativos*, que se confundem com a própria descrição ou pretendem de alguma forma corrigi-la, ampliá-la, restringi-la. Nesse sentido, assevera Alexy:

A dogmática jurídica é, em grande medida, uma tentativa de se dar uma resposta racionalmente fundamentada a questões axiológicas que foram deixadas em aberto pelo material normativo previamente determinado. ^[121]

Alguns autores, na mesma linha, entendem que seria impossível formular uma filosofia ou teoria do direito completamente objetiva. O teórico partiria sempre de algum juízo valorativo, pelo menos no que diz respeito a questões mais gerais, como a função da lei na sociedade e a avaliação positiva ou negativa que se faça a respeito. ^[122]

Dworkin veria essa impossibilidade de uma teoria do direito despida totalmente de valores em razão do seu caráter de *interpretação*. Para ele, a definição do que é o direito em determinado caso exige sempre uma interpretação, e a interpretação não pode ser feita sem juízos de valor, avaliativos ou normativos. ^[123]

Por fim, há a questão do *participante* do sistema (distinto do observador), ou do ponto de vista interno, contraposto ao externo – noções elaboradas por Hart e também por Alexy. O ponto de vista meramente descritivo pode mostrar-se insuficiente para o juiz. Além de os aspectos avaliativos estarem entremeados na aplicação da própria lei, o juiz quase sempre adere ao direito que aplica, empregando argumentos descritivos e também normativos ou avaliativos. O direito funciona para ele como uma *razão para agir*, talvez mais importante que outras razões que possam ser suscitadas, mas ainda assim a exigir uma justificação. Mesmo quando aplica a lei “por ser a lei”, e ainda que afirme dela discordar do ponto de vista moral, o juiz adere à concepção de que aquela lei deve ser aplicada, não por uma constatação

derivada do mundo fático, mas por fundamentos que estão além da própria existência da lei, como considerações políticas e morais.

Talvez por essas razões Norberto Bobbio tenha-se antecipado aos aprofundamentos da filosofia do direito anglo-saxã das últimas décadas e diga que o positivismo jurídico

não conseguiu ser integralmente fiel a esse seu propósito, pois, na realidade, ele parece não só um certo modo de entender o direito (de destacar-lhe os caracteres constitutivos), como também um certo modo de querer o direito; parece, portanto, não somente uma teoria, mas também uma ideologia.^[124]

E isso, na perspectiva que vimos analisando, não por um defeito, mas por uma impossibilidade de descartar totalmente os argumentos avaliativos.^[125] Também no mesmo sentido vai o pensamento de Leslie Green. Defensor do positivismo jurídico, conclui que “*nenhum filósofo do direito pode ser apenas um positivista jurídico*”, aduzindo que uma teoria completa do direito requer também uma avaliação sobre o que deve contar como mérito da lei (uma lei, além de justa, deve ser eficiente ou elegante?), qual o papel da lei em uma decisão judicial (a lei válida deve sempre ser aplicada?), que influência a existência da lei tem sobre nossa obediência (existe um dever de obedecer?), além de questões da maior importância como *quais* leis deveríamos ter ou ainda se deveríamos ter leis.^[126]

Finalmente, talvez percebendo a impossibilidade ou insuficiência do modelo descritivo, alguns positivistas passaram a defender, como visto acima (2.6.3), que o positivismo deve ser um *positivismo normativo* ou *ético*, isto é, esta teoria pode ser defendida com argumentos propriamente normativos, como em Campbell.^[127]

3. O realismo e o pragmatismo jurídicos

3.1. Definição. Características gerais

O realismo jurídico é a corrente da Filosofia do Direito segundo a qual o direito, pelo menos o direito válido, é aquele efetivamente observado e aplicado numa dada sociedade. A corrente adota um conceito sociológico de validade, em que sobressai a preocupação com a eficácia social do direito, tanto em termos da convicção de sua obrigatoriedade pelos sujeitos (aspecto psicológico) quanto de sua efetiva aplicação pelos tribunais.

Para o realismo jurídico norte-americano, como o direito somente se materializa com a decisão judicial, antes dela ele não existe propriamente ou não tem um caráter vinculante; as normas jurídicas serviriam ao juiz apenas como fontes de informação, juntamente com outras ciências e realidades sociais.

Dessa forma, o realismo jurídico opõe-se tanto ao jusnaturalismo – segundo o qual haveria verdades morais que se impõem ao juiz – quanto ao positivismo, que sustenta a validade de um conjunto abstrato de normas que, para os realistas, não teria força vinculante e constituir-se-ia apenas num ponto de partida.

O realismo norte-americano tem entre seus precursores e idealizadores Roscoe Pound, Benjamin Cardozo e Oliver Wendell Holmes Junior (1841-1935), o último tendo sido um juiz influente da Suprema Corte.

Deve-se mencionar que, além do realismo jurídico norte-americano, existe o realismo jurídico escandinavo, representado por autores como Axel Hägerström (1868-1939), Karl Olivecrona (1897-1980) e Alf Ross (1899-1979). Hägerström criticava a noção de *dever jurídico* que permeava a dogmática jurídica; via-a como idealista e localizava-a no jusnaturalismo e também no positivismo, que a teria herdado. O realismo escandinavo tem muitos pontos de contato com o realismo norte-americano, inclusive a importância da atividade judicial, mas inclui com mais ênfase, na análise do direito, elementos psicológicos e sociológicos.

3.2. Realismo jurídico como descrição do direito

O realismo tem um caráter descritivo, ao explicitar o que seria o direito na prática, na realidade, e por isso vai insistir na importância da atividade judicial na definição das normas jurídicas. Essa importância advém por sua vez de uma constatação: da liberdade com que os juízes interpretam a lei e os textos em geral e da profunda discricionariedade com que decidem. Ficou famosa a tirada realista de que a decisão depende *do que o juiz comeu no café da manhã*.

Autores realistas fazem a constatação histórica de que os juízes *criam* muitas vezes o direito. Michel Troper dá o exemplo de que no direito francês a *"responsabilidade civil, objeto somente de alguns artigos do Código Civil, é quase totalmente jurisprudencial."*^[128] Poderíamos acrescentar, ainda em relação ao direito francês, que o direito administrativo daquele país, que teve grande influência, inclusive no Brasil, sedimentou-se a partir da jurisprudência do *Conseil d'État*, mais do que de textos legais.

Por vezes o realismo parte de uma reflexão sobre a natureza da interpretação jurídica. Ela seria sempre algo inovador e, no direito, quando realizada pelos órgãos investidos da jurisdição, consistiria num *ato de vontade* e não de conhecimento. A interpretação seria, pois, uma função da vontade:

Todo enunciado é dotado não de uma, mas de várias significações entre as quais se trata de escolher. Essa escolha não representa uma realidade objetiva, porém traduz as preferências subjetivas daquele que a exprime. Além disso, o produto da interpretação não pode ser verdadeiro nem falso, ^[129].

Vê-se que para o realismo jurídico a discricionariedade judicial seria quase total, ao menos em relação às cortes superiores e constitucionais, sem sofrer limitação jurídica, mas apenas de caráter social.^[130]

3.3. Realismo como proposta normativa

O realismo jurídico, contudo, de forma mais explícita que o positivismo, pode assumir uma feição normativa. Ao constatar a liberdade e discricionariedade do juiz, ele igualmente assente a essa realidade e autoriza que o juiz tome a distância que entender necessária dos textos normativos, preocupando-se, sobretudo, com as *consequências* de suas decisões.

Aqui o realismo jurídico inspira ou confunde-se de alguma forma com o *pragmatismo jurídico*, corrente que tem no professor norte-americano e ex-juiz Richard A. Posner um de seus principais expoentes. Ao analisar a relação do *juiz pragmatista* com as chamadas fontes do direito, Posner assevera que:

(...) o juiz pragmatista encara a jurisprudência, a legislação e o texto constitucional sob dois aspectos: como fontes de informações potencialmente úteis sobre o provável melhor resultado do caso sob exame e como marcos que ele deve ter o cuidado de não obliterar nem obscurecer gratuitamente, pois as pessoas os tomam como pontos de referência. Porém, como vê essas “fontes” somente como fontes de informação e como restrições parciais à sua liberdade de decisão, ele não depende delas para encontrar o princípio que lhe permite decidir um caso verdadeiramente inusitado. [\[131\]](#)

Deve-se ressaltar que o realismo e o pragmatismo jurídico, ao reconhecer e conferir ao juiz esse alargado poder de escolha, não distingue de forma absoluta o direito e a política – distinção que é enfatizada por Dworkin, um dos principais adversários dessa corrente. Isso leva o juiz pragmatista a preocupar-se com as consequências de suas decisões da mesma forma que um político ou legislador – embora este último não esteja do mesmo modo sujeito ao diálogo com as fontes do direito e precedentes. Inclusive a opinião pública seria um fator importante a ser considerado pelo juiz, sobretudo quando os textos não são claros a respeito da decisão que deverá adotar – exemplo disso é a posição de Posner, na citada obra, contrária à admissão pela Suprema Corte do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

[\[132\]](#)

3.4. Fundamentos filosóficos e epistemológicos

O realismo e o pragmatismo jurídicos sofrem marcada influência do pragmatismo filosófico. Essa corrente do pensamento filosófico de finais do século XIX nega que a verdade exista como entidade metafísica mas, por outro lado, nega também que não se possa estabelecer qualquer verdade sobre a realidade natural, social, etc. O critério para estabelecer-se a verdade de uma ideia seria a prática, notadamente as suas consequências práticas. São precursores do pragmatismo Charles Sanders Peirce, William James e o próprio jurista Oliver Wendell Holmes Junior. Na modernidade, o filósofo norte-americano Richard Rorty retomou muitos elementos do pragmatismo.

Essa preocupação com a prática – tanto em saber como o direito é na prática, como com as consequências das decisões judiciais – está presente no realismo jurídico. Nesse sentido, percebe-se também a proximidade da escola com o *utilitarismo*, doutrina da filosofia moral para a qual, como vimos, o critério para definir-se se uma ação é boa ou má é o da utilidade geral – a soma de felicidade acarretada pela ação (*Parte I, 2.3.*).

De um ponto de vista metaético, vislumbra-se no realismo uma postura muito próxima daquela adotada pelo positivismo jurídico quanto à filosofia moral: o relativismo moral ou axiológico, também já discutido, e uma rejeição à metafísica.

O realismo jurídico norte-americano vale-se de alguns postulados céticos, ao afirmar a inexistência de um direito objetivo prévio à decisão judicial. Ressalta a irracionalidade e a imprevisibilidade das decisões, ditadas por motivos contingentes. Um de seus autores mais expressivos, Jerome Frank, no seu livro de 1930 *Law and Modern Mind*, afirma que a certeza do direito é um mito baseado na reverência infantil à autoridade e que deve ceder para levantar sobre suas ruínas o direito como criação permanente e imprevisível.^[133]

Outro dos seus expoentes, Oliver Wendell Holmes Jr., afirma que a função da ciência jurídica seria a de, tão somente, *tentar prever o que vão fazer os tribunais nas futuras decisões*.

Tais pressupostos filosóficos e epistemológicos do realismo ficam patentes também em Posner.^[134] Apesar de conceder ao jusnaturalismo a existência de um núcleo universal de moralidade, equivalente ao que Hart denominou de “conteúdo mínimo de direito natural”, como a proibição de matar, Posner considera que esse consenso é insuficiente para resolver os casos difíceis, para os quais não existiria uma solução propriamente verdadeira. Ele entende, e nisso critica Dworkin, que a teoria moral não tem como responder a certas perguntas envolvendo o aborto e a eutanásia.^[135]

4. Neoconstitucionalismo – Dworkin – Alexy

Embora nem Dworkin nem Alexy adotem a terminologia *neoconstitucionalismo*, reunimos esses autores neste tópico por considerar que suas formulações, notadamente na questão relacionada aos *princípios*, estão de alguma forma associadas a essa corrente atual do pensamento constitucional. [\[136\]](#)

4.1. O neoconstitucionalismo

As constituições modernas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, adotam uma principiologia baseada nos direitos humanos, constante também das declarações internacionais. Por outro lado, não apenas apresentam o caráter rígido, que lhes assegura a supremacia formal frente à legislação, mas dão ensejo em boa parte dos países ao *controle de constitucionalidade*, entregue a organismos judiciais ou em tudo semelhantes às cortes judiciais.

Enquanto um controle de constitucionalidade mais efetivo restringira-se, no século XIX, aos Estados Unidos da América, na modalidade chamada entre nós de concreta ou difusa, no pós-guerra os países europeus passam também a adotá-lo, na forma, sobretudo, do controle direto ou concentrado, também conhecido como modelo austríaco. As cortes constitucionais surgem como atores importantes na vida jurídica e política das nações, declarando a inconstitucionalidade de leis e atos normativos e decidindo questões de grande relevância. Mais que isso, sua função ganha destaque na proteção dos direitos fundamentais que, em virtude de sua formulação abstrata e fortemente valorativa, exigem uma interpretação e argumentação de tipo substantivo.

Neoconstitucionalismo é a denominação que tem sido aceita pela doutrina, a indicar essa alteração na natureza dos Estados constitucionais modernos, sobretudo em relação aos Estados legais do século XIX. A noção incluiria a força normativa da Constituição, que adquire maior eficácia jurídica, mormente através dos mecanismos de controle da constitucionalidade das leis, bem como o caráter marcadamente principiológico das constituições atuais. Luis Prieto Sanchís admite a noção de neoconstitucionalismo, a que faz equivaler a de constitucionalismo contemporâneo ou simplesmente de constitucionalismo, utilizando ainda a expressão *constitucionalismo forte*.^[137]

Outro aspecto marcante do neoconstitucionalismo, que o coloca em contato direto com as questões da Filosofia do Direito, é a defesa de uma conexão entre o direito e a moral ou a ética, que seria propiciada pelo caráter axiológico dos princípios constitucionais. Já se afirmou que essa corrente partiu de um modelo normativo (o constitucionalismo) e transformou-se em uma teoria do direito.^[138]

A introdução dos princípios nas constituições modernas, com alto nível de abstração e carga valorativa, conferiria ao raciocínio jurídico uma dimensão muito próxima do debate ético. Nesse sentido, Dworkin afirma que "*a Constituição funde questões jurídicas e morais, fazendo com que a validade de uma lei dependa da resposta a problemas morais complexos.*"^[139]

Essa reintrodução da ética no raciocínio jurídico, ao menos no nível argumentativo, em que se mostrariam incindíveis argumentos legais e extralegais, é

também destacada por Luís Roberto Barroso:

Como consequência, a partir da segunda metade do século XX, o direito deixou de caber integralmente no positivismo jurídico. A aproximação quase absoluta entre Direito e norma e sua rígida separação da ética não correspondiam ao estágio do processo civilizatório e às ambições dos que patrocinavam a causa da humanidade. [\[140\]](#).

Assim, como se vê, o neoconstitucionalismo quer-se muitas vezes uma superação do positivismo jurídico, falando-se igualmente em “pós-positivismo”. Suas formulações o aproximariam em certa medida do jusnaturalismo que, como vimos, baseia-se na tese da conexão entre direito e moral. Zagrebelsky, que defende a novidade do “direito por princípios”, reconhece que os princípios constitucionais, com sua formulação universal e abstrata, assemelham-se aos princípios do direito natural. [\[141\]](#)

Importante assinalar, contudo, que um autor como Luigi Ferrajoli, mesmo reconhecendo os méritos do Estado constitucional, rejeita o que chama de “constitucionalismo principialista” e aduz que o constitucionalismo contemporâneo não representaria uma superação, mas antes uma “expansão e complemento” do positivismo jurídico, subordinando também o legislador aos ditames constitucionais. [\[142\]](#)

4.2. Ronald Dworkin

Ronald Dworkin (1931-2013) é um dos filósofos do direito mais importantes do século XX. Ele envolve-se num profundo debate com as demais correntes da filosofia jurídica, tendo como adversários principais o positivismo e o pragmatismo jurídico e ainda, no campo da filosofia moral, o ceticismo e o utilitarismo.

4.2.1. Os princípios de moralidade política integram o direito

Para Dworkin, mencionado em outras passagens desta obra, os princípios políticos e morais integram o direito, segundo sua teoria do *direito como integridade* (*law as integrity*). Ele refere-se aos *princípios de moralidade política*, aqueles que interessam à organização da sociedade e não meramente ao comportamento individual.

Na função de dizer o direito, o juiz seria obrigado a perscrutar tais princípios, a fim de resolver o caso da melhor maneira, sobretudo nos *hard cases*, os casos difíceis em que os textos legais não são suficientemente claros.

Nessa busca pela solução correta do caso, o juiz não está livre para considerar apenas as *consequências* de sua decisão, como faria o pragmatismo jurídico – voltado, pois, para o futuro; Dworkin tem uma concepção forte dos direitos, como trunfos (*trumps*) diante do Estado, que não podem ceder diante de considerações políticas ou de utilidade. Por outro lado, o juiz também não estaria preso ao passado, às decisões anteriores das instituições públicas, como as leis e os precedentes, postura que Dworkin associa ao convencionalismo e ao positivismo jurídico.^[143]

O que se espera do juiz é a interpretação correta, notadamente da Constituição, que leve em conta os precedentes (dimensão da adequação ou *fit*) mas também dos valores protegidos pelas normas (*value*).

Dworkin ilustra a realidade jurídica dos princípios na prática judicial com o caso *Riggs v. Palmer*, também conhecido como caso *Elmer*, julgado em 1889 por um tribunal de Nova Iorque. Os juízes decidiram que, apesar de ser designado em um testamento válido, não poderia o neto herdar do avô, pois o havia assassinado; o tribunal observou que “*todas as leis e os contratos podem ser limitados na sua execução e seu efeito por máximas gerais e fundamentais do direito costumeiro.*”^[144]

4.2.2. A tese da “única resposta correta” (*one-right-answer thesis*)

Para Dworkin, nos *hard cases*, questões judicializadas envolvendo grandes indagações morais, como o aborto e a eutanásia, haveria apenas uma única resposta correta, a ser descoberta e adotada pelo juiz.

Dworkin nega aqui ao juiz qualquer *discrecionarietà*, opondo-se notadamente à tese de Hart de que, nos casos incertos, inseridos na *textura aberta* do direito em razão da imprecisão das normas legais, o juiz exerceria uma *discrecionarietà* para *criar* a decisão.

Assim, enquanto para o realismo jurídico o juiz atua com uma *discrecionarietà* quase total e, para o positivismo, a *discrecionarietà* existe nas lacunas da lei, para Dworkin não existe *discrecionarietà* nesses casos. Sempre há uma resposta correta a ser *descoberta* pelo juiz e não criada ou inventada. Para o realismo o direito *nunca* pré-existe à decisão judicial – pois é ela que o cria –, já para Dworkin o direito *sempre* pré-existe à decisão, mesmo que para encontrá-lo o juiz deva revolver complexos problemas de teoria moral.

Sobre a tese da única resposta correta, afirma Dworkin:

Alguns leitores não se deixarão convencer. É certamente "impossível" que num caso verdadeiramente difícil, uma das partes esteja simplesmente certa e a outra, simplesmente errada. Mas por quê? Pode ser que a suposição de que uma das partes pode estar certa e a outra, errada, esteja cimentada em nossos hábitos de pensamento em um nível tão profundo que não podemos, de modo coerente, negar tal suposição, por mais céticos ou intransigentes que pretendamos ser nessas questões. Isso explicaria nossa dificuldade de formular coerentemente o argumento teórico. O "mito" de que num caso difícil só existe uma resposta correta é tão obstinado quanto bem sucedido. Sua obstinação e seu êxito valem como argumentos de que não se trata de um mito. ^[145]

No curso desta obra, temos associado às correntes da Filosofia do Direito posicionamentos no âmbito da filosofia moral e notadamente da metaética. Ao positivismo jurídico associamos o ceticismo ou relativismo moral e ao jusnaturalismo o chamado realismo ou objetivismo moral. Segundo o objetivismo, haveria “verdades morais” objetivas, independentemente das crenças das pessoas ou das sociedades. A tese dworkiniana da “única resposta correta” em casos de grande indagação moral atrai por vezes a crítica de que o filósofo norte-americano esposaria também uma forma de objetivismo; foi o que afirmou Stanley Fish, em debate travado com Dworkin, sendo que este último repeliu a assertiva. ^[146]

A tese da única resposta correta é alvo de críticas, inclusive de autores não-positivistas como John Finnis e Carlos Santiago Nino. Também Alexy:

As regras de fundamentação referida a direitos fundamentais não definem um procedimento que leve, em todos os casos, a somente um resultado. ^[147]

A tese da única resposta correta em Dworkin está ligada à sua teoria da interpretação e à metáfora do romance em cadeia. Interpretar uma obra de arte ou um problema jurídico seria “*uma questão de impor um propósito a um objeto ou prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou do gênero aos quais se imagina que pertençam*”^[148], mostrando o objeto sob a sua melhor luz.^[149]

Na metáfora do romance em cadeia, o juiz seria como o escritor de um romance iniciado por outros e, portanto, estaria obrigado a continuar o empreendimento de forma *coerente*; o primeiro escritor gozaria de uma liberdade total ou mais ampla, enquanto os seguintes, diante da complexidade do enredo, experimentariam um constrangimento maior, restando-lhes muitas vezes uma única interpretação possível sobre a maneira de continuar o romance.^[150]

A interpretação ocupa lugar especial na teoria de Dworkin. Enquanto considera que o convencionalismo e o pragmatismo são interpretações possíveis do direito, a sua teoria não apenas se constitui em mais uma interpretação, mas é aquela em que a interpretação é algo como a própria essência do direito e da atividade judicial. Como dito acima, a definição do que é o direito em determinado caso exige sempre uma interpretação, e a interpretação não pode ser feita sem juízos de valor, avaliativos ou normativos.^[151]

4.3. Robert Alexy

O alemão Robert Alexy é outro grande nome da Filosofia do Direito contemporânea, também associado ao neoconstitucionalismo por sua teoria dos princípios, embora, como já afirmado, ele não adote essa denominação.

O pensamento de Alexy, em grandes linhas, pode ser dividido em três partes, todas de certa forma conectadas entre si: suas considerações mais gerais sobre o conceito de direito, que já abordamos em alguns pontos; sua teoria da argumentação jurídica, que pretende estabelecer bases racionais para a argumentação e a decisão judicial; e sua teoria dos direitos fundamentais, onde desenvolve a sua teoria dos princípios e da ponderação.

Quanto ao conceito de direito, vimos que Alexy defende uma conexão conceitual entre direito e moral, endossando a fórmula de Radbruch de que *a lei extremamente injusta não é lei*. Ainda no âmbito do conceito, Alexy defende que o direito tem sempre uma *pretensão à correção* moral, ainda que não a realize, o que lhe confere, ao lado da dimensão real, do direito positivo, uma *dimensão ideal* (natureza *dual* do direito).

Outro aspecto que propiciaria a conexão entre o direito e a moral seriam os princípios.^[152] Qualquer sistema jurídico minimamente desenvolvido incluiria os princípios, que seriam invocados nos casos duvidosos.

Tais princípios podem estar positivados ou ser apenas princípios morais, necessários à solução da lide. Segundo Alexy, de acordo com o argumento dos princípios, o juiz também “*está legalmente vinculado no âmbito de abertura do direito positivo, ou seja, do direito estabelecido e eficaz, e isso de uma maneira que cria uma vinculação necessária entre direito e moral.*”^[153] Todos esses aspectos revelam a proximidade entre Alexy e Dworkin, sendo, contudo, de atribuir-se primazia a este último nas formulações relativas aos princípios.^[154]

A sua teoria da argumentação jurídica, objeto de sua primeira monografia^[155], leva-o a estabelecer a *tese do caso especial*. Para Alexy, o direito é um caso especial do discurso ou da argumentação prática em geral, que inclui a argumentação política e moral. É um caso especial porque, diferentemente da argumentação moral mais aberta, a argumentação jurídica baseia-se sempre em alguma norma de direito positivo, o que confere mais segurança e certeza à argumentação. Contudo, a argumentação jurídica, mesmo se valendo dos métodos de interpretação do direito (verbal, sistemático, teleológico, etc, *ver a Parte III desta obra*), não se mostraria suficiente para resolver todos os problemas jurídicos e acabaria tendo que se voltar novamente para regras da argumentação prática geral, como as regras gerais do discurso racional, como a da

não-contradição, o “princípio da universalização” de R. Hare, etc. Mais uma vez ver-se-ia aí a conexão entre direito e moral.

Por fim, na sua teoria dos direitos fundamentais, em que desenvolve a sua teoria dos princípios^[156], Alexy defende a distinção, já presente em Dworkin, entre *princípios e regras*, que seriam espécies do gênero *normas jurídicas*. Os princípios seriam mandamentos ou razões *prima facie*, noção que Alexy toma de empréstimo ao filósofo moral escocês W.D. Ross (com sua noção de *direitos morais prima facie*); isso quer dizer que os princípios, como os princípios constitucionais, não indicam de antemão e de forma precisa todas as situações fáticas em que vão se aplicar, mormente porque eles podem colidir no caso concreto, sendo necessário avaliar as circunstâncias de cada caso para se chegar a um juízo de precedência ou de prevalência de um princípio sobre outro. É o que Alexy chama de *juízo de precedência condicionada*. Já as regras seriam mandamentos ou razões *definitivas*, porque já conteriam os pressupostos fáticos capazes de ensejar ou não sua aplicação ao caso concreto.

Enquanto as regras demandariam o tradicional juízo de *subsunção* dos fatos à norma, a colisão de princípios colocaria em evidência a dimensão do *peso* de cada um na situação concreta e exigiria um raciocínio de *ponderação* ou *sopesamento* entre os princípios colidentes.

Podemos citar o caso *Ellwanger*^[157], decidido pelo Supremo Tribunal Federal, como exemplo de colisão e ponderação entre princípios constitucionais, de um lado a liberdade de expressão e de outro a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a não-discriminação. Tratava-se da publicação de textos de cunho nazista, antissemita, pelo Sr. Ellwanger, que acabou condenado pela prática de racismo. O STF, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e manteve a condenação, destacando que “o direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter absoluto.” (Min. Celso de Mello). Na linha de fazer preponderar a liberdade de expressão e considerar atípica a conduta, votaram os ministros Marco Aurélio e Ayres Britto.

Para Alexy, os princípios são ainda “mandamentos de otimização”, no sentido em que devem ser otimizados, maximizados, isto é, aplicados na sua máxima extensão, nos limites, contudo, de suas possibilidades fáticas e jurídicas. As possibilidades jurídicas seriam limitadas, justamente, pela convivência dos vários princípios.

Na colisão de princípios e na subsequente ponderação ou sopesamento, tem particular importância o *princípio da proporcionalidade*. Ele não seria um princípio como os outros, mas, como já mencionamos, uma metanorma, pauta ou postulado normativo de aplicação do direito, servindo para resolver o conflito surgido entre outros princípios. Alexy estabelece e desenvolve ainda os três subprincípios ou submáximas que compõem o princípio da proporcionalidade. A medida *M* que

interfira no princípio P_1 para supostamente proteger o princípio P_2 , teria, para ser considerada proporcional, que passar pelos seguintes testes, representados pelas três submáximas:

- **Adequação:** teste fático, voltado a saber se a medida M é realmente capaz, apta, no mundo dos fatos, a proteger P_2 ;
- **Necessidade:** ainda no mundo dos fatos, tratar-se-ia de saber se a medida M é necessária, isto é, se não haveria meio menos gravoso (considerando P_1) de proteger P_2 ;
- **Proporcionalidade em sentido estrito:** submáxima que segundo Alexy opera no mundo do direito. Trata-se aqui de saber se não há excesso, se os meios utilizados (medida M que interfere negativamente em P_1) são proporcionais aos fins almejados (proteção e importância de P_2 na espécie), isto é, se a interferência em P_1 não se mostra muito intensa diante da importância de P_2 naquela situação concreta. Essa etapa seria regida pela “lei do sopesamento”, segundo a qual tanto maior for a intensidade da interferência em P_1 , tanto maior deve ser a importância de P_2 no caso em exame. [\[158\]](#)

Por fim, devemos destacar que tanto na sua teoria da argumentação jurídica, como na sua teoria dos princípios, Alexy vislumbra a possibilidade de uma decisão *racional*. Se, como visto, ele não aceita a tese da “única resposta correta” de Dworkin, de toda forma ele se aproxima dessa ideia, na modalidade da decisão mais adequada ou pelo menos tomada dentro de um quadro e de procedimentos racionais. Criticado por Jürgen Habermas, no sentido da irracionalidade da ponderação, Alexy aduz ser “*possível elaborar juízos racionais sobre intensidades de intervenções, sobre graus de importância e sobre o relacionamento entre ambos*”[\[159\]](#). E, ainda: “*Isso faz com que a dogmática jurídica seja confrontada com o problema da possibilidade de **fundamentação racional dos juízos de valor** (...) isso é em princípio possível.*”[\[160\]](#) (grifei)

4.4. Avaliação crítica do neoconstitucionalismo

A concepção da constituição como uma *ordem de valores* afirma-se sobretudo na Alemanha, originando também o conceito de *ponderação* entre eles, a ser realizada pelo juiz constitucional. Logo surge a crítica de que tal concepção conferiria ao juiz margem excessiva de subjetividade. Por outro lado, parte da doutrina, mesmo apoiando a nova amplitude da jurisdição constitucional, busca criar procedimentos para que a ponderação se faça de maneira mais objetiva. Afirma Paulo Gustavo Gonet Branco:

Se o modelo constitucional firmado sob a ideia de que a Constituição enfeixa uma ordem de valores foi saudado positivamente logo no seu início, também cedo teve que se medir com os críticos, que estenderam o pessimismo quanto às virtudes da teoria às suas consequências inevitáveis em termos de alargamento do poder dos juízes. Os juízes estariam, segundo os mesmo opositores, perigosamente aparelhados para forçar à sociedade as suas compreensões axiológicas pessoais. [\[161\]](#).

O juiz constitucional e jurista alemão Böckenförde, vencido numa decisão do tribunal constitucional sobre a escusa de consciência para dispensa do serviço militar, teceu críticas à ponderação, chegando a afirmar no seu voto que "*o direito aplicável não mais tem a sua sede na Constituição, mas no juízo de ponderação do juiz.*" [\[162\]](#).

O problema residiria justamente na carga axiológica ou valorativa dos princípios e na sua aptidão – erigidos em normas de referência do controle de constitucionalidade – a resolverem as questões e conflitos valorativos que são postos à decisão do juiz constitucional. A proximidade dos princípios com os valores morais é perceptível e Alexy chega a afirmar que os princípios são valores. [\[163\]](#)

Isso nos remete à questão do *conhecimento ético* e da existência ou não de verdades no âmbito da moral. Como vimos no decorrer dessa obra, as correntes da Filosofia do Direito por vezes se posicionam a respeito desse aspecto da filosofia moral, conhecido também como *metaética*. O positivismo jurídico em geral afina-se com o *ceticismo* ou *relativismo axiológico ou moral*, como em Kelsen, mencionado atualmente por vezes como *não-cognitivismo*, negando a possibilidade do conhecimento ético; já o jusnaturalismo parece esposar o *realismo* [\[164\]](#) ou *objetivismo* ou ainda *cognitivismo moral* que, ao contrário, acredita na possibilidade de estabelecer verdades morais.

O problema é tratado também como o da relatividade dos valores. John Mackie, dos autores mais importantes da corrente não-cognitivista, refere-se à "*subjetividade dos valores*", asseverando de forma categórica que "*não há quaisquer valores objetivos*". [\[165\]](#) Dizer que os valores são *subjetivos* é a forma mais simples de dizer que não é possível atingir uma verdade *objetiva*, racionalmente indisputável diante de todos os indivíduos, a respeito da superioridade de um valor

sobre outro ou ainda sobre as decorrências normativas de um valor, sobre o que devemos ou não fazer, etc.

Reconhecemos em alguma medida o mérito da tese objetivista, quando advoga a possibilidade e a necessidade do debate ético, repelindo o recurso à subjetividade para legitimar posturas arbitrárias e discriminatórias. Contudo, abraçamos alguma forma de relativismo moral ao constatar que não há “resposta correta” ou única para certos debates travados no campo valorativo.

A questão do aborto, por exemplo, ou mesmo as pesquisas com embriões, é marcada por controvérsias insanáveis do ponto de vista racional, voltado à descoberta da verdade. Disputam a posição *concepcionista*, segundo a qual a formação do ser humano dá-se com a mera concepção, e a *sencientista* ou neurológica^[166], segundo a qual isso acontece num estágio mais avançado do desenvolvimento do embrião. Ora, cada uma dessas posições deita raízes em crenças religiosas e convicções filosóficas, em *visões morais*, na expressão de Iris Murdoch^[167], não sendo possível arbitrar de que lado está a verdade. Ainda que se adote a perspectiva de que o direito deve respeitar a autonomia moral dos indivíduos, só proibindo aquilo que cause prejuízo a outrem, segundo o princípio do dano (*harm principle*) de John Stuart Mill^[168], para a posição concepcionista o aborto tem caráter de atentado à vida e por isso pode ser legitimamente proibido.

Bobbio, como positivista, também adere à lei de Hume e critica a crença na “natureza das coisas”, presente na teoria do Direito Natural. Para ele, dos fatos não se pode inferir a regra de conduta, pois estas pressupõem um acordo quanto ao *fim*, que nem sempre é obtido nos assuntos humanos.

(...) quando vem a faltar a concordância quanto ao fim, quando, portanto, mais fins entre si contrastantes se apresentam, cai então a aparente objetividade. Tomemos como exemplo o problema da disciplina jurídica das práticas anticoncepcionais. (...) Se o fim que aqui se propõe for a observância de uma certa regra ético-religiosa, parecerão agora relevantes certos fatos e se propõe uma certa solução; se, pelo contrário, o fim for o controle do crescimento demográfico, outros fatos parecerão relevantes e se propõe uma outra solução.^[169]

Paulo Gustavo Gonet Branco lembra ainda que Carl Schmitt, na famosa palestra sobre a *tiranía dos valores*,

põe-se de acordo com Weber em que é “o indivíduo humano quem estabelece os valores, com liberdade de decisão completa e puramente subjetiva.” Daí repelir o uso da teoria dos valores como método de interpretação e aplicação do Direito. O processo de preferir um valor a outro é entendido como insuscetível de qualquer rigor conceitual e lógico, traduz-se como simples manifestação de interesses subjetivos, expressando mera disposição pessoal de quem é plenamente livre para valorar como quiser, tornando-se, por fim, sempre apto para gerar mais dissenso e insubordinação.^[170]

No nosso *Neoconstitucionalismo e verdade: limites democráticos da jurisdição constitucional*, com maior aprofundamento, adotamos um relativismo ou não-cognitivismo moderado, de onde fizemos derivar a necessidade de *autocontenção* da Corte Constitucional, na modalidade de uma *reserva epistêmica*.^[171]

Os princípios são normas jurídicas eficazes e que podem resolver muitos casos, até sem intermediação das regras, dentro de parâmetros valorativos e racionais aceitáveis por todos. Mas, na sua relativa indeterminação, eles não teriam suficiente “densidade normativa” para resolver todas as questões - numa suposta completude que já se chamou de *holismo* constitucional. [\[172\]](#)

A Interpretação do Direito

Parte III

1. Interpretação e hermenêutica. Conceito e relação com a Filosofia do Direito

1.1. Conceito

A interpretação não é uma realidade exclusiva do direito. O homem é um ser que se comunica com os demais através da linguagem, e mesmo consigo próprio, pois a linguagem é a ferramenta do pensamento, se não se confunde com ele. A linguagem, por sua vez, é constituída de *signos* – e os signos são coisas, como palavras, gestos, desenhos, que significam outras coisas. O signo sempre remete a algo diferente de si. Ferdinand de Saussure irá fixar a distinção, dentro do signo linguístico, entre significante e significado, sendo o significante a parte material do signo, como a palavra falada, e o significado aquilo a que o signo remete. Para Saussure, o signo linguístico é arbitrário, isto é, entre o som da palavra “cadeira” e o objeto que designa não há qualquer relação de similitude, mas mera convenção arbitrária.^[173] Existem outros signos, que não os linguísticos, como os *símbolos*, em que a relação entre o significante e o significado não são totalmente arbitrárias; assim, a pomba é símbolo da paz e não o leão, que o é da força. Mas mesmo aqui, e na metáfora em geral, que também se baseia na semelhança, existe uma grande margem de liberdade e subjetividade.

Assim, o direito, ao se expressar através da linguagem natural, traz para si toda a problemática da interpretação linguística. Mas não é só. As imprecisões do direito e as interpretações necessárias não se devem apenas às imprecisões da linguagem, pois incluem relações de poder – por exemplo, a *vontade* do legislador –, conceituação de fatos, reflexões sobre os valores e finalidades da lei, etc.

Enfim, a interpretação é sempre um procedimento necessário para fazer falar o signo ou o significante e obter-se o significado. Segundo Maximiliano, “*pode-se procurar e definir a significação de conceitos e intenções, fatos e indícios; porque tudo se interpreta, inclusive o silêncio.*”^[174]

É comum dizer-se, em direito, que a interpretação objetiva *definir o sentido e o alcance da norma*. O sentido e o alcance têm relação estreita, mas o primeiro seria uma espécie de significado ideal, capaz de aplicar-se a determinada extensão da realidade, o alcance. A distinção pode remeter àquela clássica em filosofia da linguagem entre a *intensão* (com *s*) e a *extensão* do conceito.

Por fim, a hermenêutica seria a “ciência” da interpretação ou o seu estudo teórico. A interpretação, pois, é atividade prática, necessária ao uso da fala, ao direito, à literatura, enquanto a hermenêutica é a disciplina que a estuda, define suas espécies, classificações, limites, etc.

1.2. A relação da interpretação com as correntes jusfilosóficas

Pelo que estudamos das correntes jusfilosóficas, percebe-se que seus postulados podem guardar relação com o tema da interpretação do direito. Cada corrente tenderá a encarar a interpretação jurídica de determinada maneira. Mais que isso, os problemas acarretados pela interpretação podem modular os próprios conceitos de uma determinada corrente. De forma mais ou menos esquemática, podemos estabelecer as seguintes relações entre as correntes da Filosofia do Direito e a interpretação jurídica:

- O *positivismo jurídico*, com sua teoria das fontes, confere um lugar mais limitado à interpretação. Esta não é totalmente livre, está limitada justamente pelo texto da constituição e das leis. Haveria uma preponderância do método *verbal* de interpretação, que veremos adiante. Contudo, o positivismo admite que o aplicador da lei, sobretudo o juiz, tenha alguma margem de manobra interpretativa. Assim, Kelsen fala de uma *moldura* da lei na qual o intérprete se move com uma margem maior ou menor de livre apreciação.^[175] Hart também admite que algumas vezes o direito apresenta uma *textura aberta*, uma zona de *penumbra*, conferindo ao juiz nesses casos maior liberdade interpretativa ou mesmo uma liberdade semelhante à do legislador, o que ele chama de discricionariedade.^[176]
- Podemos estimar que, no *jusnaturalismo*, o intérprete estaria autorizado a buscar a solução justa sem se ater de forma tão rigorosa ao texto da lei. A conexão entre direito e moral ou direito e justiça, admitida pelo jusnaturalismo, levaria o intérprete a descobrir a *finalidade* da lei ou do direito em geral, privilegiando o método teleológico de interpretação. Assim, o intérprete possui, ao menos aparentemente, uma margem maior de liberdade, pois perscruta além do direito positivo, mas o resultado da interpretação exige a solução justa para o caso, e em geral isso significa uma única solução, ou uma que é melhor que as demais;
- Para o *realismo jurídico*, a atividade interpretativa do aplicador da lei não tem limites, ou porque se concebe que ele não está submetido normativamente ao texto legal, ou por considerar que a interpretação é sempre por definição inovadora. Assim, diríamos que a interpretação não é para o realismo uma preocupação, pois para esses autores o aplicador da lei não tem um compromisso com o texto legal.

- O *pragmatismo jurídico*, que comunga alguns dos postulados do realismo, tem contudo uma abordagem mais *normativa*, daquilo que o direito deve ser e do que o juiz deve fazer. Assim, para essa corrente, são importantes as *consequências* da decisão, do ponto de vista social, econômico, etc, podendo-se pensar que tal concepção irá influenciar na atividade interpretativa.
- Por fim, o neoconstitucionalismo, diante da realidade principiológica das constituições atuais, confere ao intérprete um papel de maior abrangência. Ele trabalharia com um material normativo mais amplo ou, no dizer de Alexy, *aberto*, os princípios. Para Dworkin, os princípios têm natureza política e moral, o que confere ainda maior amplitude à interpretação. Para Alexy, os princípios constitucionais são mandamentos de otimização, possuem estrutura distinta das regras, exigindo do intérprete e aplicador o *sopesamento* ou ponderação entre eles. Contudo, diferentemente do realismo jurídico, a maior liberdade diante do texto não significa discricionariedade do juiz. Para Dworkin, aliás, ele não a possui, devendo buscar a “única solução correta” para o caso; para Alexy, embora não concorde com a tese da única solução correta, a interpretação deve valer-se de procedimentos racionais, como a aplicação do princípio da proporcionalidade, com vistas a diminuir a arbitrariedade da decisão.

Alguns autores consideram que o positivismo jurídico não possui uma teoria da interpretação, notadamente quando o juiz se encontra no espaço de liberdade da *moldura* da norma (Kelsen) ou da *textura aberta* do direito (Hart), quando então operaria com discricionariedade. A essa discricionariedade no âmbito de abertura do direito opõem-se tanto Dworkin quanto Alexy. [\[177\]](#)

Jean-Yves Chérot põe em evidência esse aspecto ao tratar do positivismo exclusivo, aduzindo que essa corrente “*não dá qualquer direção sobre o que o juiz deve fazer em termos de argumentação jurídica, sobretudo nos casos difíceis.*” [\[178\]](#) Essas considerações seriam aplicáveis, ainda com maior razão, ao realismo jurídico.

2. Classificação e métodos de interpretação

2.1. Interpretação autêntica e doutrinal

Uma classificação tradicional da interpretação refere-se à sua origem, de onde ela provém. Assim, fala-se em *interpretação autêntica* e *interpretação doutrinária*.

A interpretação autêntica viria do próprio legislador. Este, através de uma lei ou decreto legislativo posterior à lei objeto da controvérsia, disporia sobre a interpretação correta do dispositivo.

A interpretação autêntica está ligada ao fortalecimento do positivismo jurídico como concepção do direito dominante no século XIX. Ela pressupõe que o direito só pode emanar do Legislativo e que os juízes não poderiam interpretar a lei, sob pena de usurpar a função legislativa e colocar-se em patamar de superioridade ao legislador. Essa concepção era tão arraigada nessa época que as legislações de diversos países previam que se, em determinado caso, o juiz tivesse dúvida sobre a interpretação da lei, deveria suspender o julgamento e submeter a questão ao parlamento. Maximiliano dá conta de que, na França, vigeu até 1837 a figura do *référé au législateur*, que consistia na interrupção do julgamento para consulta e obtenção da interpretação autêntica.^[179]

Uma das consequências do conceito de interpretação autêntica é que o ato que a veicule terá aplicação retroativa; sendo meramente interpretativo, retroagirá à data da lei interpretada. É o que vemos, por exemplo, no art. 106, I, do nosso Código Tributário Nacional.^[180]

A *interpretação doutrinária* seria aquela realizada pela doutrina, sem poder de vincular o aplicador do direito.

Registre-se aqui, por oportuno, que Kelsen considera que o intérprete autêntico é o juiz, pois, ao aplicar a lei, dentro de sua moldura, ele concretiza o ordenamento jurídico e cria normas de natureza individual que integram o sistema.

2.2. Métodos de interpretação

De suma importância para essa matéria, a doutrina elenca alguns métodos ou processos de interpretação do direito. Seriam eles:

- Verbal, gramatical ou filológico;
- Lógico;
- Sistemático;
- Histórico;
- Teleológico, axiológico;
- Sociológico.^[181]

Por vezes, os autores divergem nessa enumeração, suprimindo alguma das espécies citadas ou englobando-as nas outras.

Assim, temos que o método *gramatical* objetiva chegar ao significado correto da norma através de uma análise linguística que abrange a semântica e a gramática. É considerado o método mais tradicional e conservador e foi o preferido da escolástica medieval.

Apesar de a análise gramatical conter alguma lógica, o método *lógico* vai além, pois pretende evitar contradições na interpretação e, portanto, considera os demais aspectos da lei, contidos no próprio artigo interpretado, na lei em que ele se insere ou em outros âmbitos do sistema jurídico. Por essa razão, o método lógico guarda relação com o *sistemático*, que busca uma interpretação harmônica do dispositivo em relação ao conjunto do ordenamento jurídico.

O método *histórico* apresenta dois aspectos. Um deles prende-se à pesquisa da vontade do legislador, buscando inteirar-se do contexto em que a lei foi produzida e mesmo dos trabalhos preparatórios do texto legal, como os debates parlamentares. Outro aspecto procura entender a lei no seu evoluir histórico, as suas origens, as leis que lhe antecederam sobre a matéria em estudo, as razões das modificações, etc.

O método *teleológico* apresenta-se como uma fase ulterior, mais avançada, da hermenêutica. Aqui se busca não a vontade do legislador histórico, mas a vontade da lei. Um passo importante para a jurisprudência foi abandonar a pergunta sobre “*o que quis o legislador?*” e substituí-la por “*o que quereria o legislador diante desse caso concreto, de que ele não cogitou expressamente?*”. Passou-se, pois, a pesquisar os *fins* (*telos*) da lei e priorizar uma solução para o caso concreto conforme a essa finalidade, mais do que à literalidade do dispositivo. Aqui entra a metáfora *letra x espírito da lei*, consubstanciada na máxima de São Paulo *littera occidit, spiritus*

vivificat (a letra mata, o espírito vivifica). Esse tipo de interpretação às vezes é chamado de *axiológica*, realizada a partir dos *valores* albergados pela lei, notando-se a proximidade entre os conceitos de finalidades e valores.

O método *sociológico* mostra-se próximo do teleológico e em algumas classificações não aparece. Aqui também se opta por deixar de lado a letra do dispositivo e buscar uma interpretação adaptada à evolução social e aos “fins sociais” buscados pela legislação e consagrados no art. 5º da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/1942).

A discussão sobre tais métodos continua extremamente presente na doutrina e na aplicação do direito. Um exemplo pode ter-se na polêmica norte-americana acerca da interpretação constitucional, tendo-se no *originalismo* do *justice* Antonin Scalia uma defesa da interpretação de acordo com a vontade dos constituintes e, portanto, de natureza histórica.

Um dos problemas, contudo, dos métodos de interpretação, é que não existe regra a respeito de sua própria utilização, como qual deve ser o método a preponderar em cada caso. ^[182]

Isto significa dizer que *não existe hierarquia* entre esses métodos, como reconhece Alexy; ele admite, contudo, que a especificidade da argumentação jurídica privilegia os métodos semântico e genético (*que corresponderiam aos métodos verbal e histórico na classificação fornecida acima*), de maneira que eles podem ser superados, mas transferem um ônus especial a quem argumenta em contrário. ^[183]

Por fim, temos que em algumas áreas do direito, contudo, a necessidade de uma interpretação estrita recomenda o método verbal ou gramatical, como no Direito Penal em relação aos tipos incriminadores.

2.3. Classificação quanto ao alcance da interpretação

Quanto a esse aspecto, diz-se que a interpretação pode ser extensiva, restritiva ou declarativa.

Quanto à interpretação declarativa, ela não ampliaria nem restringiria o quanto foi expresso pelo legislador. De há muito se rejeita a existência de uma interpretação meramente declarativa, pois ela não traria nada de novo e, portanto, não faria sentido. Pela mesma razão, não goza na doutrina de muito respaldo o brocardo latino “*in claris cessat interpretatio*”; a interpretação é sempre necessária e é ela que torna clara determinada disposição legal.^[184] Contudo, deve-se tomar a ressalva *cum grano salis*, pois o brocardo a nosso ver continua a ter significado relevante.

Na interpretação extensiva, estende-se seu alcance para abarcar uma situação que a norma não previu de forma expressa, considerando-se, contudo, que o legislador pretendeu abrangê-la, dizendo menos do que queria (*lex dixit minus quam voluit*).

Na interpretação restritiva, ao contrário, restringe-se o alcance da norma, evitando que abranja determinada situação, entendendo-se também que foi essa a vontade do legislador, que teria dito *mais* do que queria efetivamente (*lex dixit plus quam voluit*). Essa técnica é muito utilizada naquelas matérias sob reserva de lei, como o direito penal e o tributário, com o fim de evitar que a interpretação acabe por criar outras figuras e com isso fragilize as garantias individuais.

3.A superação dos métodos de interpretação mediante puro raciocínio lógico-dedutivo

O positivismo jurídico teve seu auge no século XIX e, em termos de interpretação, fazia valer os cânones de respeito à vontade do legislador, buscada através dos métodos gramatical e histórico, quando não se valendo do recurso da interpretação autêntica.

Contudo, o século XIX presenciou grandes mudanças sociais, com o aprofundamento da revolução industrial e tecnológica, o avanço da ciência em todos os níveis e, no campo social, o surgimento da “questão operária”, com a organização dessa classe em sindicatos para defender os seus interesses. Também se difundiu a sociedade de consumo, e além do operário aparece o consumidor como pessoa necessitada da proteção legal e estatal. Por fim, o avanço da sociedade em todos os níveis acarretou também mudanças culturais expressivas, influenciando nas relações familiares e de gênero, com a progressiva afirmação social das mulheres.

O direito não podia permanecer indiferente a tudo isso e, como as reformas legislativas demoravam – e geralmente demoram, vindo muitas vezes depois dos fatos e mesmo das mudanças jurisprudenciais –, doutrina e jurisprudência começaram a afastar-se dos cânones ou métodos exegeticos até então vigentes. A superação dos métodos tradicionais de interpretação, gramatical, lógico, histórico, em direção a uma hermenêutica teleológica e valorativa começou já na segunda metade do século XIX e desabrochou na primeira metade do século XX, com autores como François Geny, Edmond Picard, Eugen Ehrlich.

Entre nós, abraça essas correntes renovadoras, já na terceira década do século XX, Carlos Maximiliano, dando conta da superação dos métodos tradicionais pelo que chama ora de método teleológico, ora sociológico, corrente histórico-evolutiva ou simplesmente método evolutivo, referindo-se às escolas francesa da *Libre recherche* e alemã do *Direito justo (Richtiges Recht)*. Vislumbra-se no nosso autor forte influência sociológica de autores como Auguste Comte e Spencer, chegando à concepção do intérprete como sociólogo do direito, “*adaptador das fórmulas vetustas às contingências da hora presente.*”^[185].

Exemplo simples de como a interpretação do direito sofre os influxos das mudanças sociais e culturais pode ser constatado em conceitos jurídicos com carga valorativa, como *mulher honesta*. A menção era elemento de alguns tipos penais e, mesmo antes de sua supressão do Código Penal, já exigia interpretação que levasse em conta a evolução da moral e dos costumes depois do advento da lei.

3.1. O método de interpretação pela lógica do razoável

As muitas mudanças operadas e o afastamento dos cânones positivistas mais extremados colocaram para os juristas a questão das especificidades, mas também dos limites da atividade do intérprete e aplicador do direito, notadamente do juiz. Superados os métodos tradicionais, gramatical e histórico, que em geral tinham como diretriz a vontade do legislador, como entender e legitimar a atuação mais livre dos juízes na conformação do sistema jurídico?

Essas respostas surgem inicialmente como “*a lógica do razoável*”, em meados do século XX, com reflexo direto nas teorias contemporâneas do direito. O direito não trabalharia com a racionalidade da lógica formal, mas com a ideia de razoabilidade própria da *razão prática*, expressão utilizada por Kant para se referir ao âmbito da moral, do direito e da estética, em contraposição à *razão pura* da matemática e da geometria. Vão nesse sentido a tópica de Theodor Viehweg, os trabalhos de Toulmin, bem como as obras do polonês, naturalizado belga, Chaïm Perelman e do jusfilósofo espanhol, nascido na Guatemala, Luis Pedro Alejandro Recaséns Siches.

Um exemplo de como a lógica formal é insuficiente à aplicação do direito é dado por Radbruch.^[186] O autor alemão relata caso em que, numa estação ferroviária da Polônia, havia um cartaz proibindo a entrada de pessoas acompanhadas de cachorro. Certa vez quis adentrar ao local um homem acompanhado de um urso, no que foi impedido pelo agente, protestando o usuário, contudo, por não estar a hipótese prevista no cartaz. Problema parecido ensejaria a possibilidade de entrar no local um cego acompanhado por seu cão-guia. A singela ilustração demonstra que a aplicação do direito não pode valer-se unicamente da lógica formal e da rigorosa subsunção de fatos à norma, na modalidade de um silogismo. A lei é sempre dotada de uma finalidade e valor que não podem ser olvidados no momento da aplicação.

Perelman tem sua formação e estudos iniciais voltados para a lógica formal e não para o direito. Mas passa em seguida a estudar o raciocínio e a argumentação jurídica, tentando relacioná-los com seus estudos de lógica. Chega à conclusão de que se deve diferenciar a *lógica formal* da *lógica argumentativa*, do que já falava Aristóteles nos seus trabalhos sobre a retórica.

A lógica formal, que tem sua aplicação preferencial na matemática, objetiva realizar *demonstrações*, raciocínios construídos a partir de premissas gerais, pelo método dedutivo. A partir de uma premissa inquestionável, chega-se a conclusões também por assim dizer “coercitivas” em termos de pensamento.

Já a lógica argumentativa não pode pretender à demonstração de suas teses da mesma maneira; ela orienta-se não pela verdade absoluta, mas pelo *plausível, convincente, razoável*. Na lógica formal, a *racionalidade* demonstra a verdade de um postulado ou consequência. Na lógica argumentativa, a *razoabilidade* convence sobre a preferência de um determinado ponto de vista. Citando Comparato, Eros Roberto Grau afirma que o intérprete atua segundo a *lógica da preferência*, e não conforme a *lógica da consequência*: a lógica jurídica é a da escolha entre várias possibilidades corretas. ^[187]

O que Perelman pretende é *não renunciar à razão* no âmbito da política, da moral e do direito. Não se aplicaria ao direito o raciocínio lógico-dedutivo da lógica formal, mas não se poderia simplesmente abrir mão da razão e aceitar quaisquer argumentos como equivalentes. A razão aqui assumiria então o papel de *razão prática*, com suas especificidades, mas ainda assim razão. Perelman encerra uma palestra proferida na Sociedade Francesa de Filosofia afirmando acreditar numa sociedade que se fundamente na razão, “*ou seja, a um só tempo, nas demonstrações racionais e nas argumentações razoáveis.*” ^[188]

Linha de pensamento em tudo semelhante é seguida por Recaséns Siches. Ainda reconhecendo lugar para a lógica no mundo do direito, Siches forja a expressão “lógica do razoável” ou “lógica do humano”. Enquanto as questões valorativas estão ausentes na lógica formal, aqui elas seriam inarredáveis, de maneira que “*a lógica do humano ou do razoável é uma razão impregnada de pontos de vista estimativos, de critérios de valoração, de pautas axiológicas(...)*” ^[189]

Recaséns Siches considera que a lógica do razoável dirige-se ao legislador e aos juízes, que ao adotá-la darão cumprimento ainda mais fiel às disposições legislativas. O mesmo ele diz em relação à equidade, considerando que o legislador elabora normas gerais e tendo em vista situações habituais, não sendo elas aplicáveis quando o caso for distinto ou quando sua aplicação produzir resultados opostos aos que a lei desejou. A *apreciação do resultado* da interpretação é aspecto importante para Siches e para o que Maximiliano chamou de corrente evolutiva da hermenêutica.

3.2. Teorias modernas da argumentação jurídica

A argumentação jurídica e os seus limites continuaram a ser objeto de profundos debates na Filosofia do Direito, na segunda metade do século XX. Teorias como a de Perelman estiveram ligadas a um repúdio decidido ao positivismo jurídico, associado por muitos à ascensão do nazismo, embora os positivistas rejeitem tal associação, como já visto. Os filósofos do direito permaneceram refletindo sobre a relação da argumentação com o direito positivo, suas possibilidades e limites.

Manuel Atienza conclui sua reflexão a respeito da argumentação jurídica, respaldando as teses de dois autores, Robert Alexy, já estudado na Parte II e Neil MacCormick (1941-2009), filósofo do direito escocês. Apesar de pertencerem a campos diversos da filosofia jurídica, MacCormick sendo considerado um positivista, Atienza considera próximas as conclusões de ambos a respeito da argumentação.^[190]

MacCormick preocupa-se com a obediência do juiz ao direito legislado, sem, contudo, deixar de reconhecer uma margem relevante para argumentos morais e consequentialistas. Assim, ao contrário de Perelman, que recusa a lógica dedutiva em matéria jurídica, MacCormick a vê presente, no que chama de justificação interna da decisão judicial. Na justificação interna, que sustenta o próprio raciocínio da decisão, a lógica formal deve estar sempre presente, sejam quais forem as premissas adotadas pelo juiz. Contudo, além desse tipo de justificação, é necessária uma *justificação externa*, baseada na consistência e na coerência da decisão. A consistência diz respeito às premissas normativas adotadas, enquanto a coerência apresenta um aspecto normativo e outro narrativo. A coerência normativa deve levar em conta que o direito é uma empresa racional e deve estar de acordo com a noção de universalidade, como componente da racionalidade, enquanto a coerência narrativa oferece um teste com relação a questões de fato.^[191]

Por sua vez, Alexy parte da *teoria do discurso prático* de Habermas, que de alguma forma reproduz as diferenças apontadas acima entre a razão pura e a razão prática. Como já visto, para Alexy o discurso jurídico seria um caso especial do discurso prático geral, isto é, do discurso moral, com algumas condições específicas de validade, como os limites postos pelo ordenamento jurídico positivo.

A posição de Habermas, como a de Alexy, seria a de preservar a racionalidade no âmbito do discurso prático, moral, jurídico e político. Para tanto, entendem que é preciso assegurar condições ideais em que o debate de opiniões deve ser travado – como as exigências de simetria entre os participantes e de liberdade –, de maneira a chegar-se a uma solução racional.

Alexy, contudo, não crê, como Dworkin, que exista apenas uma “única resposta correta” para as questões jurídicas problemáticas, reconhecendo limites ao discurso jurídico. Ele repudia o que chama de “teoria forte” dos princípios, adotada por Dworkin, que conteria todas as relações de prioridade entre eles, abstratas e concretas.^[192] Contudo, embora reconheça em algum nível a subjetividade da ponderação, Alexy não desacredita o discurso e a argumentação jurídica, pois, se não são capazes de identificar a única resposta correta, têm ao menos o condão de funcionar negativamente, identificando e afastando respostas inadmissíveis.

MacCormick, da mesma forma, busca uma via intermediária entre o ultrarracionalismo de Dworkin e o ceticismo de Ross^[193], defendendo a racionalidade da argumentação, mas também seus limites. Nas palavras de Atienza, o autor escocês entende que

em algum estágio da argumentação jurídica se chega a escolhas últimas (por exemplo, entre critérios de justiça, de utilidade ou de oportunidade), a favor dos quais se pode, evidentemente, apresentar razões, mas que não são razões concludentes, na medida em que se supõe estarem situadas num nível pré-racional ou extra-racional.^[194]

4. Teoria do ordenamento jurídico. Integração do direito

Aspecto também ligado à interpretação do direito é a teoria do ordenamento jurídico que, segundo Bobbio, foi uma contribuição do positivismo jurídico à teoria geral do direito.^[195] Apesar de situar-se num nível epistemológico distinto dos debates que acabamos de analisar, pois, como dito, representa postulações quicá normativas do positivismo, a teoria do ordenamento jurídico tem evidente utilidade na aplicação do direito.

Ao fixar a lei como fonte prioritária do direito, o positivismo desenvolveu a teoria do ordenamento jurídico, baseada em três caracteres fundamentais: ***a unidade, a coerência e a completude ou completitude.***

A unidade do ordenamento jurídico confunde-se de certa forma com a coerência, no sentido de que o sistema é uno, não admitindo contradições. Para Kelsen, a unidade manifesta-se sobretudo na concepção dinâmica do ordenamento, em que as normas se dispõem de forma hierárquica e escalonada. Cada norma é válida em razão de uma norma superior que atribuiu competência a determinada autoridade ou órgão para editá-la, esta norma superior encontrando ela mesma seu fundamento numa outra norma que lhe é superposta, e assim por diante, até chegarmos à norma fundamental.

A coerência, como dito, decorre da unidade do ordenamento jurídico, de maneira a não existir contradições entre as diversas normas que o integram. Este princípio nega que possa haver *antinomias*, isto é, normas incompatíveis entre si, buscando-se critérios capazes de dissipar as (aparentes) contradições. Tais critérios são os seguintes:

- Critério *cronológico*, segundo o qual a norma posterior prevalece sobre a norma precedente (*lex posterior derogat priori*);
- Critério *hierárquico*, segundo o qual a norma de grau superior, isto é, estabelecida por uma fonte superior, prevalece sobre aquela de grau inferior (*lex superior derogat inferiori*);
- Critério da *especialidade*, de acordo com o qual a norma especial prevalece sobre a geral (*lex specialis derogat generalis*).

Por fim, pelo princípio da completude, o ordenamento jurídico ou não apresenta lacunas, como sustentaram alguns autores, ou provê os meios para que tais lacunas sejam colmatadas.

São duas as principais teorias que negam a existência de lacunas no ordenamento. São elas:

- *A teoria do espaço jurídico vazio*, desenvolvida por Bergbohm e sustentada por Santi Romano. De acordo com este entendimento, o que não está previsto nas normas não diz respeito ao direito, é-lhe indiferente, não se podendo falar em incompletude.
- *A teoria da norma geral exclusiva*, de Zitelmann e retomada por Donati. Para esta teoria, a cada norma jurídica efetivamente existente subjaz uma norma implícita – que seria a *norma geral exclusiva* – que diz não se aplicar aquela disposição a qualquer outra situação que não a prevista na norma, de maneira que todas as situações estariam automaticamente reguladas pelo direito.

Para a maioria dos autores, contudo, as lacunas podem existir, demandando um procedimento de *integração* por parte do juiz, que deve decidir esses casos com base na analogia, nos costumes, nos princípios gerais de direito e, em alguns casos, quando autorizado por lei, por equidade.

BIBLIOGRAFIA

ALEXY, Robert. *Conceito e validade do direito*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

_____. *Teoria dos direitos fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2015.

ARISTÓTELES. *Éthique à Nicomaque*. Le livre de poche, 1992.

_____. *Ética a Nicômaco*. São Paulo: Edipro, 2014.

ATIAS, Christian. *Philosophie du droit*. Paris: PUF, 1999.

ATIENZA, Manuel. *As razões do direito: teorias da argumentação jurídica*. São Paulo: Landy Editora, 2006.

AUSTIN, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

BARROSO, Luís Roberto. *Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo*. 2a.ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

BOBBIO, Norberto. *O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito*. São Paulo: Ícone Editora, 2006.

BONELLA, Alcino Eduardo. A ética do aborto. *Revista Filosofia*, São Paulo, Ed. Escala, Ano VI, n. 65.

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Juízo de ponderação na jurisdição constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2009.

CELLA, José Renato Graziero. Realismo jurídico norte-americano e ceticismo. Disponível em http://www.cella.com.br/conteudo/conteudo_28.pdf. Acesso em 27/04/2013.

CHEROT, Jean-Yves. Le debat sur le juspositivisme entre Raz et Alexy. *Droit & Philosophie* 9 (2018/2).

COMTE-SPONVILLE, André. *Petit traité des grandes vertus*. Paris: Presses Universitaires de France, 1995.

_____. *Pequeno tratado das grandes virtudes*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

_____. *Valor e verdade*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

DIMOULIS, Dimitri. *Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-político*. São Paulo: Método, 2006.

DREIER, Ralph. *Recht – Moral – Ideologie*. Frankfurt: Suhrkamp, 1981.

DROIT, Roger-Paul. *Ética: uma primeira conversa*. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

_____. *O império do direito*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

EDMONDS, David. *Would you kill the Fat Man?: the Trolley Problem and What Your Answer Tells Us about Right and Wrong*. Princeton: Princeton University Press, 2014.

FERRAJOLI, Luigi. O Estado de Direito entre o passado e o futuro. In: COSTA, Pietro e ZOLO, Danilo (orgs). *O Estado de Direito: história, teoria, crítica*. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 417-464.

_____. Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. In: FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (orgs). *Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

FINNIS, John. *O direito natural em Tomás de Aquino: sua reinserção no contexto do juspositivismo analítico*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2007.

FONTES, Paulo Gustavo Guedes. *Neoconstitucionalismo e verdade: limites democráticos da jurisdição constitucional*. 3ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

_____. Limites do direito diante da autonomia moral do indivíduo: os riscos do máximo ético, *Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região*, ano XXIV, n. 116, São Paulo, jan./mar. 2013, p. 69-82.

_____. *Pílulas de Filosofia do Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. (no prelo)

_____. Holismo constitucional x discricionabilidade legislativa. In: GRANDINO RODAS, João; ATTÍE JUNIOR, Alfredo. (Orgs.). *30 anos da Constituição Federal: retrospectiva, avanços e desafios*. 1ªed. São Paulo: CEDES: Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, 2018, v. 1, p. 561-574.

FOOT, Philippa. The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect. *Oxford Review*, nº.5, 1967.

GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Ser o no ser normativo: um dilema para el positivismo jurídico. In: DIMOULIS, Dimitri ; DUARTE, Écio Oto (Coord.). *Teoria do direito neoconstitucional: superação ou reconstrução do positivismo jurídico?* São Paulo: Editora Método, 2008, p. 79-101.

GRAU, Eros Roberto. *Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do direito e os princípios*. São Paulo: Malheiros, 2013.

GREEN, L. Legal positivism. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disponível em: <<http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/>>. Acesso em 15/07/2020.

GUEDES, Néviton. A importância de Dworkin para a teoria dos princípios. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012-nov-05/constituicao-poder-ronald-dworkin-teoria-principios>

HART, H.L.A. *O conceito de direito*. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

_____. Positivism and the Separation of Law and Morals. *Havard Law Review*, vol. 71, 1958, p. 593-629.

_____. *Direito, liberdade, moralidade*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1987.

HÖFFE, Otfried. *Justiça política*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

IHERING, Rudolf Von. *A luta pelo direito*. São Paulo: Rideel, 2005.

KELSEN, Hans. *Teoria pura do direito*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

_____. *A justiça e o direito natural*. Coimbra: Almedina, 2001.

_____. *O que é justiça? A Justiça, o Direito e a Política no espelho da ciência*. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

LYCURGO, Tassos; ERICKSEN, Lauro. *Filosofia do direito para concursos da magistratura*. São Paulo: Edipro, 2011.

MARMOR, Andrei. Legal positivism: still descriptive and morally neutral. Disponível em: < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=763844## >. Acesso em 15/07/2020.

MACKIE, J. L. *Ethics: Inventing Right and Wrong*. London: Penguin Books, 1990.

MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. Kelsen contra o Estado. In: MATOS, Andityas Soares de Moura Costa; SANTOS NETO, Arnaldo Bastos (Coord). *Contra o absoluto: perspectivas críticas, políticas e filosóficas da obra de Hans Kelsen*. Curitiba: Juruá, 2011.

_____. Positivismo jurídico e autoritarismo político: a falácia da *reductio ad Hitlerum*. In: DIMOULIS, Dimitri; DUARTE, Écio Oto (Coord.). *Teoria do direito neoconstitucional: superação ou reconstrução do positivismo jurídico?* São Paulo: Editora Método, 2008, p. 103-127.

MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

MONTAIGNE, Michel de. *Ensaaios: que filosofar é aprender a morrer e outros ensaios*. Porto Alegre: LP&M, 2017.

MORRISSON, Wayne. *Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo*. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

NINO, Carlos Santiago. *La validez Del derecho*. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2012.

PERELMAN, Chaïm. *Ética e direito*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

PINTO, Rafael da Silva. *A filosofia de Iris Murdoch: peregrinação moral em busca do bem*. São Paulo: Anna Blume, 2011.

POSCHER, Ralph. Insights, Errors and Self-Misconceptions of the Theory of Principles. *Ratio Juris* 22 (2009/4), p. 225/254.

POSNER, Richard. *A problemática da teoria moral e jurídica*. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

PUTNAM, Hilary. *O colapso da verdade e outros ensaios*. São Paulo: Ideias e letras, 2008.

RAZ, Joseph. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford : Clarendon Press, 1979.

REALE, Miguel. *Filosofia do direito*. São Paulo: Saraiva, 2002.

RICOEUR, Paul. *Em torno ao político*. São Paulo: Edições Loyola, 1995.

SABADELL, Ana Lucia. *Manual de Sociologia Jurídica: introdução a uma leitura externa do direito*. 2ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002.

SALDANHA, Nelson. *Filosofia do direito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

SANCHÍS, Luis Prieto. *Justicia constitucional y derechos fundamentales*. 2ª edição. Madri: Editorial Trotta, 2009.

SAUSSURE, Ferdinand. *Curso de linguística geral*. São Paulo: Editora Cultrix, 1969.

SQUELLA, Agustín. *Positivismo jurídico, democracia y derechos humanos*. México: Distribuciones Fontanamara, 1998.

TOMASZEWSKI, Adauto. A Lógica do Razoável – um ensaio sobre o pensamento de Recaséns Siches e a atuação do operador do direito. *Rev. de Ciênc. Jur. e Soc. Unipar*, n. 1, vol. 1: jul/dez. 1998, P. 121-139.

TRINDADE, André Karam. Crítica à imprecisão da expressão neoconstitucionalismo. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2013-jan-19/diario-classe-critica-imprecisao-expressao-neoconstitucionalismo>>. Acesso em 10/12/2013.

TROPER, Michel. *A filosofia do direito*. São Paulo: Martins Fontes (coleção Tópicos Martins), 2008.

WALDRON, Jeremy. *Law and Disagreement*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

_____. *A dignidade da legislação*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

WALKER, Ralph. *Kant: Kant e a lei moral*. São Paulo: Editora Unesp, 1999.

WEBER, Max. *Ciência e Política: duas vocações*. São Paulo: Martin Claret, 2011.

WERLE, DenilsonLuis. O liberalismo contemporâneo e seus críticos. In: RAMOS, Flamarion Caldeira; MELO, Rúrion; FRATESCHI, Yara. *Manual de filosofia política*. São Paulo: Saraiva, p. 259-284

- [1] IHERING, Rudolf Von. *A luta pelo direito*. São Paulo: Rideel, 2005, p. 8.
- [2] WEBER, Max. *Ciência e Política: duas vocações*. São Paulo: Martin Claret, 2011, pp. 115; 119.
- [3] HART, H.L.A. *O conceito de direito*. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 118-128.
- [4] Kelsen, Hans. *Teoria pura do direito*. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 235-238. A importância que Kelsen confere à eficácia social das normas, ainda que como condição e não causa da validade, parece-nos significativa. Mesmo em considerando o direito um sistema de normas postas pelo Estado, haveria aí em certa medida uma concessão às outras maneiras de concebê-lo, seja às correntes sociológicas, como o sociologismo e o realismo jurídico, seja ao próprio jusnaturalismo. Isso porque podemos pensar que a norma totalmente ineficaz e, por isso, segundo Kelsen, inválida, seria aquela que não passou no teste de conformidade em relação à consciência e moralidade social.
- [5] ALEXY, Robert. *Conceito e validade do direito*. São Paulo: Martins Fontes, 2009, pp. 101-104; 108. Cf. também ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 61. O autor remete ainda a DREIER, Ralph. *Recht – Moral – Ideologie*. Frankfurt: Suhrkamp, 1981, p.194 e ss.
- [6] REALE, Miguel. *Filosofia do direito*. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 493-494.
- [7] RICOEUR, Paul. *Em torno ao político*. São Paulo: Edições Loyola, 1995, p. 161.
- [8] DROIT, Roger-Paul. *Ética: uma primeira conversa*. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 43-52.
- [9] PERELMAN, Chaïm. *Ética e direito*. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 81. Sobre o tema da vinculação entre ética e religião, lembre-se a frase atribuída a Dostoiévski: “*Se Deus não existe, tudo é permitido*.” E a variação de Lacan, talvez se referindo ao fato de a religião ter muitas vezes servido para justificar a prática de atos desumanos: “*Se Deus existe, tudo é permitido!*”.
- [10] Esse é o domínio da *metaética*, que estudamos, em correlação com o neoconstitucionalismo, no nosso *Neoconstitucionalismo e verdade: limites democráticos da jurisdição constitucional*. 3ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. Recomendamos ao leitor a consulta dessa nossa obra para um aprofundamento dos temas aqui tratados.
- [11] Kant teria adotado também a distinção formulada por Hume, com outra nomenclatura, ao diferenciar os juízos sintéticos (juízos de fato) e analíticos (juízos de valor, matemáticos, etc). Hilary Putnam contesta a lei de Hume, destacando que os fatos, como definidos pelas ciências, já comportam muitas vezes valorações e que, por outro lado, os valores podem, sim, ser objeto de discussão, defendendo a possibilidade do debate ético em busca das melhores soluções. PUTNAM, Hilary. *O colapso da verdade e outros ensaios*. São Paulo: Ideias e letras, 2008.
- [12] O imperativo categórico está assim definido: “*age unicamente segundo uma máxima tal que ao mesmo tempo possas querer que ela se torne uma lei universal*.” (Apud WALKER, Ralph. *Kant: Kant e a lei moral*. São Paulo: Editora Unesp, 1999, p. 31).
- [13] FOOT, Philippa. The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect. *Oxford Review*, nº.5, 1967.
- [14] EDMONDS, David. *Would you kill the Fat Man?: the Trolley Problem and What Your Answer Tells Us about Right and Wrong*. Princeton: Princeton University Press, 2014, p. 35.
- [15] Também nesse sentido crítico, Cf. HÖFFE, Otfried. *Justiça política*. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 58-60.
- [16] AUSTIN, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 157. (tradução nossa)
- [17] HART, H.L.A. Positivism and the Separation of Law and Morals. *Harvard Law Review*, vol. 71, 1958, p. 593-629.
- [18] GREEN, L. Legal positivism. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/> Acesso em 03/03/2014. (tradução nossa)
- [19] *Op. cit.*, 2009, p. 44-45.
- [20] Seria o que Dimitri Dimoulis entende por “moralismo da interpretação”, distinto do “moralismo da validade.” Cf. DIMOULIS, Dimitri. *Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-político*. São Paulo: Método, 2006, p. 91.
- [21] HART, H.L.A. *Op. cit.*, 2012, p. 239.
- [22] *Ibid.*, 2012, p. 250.
- [23] Apud MORRISON, Wayne. *Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo*. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 75.
- [24] Kelsen, Hans. *Op. cit.*, 1997, p. 54.
- [25] A visão do Estado proposta pelo marxismo é considerada reducionista por muitos autores. Para Engels, no seu famoso *A origem da família, da propriedade privada e do Estado*, o Estado desapareceria com a superação do capitalismo. Não deixa de ser uma consideração

utópica imaginar que, mesmo sob condições materiais favoráveis e igualitárias, os conflitos entre os homens possam desaparecer a ponto de prescindir-se do Estado. Autores marxistas mais modernos, como Nicos Poulantzas, baseados inclusive numa obra de Marx (*O 18 brumário de Luís Bonaparte*), passam a sustentar que o Estado não está simplesmente a serviço da classe dominante, mas pode gozar de uma “autonomia relativa” entre as classes; o Estado seria então o “palco da luta de classes”.

[26] FINNIS, John. *O direito natural em Tomás de Aquino: sua reinserção no contexto do juspositivismo analítico*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2007, p. 110-111.

[27] É sempre importante, na Filosofia do Direito, distinguir entre uma abordagem descritiva do direito, do que o direito *é* – como tende a ser em geral o positivismo jurídico – e uma perspectiva normativa, que pretende dizer como o direito *deve ser*.

[28] MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 132.

[29] LYCURGO, Tassos; ERICKSEN, Lauro. *Filosofia do direito para concursos da magistratura*. São Paulo: Edipro, 2011, p. 65.

[30] HART, H.L.A. *Direito, liberdade, moralidade*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1987.

[31] Ver também o meu: Limites do direito diante da autonomia moral do indivíduo: os riscos do *máximo ético*. *Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região*, ano XXIV, n. 116, São Paulo, jan./mar. 2013, pp. 69-82.

[32] COMTE-SPONVILLE, André. *Petit traité des grandes vertus*. Paris: Presses Universitaires de France, 1995, p. 91. Para a edição brasileira: *Pequeno tratado das grandes virtudes*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

[33] *Ibid.*, p. 92.

[34] Tradução livre desse brocardo seria “se a lei é aplicada de forma muito rigorosa, comete-se grande injustiça.”

[35] *Éthique à Nicomaque*. Paris : Le livre de poche, 1992, p. 196. Para uma edição brasileira: *Ética a Nicômaco*. São Paulo: Edipro, 2014.

[36] *Ibid.*, p. 199.

[37] *Ibid.*, p. 215.

[38] PERELMAN, Chaïm. *Op. cit.*, p. 103.

[39] *Op. cit.*, 2012, p. 211.

[40] KELSEN, Hans. *A justiça e o direito natural*. Coimbra: Almedina, 2001, p. 101.

[41] Distinto a esse respeito é o pensamento de Hart que, mesmo em termos da justiça compensatória ou comutativa, destaca que o conceito não prescinde na sua aplicação de concepções morais acerca da igualdade. HART. *Op. cit.*, 2012, p. 214.

[42] HÖFFE, Otfried. *Op. cit.*, p. 28-29.

[43] A possibilidade de uma definição universal da justiça, ainda que em bases procedimentais, é objeto da polêmica entre liberais, como Rawls, e comunitaristas como Michael Sandel, Charles Taylor, Michael Walzer e Alasdair McIntyre. Rawls propõe uma distinção entre *justiça* e *bem*; estabelecidos os princípios universais de uma sociedade justa, a questão do bem ou da *vida boa* seria deixada à deliberação individual. Os comunitaristas entendem que a justiça não poderia ser definida de forma universal e abstrata, sem referência à noção de bem ou bem comum existente numa determinada comunidade, a um determinado *horizonte de valores*. (Cf. WERLE, Denilson Luis. O liberalismo contemporâneo e seus críticos. In: RAMOS, Flamarion Caldeira; MELO, Rúrion; FRATESCHI, Yara. *Manual de filosofia política*. São Paulo: Saraiva, p. 259-284)

[44] *Op. cit.*, 2012, p. 268.

[45] FINNIS, John. *Op. cit.*, p. 110.

[46] ALEXY, Robert. *Op. cit.*, 2009, p. 35.

[47] O debate travado por Hart e Fuller a respeito desse caso leva em conta que o tribunal havia declarado inválida a lei nazista de 1934. Mas há notícia de que o fundamento real da condenação não foi esse; o tribunal considerou que a lei não feria o direito natural, mas que a acusada não tinha o dever de informar à autoridade pública, tendo-o feito por razões puramente pessoais e deveria ter percebido que fazê-lo, nas circunstâncias, era “*contrário à sua consciência e ao senso comum de justiça de todos os seres humanos decentes*.” (Cf. HART, H.L.A. *Op. cit.*, 2012, p. 388).

[48] Exemplo mais recente dessa problemática foi o julgamento de Oskar Gröning, contador do campo de concentração de Birkenau, condenado em 2015 por um tribunal alemão a uma pena de 4 anos de prisão por cumplicidade nos assassinatos; ele já contava com mais de 90 anos e morreu em 2018 antes de cumprir a pena, após ter todos os seus recursos rejeitados.

[49] HART, H.L.A. *Op. cit.*, 2012, p. 273. Esse raciocínio, que Alexy chama de “argumento da clareza”, utilizado contra a fórmula de Radbruch, é endossado por autores positivistas modernos. Nesse sentido: SQUELLA, Agustín. *Positivismo jurídico, democracia y derechos humanos*. México: Distribuciones Fontanamara, 1998, p. 49.

[50] ALEXY, Robert. *Op. cit.*, 2009, p. 48-75.

[51] HART, H.L.A. *Op. cit.*, p. 217.

[52] SALDANHA, Nelson. *Filosofia do direito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 155. A *egologia* ou *teoria egológica do Direito* a que se refere Saldanha foi desenvolvida pelo jurista argentino Carlos Cossio.

[53] Maximiliano enumera diversas normas legais que deixam larga margem de apreciação ao juiz, demonstrando o quanto de justiça ainda remanesce na órbita do aplicador: “quando se referem a boa ou má fé; equidade; força maior; moral; bons costumes; ingratidão; imprudência ou imperícia; objeto ilícito, ou impossível; fim ilícito, ou imoral; injúria grave; dolo, no civil e no crime; bem como ao usarem das expressões – quando *exequível*; *sempre que for possível*; ou mandarem graduar a pena conforme as circunstâncias agravantes e atenuantes; e falarem de haver, sobre a pessoa do cônjuge, caído em erro que, descoberto, *torne insuportável a vida em comum*; *justo motivo* para não admitir que outrem pague a sua dívida; indenizar, além do que o credor perdeu, o que *razoavelmente* deixou de lucrar; tratar o imóvel alheio *como se fosse seu*; empregar, no exercício do mandato, a diligência *habitual*; provar que guardava com o *cuidado preciso* o animal danificador; restituir, na falta da própria coisa, o equivalente estimado pelo seu preço ordinário e *pelo de afeição*; e assim por diante.” (MAXIMILIANO, Carlos. *Op. cit.*, p. 52)

[54] GRAU, Eros Roberto. *Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do direito e os princípios*. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 133-136.

[55] ATIAS, Christian. *Philosophie du droit*. Paris: PUF, 1999, p. 49.

[56] Tratei da questão de forma mais aprofundada no meu *Neoconstitucionalismo e verdade: limites democráticos da jurisdição constitucional*. 3ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

[57] DIMOULIS, Dimitri. *Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-político*. São Paulo: Método, 2006, p. 85; também SABADELL, Ana Lucia. *Manual de Sociologia Jurídica: introdução a uma leitura externa do direito*. 2ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 20.

[58] A injustiça do nazismo levou o dramaturgo francês Jean Anouilh a escrever e fazer representar, sob a ocupação alemã da França, uma nova versão de *Antígona*, que passava a encarnar os valores da Resistência.

[59] Cf. MATOS, Andyttias Soares de Moura Costa. Positivismo jurídico e autoritarismo político: a falácia da *reductio ad Hitlerum*. In: DIMOULIS, Dimitri; DUARTE, Écio Oto (Coord.). *Teoria do direito neoconstitucional: superação ou reconstrução do positivismo jurídico?* São Paulo: Editora Método, 2008, p. 103-127.

[60] *Apud*. MORRISON, Wayne. *Op. cit.*, p. 42.

[61] *Ibid.*, p. 48.

[62] Aristóteles. *Op. cit.*, p. 216. (tradução nossa)

[63] MORRISON, Wayne. *Op. cit.*, p. 63-64.

[64] *Ibid.*, p. 73.

[65] *Ibid.* p. 83.

[66] FINNIS, John. *Op. cit.*, p. 94-98. John Finnis, católico, tem adotado posições consideradas conservadoras em temas como homossexualidade, aborto, imigração, etc. Ver: <<https://www.theguardian.com/law/2017/feb/03/neil-gorsuch-mentor-john-finnis-compared-gay-sex-to-bestiality>>. Acesso em 26/07/2020.

[67] ALEXY, Robert. *Op. cit.*, 2009, p. 44-45.

[68] *Ibid.*, p. 83, 97.

[69] *Ibid.*, p. 97.

[70] ALEXY, Robert. The Special Case Thesis and the Dual Nature of Law, *Ratio Juris* 31 (2018/3), p. 254–259.

[71] HART, H.L.A. *Op. cit.*, 2012, p. 250.

[72] Montaigne, em um de seus ensaios, lembra a resposta de Eumenes que, sitiado por Antígono, que seria maior e mais forte do que ele e o pressionava a sair para falar-lhe, respondeu: “Jamais considerarei um homem maior do que eu enquanto tiver minha espada em meu poder.” (*Ensaaios: que filosofar é aprender a morrer e outros ensaios*. Porto Alegre: LP&M, 2017, p. 54). Hart faz interessante correlação dessa ideia com o Direito Internacional: “*Essa desigualdade entre as unidades do direito internacional é, como veremos a seguir, umas das coisas que lhe conferiram uma natureza tão distante do direito nacional e limitaram o âmbito no qual ele pode operar como um sistema coercitivo organizado.*” (*Op. cit.*, 2012, p. 253)

[73] FINNIS, John. *Op. cit.*, 94-95.

[74] *Ibid.*, p. 99.

[75] *Apud* ALEXY, Robert. *Op. cit.*, 2009, p. 34.

[76] *Apud* ALEXY, Robert. *Op. cit.*, p. 7.

[77] HART, H.L.A. *Op. cit.*, 2012, p. 271-273.

[78] ALEXY, Robert. *Op. cit.*, p. 49.

[79] *Ibid.*, p. 48-80.

[80] MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. Kelsen contra o Estado. In: MATOS, Andityas Soares de Moura Costa; SANTOS NETO, Arnaldo Bastos (Coord). *Contra o absoluto: perspectivas críticas, políticas e filosóficas da obra de Hans Kelsen*. Curitiba: Juruá, 2011, p. 75-118.

[81] Em sentido diverso, porém, da associação kelseniana do jusnaturalismo com a metafísica platônica, a doutrina do direito natural na sua forma moderna, bem como o contratualismo, fortalecem-se justamente no momento de ruptura com o pensamento medieval e católico e reivindicam um caráter científico e muitas vezes antirreligioso, buscando fornecer à modernidade uma nova legitimação do poder político e do direito.

[82] ZAGREBELSKY, Gustavo. *El derecho dúctil: ley, derechos, justicia*. 10ª edição. Madri: Editorial Trotta, 2011, p. 119. (tradução nossa)

[83] Alexy assevera que “o não-positivismo pressupõe uma ética não relativista minimamente rudimentar.” Cf. ALEXY, Robert. *Op. cit.*, 2009, p. 49.

[84] *Apud* SQUELLA, Agustín. *Op. cit.*, p. 14.

[85] GREEN, L. Legal positivism. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/> Acesso em 03/03/2014. (tradução nossa)

[86] *Op. cit.*, p. 157. (tradução nossa)

[87] *Apud* MARMOR, Andrei. Legal positivism: still descriptive and morally neutral. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=763844### . Acesso em 04/03/2014.

[88] BOBBIO, Norberto. *O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito*. São Paulo: Ícone Editora, 2006.

[89] As revoluções liberais, também chamadas de “burguesas”, são aquelas que deram origem aos regimes liberais e democráticos modernos, substituindo as monarquias absolutas em alguns países e, em outros, conciliando os regimes monárquicos com a representação parlamentar e o respeito aos direitos individuais. Podemos considerar como as principais dentre elas a revolução inglesa do século XVII (1689), a revolução francesa de 1789 e também a independência americana de 1776. Os processos revolucionários prosseguiram no século XIX, ganhando contudo outros contornos e preocupações.

[90] BOBBIO, Norberto. *Op. cit.*, p. 54.

[91] “*Il ne serait pas exagéré de dire que la Révolution française marque l'avènement et le triomphe de la loi.*” (“Não seria exagero dizer que a Revolução francesa marca o advento e o triunfo da lei.”) (ATIAS, Christian. *Op. cit.*, p. 170)

[92] FERRAJOLI, Luigi. O Estado de Direito entre o passado e o futuro. In: COSTA, Pietro e ZOLO, Danilo (orgs). *O Estado de Direito: história, teoria, crítica*. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 417-464.

[93] Agustín Squella ressalta o “paradoxo” de que os direitos naturais, superiores ao direito positivo na concepção dos jusnaturalistas, tiveram que ser positivados como forma de garantir a sua observância. *Op. cit.*, p. 102.

[94] Segundo este autor, a expressão *positivus* referida ao direito primeiramente ocorre numa passagem do *Commento de Calcidio* ao *Timeu* de Platão. (BOBBIO, Norberto. *Op. cit.*, p. 16)

[95] GREEN, L. Legal positivism. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/> Acesso em 03/03/2014.

[96] BOBBIO, Norberto. *Op. cit.*, p. 131-134.

[97] *Apud* MARMOR, Andrei. Legal positivism: still descriptive and morally neutral. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=763844### ,p. 19-20. Acesso em 04/03/2014.

[98] DWORKIN, Ronald. *O império do direito*. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 10-15.

[99] GREEN, L. Legal positivism. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/> Acesso em 03/03/2014.

[100] Portanto, diferentemente do que às vezes se fala, a Constituição *não é* a norma fundamental para Kelsen, apesar de ocupar o ápice do sistema jurídico positivo. A norma fundamental para este autor não seria uma norma do ordenamento positivo, mas norma pressuposta, lógico-transcendental, acima de todas as normas positivas, inclusive da Constituição. Seu conteúdo seria algo do tipo: “*deve-se obedecer à Constituição*” ou ao poder constituinte. É uma “norma de fechamento”, necessária ao pressuposto kelseniano de que só uma norma pode conferir validade a outra. Ver o meu *Pílulas de Filosofia do Direito: 30 doses essenciais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

- [101] Alexy parece acreditar que há boas razões para **não** se conceber a norma fundamental dessa maneira abstrata e, nesse caso, segundo ele, só restaria fundamentar a norma fundamental por meio de um conceito de validade sociológico ou ético. (ALEXY, 2015, p. 61, nota de rodapé de nº 32).
- [102] Segundo Posner, Hart afasta-se da tradição da *common law* – em que os precedentes judiciais são fonte relevante do direito – e chegaria a evitar menção a essa realidade, pois incompatível com sua regra de reconhecimento (*rule of recognition*), próxima da norma fundamental kelseniana e mais apropriada ao direito continental. POSNER, Richard. *A problemática da teoria moral e jurídica*. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- [103] GREEN, L. Legal positivism. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/> Acesso em 03/03/2014.
- [104] NINO, Carlos Santiago. *La validez del derecho*. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2012, p. 63.
- [105] *Op. cit.*, 2012, p. 271-273.
- [106] KELSEN, Hans. *O que é justiça? A Justiça, o Direito e a Política no espelho da ciência*. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 145. No mesmo sentido, HART, H.L.A. Positivism and the Separation of Law and Morals. *Harvard Law Review*, vol. 71, 1958, p. 593-629.
- [107] HART, H.L.A. Positivism and the Separation of Law and Morals. *Harvard Law Review*, vol. 71, 1958, p. 593-629.
- [108] HART, H.L.A. *Op. cit.*, 2012, *Pós-escrito*.
- [109] *Apud* ALEXY, Robert. *Op. cit.*, 2009, p. 65.
- [110] HART, H.L.A. *O conceito de direito*. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- [111] HART, H.L.A. *Op. cit.*, 2012, p. 341. (*Pós-escrito*)
- [112] GREEN, L. *Op. cit.*
- [113] RAZ, Joseph. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford : Clarendon Press, 1979.
- [114] CHEROT, Jean-Yves. Le débat sur le juspositivisme entre Raz et Alexy. *Droit & Philosophie* 9 (2018/2), p. 21-44 (tradução nossa).
- [115] WALDRON, Jeremy. *Law and Disagreement*. Oxford: Oxford University Press, 1999. Leitor Kindle, pp. 166/167.
- [116] KELSEN, Hans. *A justiça e o direito natural*. Coimbra: Almedina, 2001, p. 100.
- [117] *Apud* ALEXY, Robert. *Op. cit.*, 2009, p. 65. Também Alexy considera que a necessidade do sistema jurídico advém das limitações do discurso prático geral ou moral, do qual considera o direito uma espécie. *Apud* ATIENZA, Manuel. *As razões do direito: teorias da argumentação jurídica*. São Paulo: Landy Editora, 2006, p. 171. A relação entre o desacordo moral e a necessidade da regra de direito positivo é enfatizada igualmente por J. Waldron. Cf: WALDRON, Jeremy. *A dignidade da legislação*. São Paulo: Martins Fontes, 2003, pp. 43-44.
- [118] Positivism and the Separation of Law and Morals. *Harvard Law Review*, vol. 71, 1958, p. 593-629. No mesmo sentido de Hart, cf. DIMOULIS, Dimitri. *Op. cit.*, p. 191/192.
- [119] GREEN, L. Legal positivism. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/> Acesso em 03/03/2014.
- [120] NINO, Carlos Santiago. *Op. cit.*, 175-177
- [121] ALEXY, Robert. *Op. cit.*, 2015, p. 36.
- [122] MARMOR, Andrei. Legal positivism: still descriptive and morally neutral. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=763844### .Acesso em 04/03/2014.
- [123] *Ibid.*
- [124] BOBBIO, Norberto. *Op. cit.*, p. 224.
- [125] Kelsen quis afastar-se da sociologia jurídica, que estudava o “ser” do direito, afirmando que o direito é um “dever ser” e assim deveria ser estudado, distinguindo a simples eficácia social da validade jurídica; ao mesmo tempo, por sua pretensão científica, pretendeu estudar esse “dever ser” de forma objetiva, buscando estabelecer algo como “o ser do dever ser.” O ponto a que chegamos é o de questionar se algo como um “dever ser” pode ser estudado como “ser”, de forma objetiva, ou se permaneceria de alguma forma dependente das avaliações próprias do campo do dever ser.
- [126] GREEN, L. Legal positivism. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/> Acesso em 03/03/2014.
- [127] *Apud* MARMOR, Andrei. Legal positivism: still descriptive and morally neutral. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=763844### .Acesso em 04/03/2014.

[128] Troper, Michel. *A filosofia do direito*. São Paulo: Martins Fontes (coleção Tópicos Martins), 2008, p. 117.

[129] *Ibid.*, p. 125.

[130] *Ibid.*, 139-140.

[131] POSNER, Richard. *A problemática da teoria moral e jurídica*. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 382.

[132] Posner entendia que a Corte não deveria autorizá-lo, pois ofenderia os valores da maioria dos americanos. *Op. cit.*, 393-399. Em 2015, contudo, sobreveio a decisão *Obergefell v. Hodges* pela Suprema Corte, autorizando o casamento igualitário.

[133] In: CELLA, José Renato Graziero. Realismo jurídico norte-americano e ceticismo. Disponível em http://www.cella.com.br/conteudo/conteudo_28.pdf. Acesso em 27/04/2013.

[134] POSNER, Richard. *Op. cit.*, 11-24.

[135] *Ibid.*, p. 179.

[136] Para todas as questões tratadas neste capítulo, remeto o leitor ao meu *Neoconstitucionalismo e verdade: limites democráticos da jurisdição constitucional*. 3ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

[137] SANCHÍS, Luis Prieto. *Justicia constitucional y derechos fundamentales*. 2ª edição. Madri: Editorial Trotta, 2009, p. 101; 116-117. (tradução nossa)

[138] GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Ser o no ser normativo: um dilema para el positivismo jurídico. In: DIMOULIS, Dimitri ; DUARTE, Écio Oto (Coord.). *Teoria do direito neoconstitucional: superação ou reconstrução do positivismo jurídico?* São Paulo: Editora Método, 2008, p. 79-101.

[139] DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 285.

[140] BARROSO, Luís Roberto. *Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo*. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 248.

[141] ZAGREBELSKY, Gustavo. *El derecho dúctil: ley, derechos, justicia*. 10ª edição. Madri: Editorial Trotta, 2011, p. 68.

[142] FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. In: FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (orgs). *Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 13. O autor italiano defende uma concepção de constitucionalismo estritamente “juspostivista”.

[143] *Op. cit.*, 1999, p. 271-275.

[144] *Op. cit.*, 2007, p. 37. Esclareça-se que se traduziu *common law* como “direito costumeiro.” Contudo, como esclarece o tradutor, *common law* “refere-se ao conjunto de leis que deriva e se desenvolve a partir das decisões dos tribunais, em oposição às leis promulgadas através de processo legislativo.” (p. 37)

[145] *Ibid.*, Cap. 13. Os direitos podem ser controversos?, pp.429-446.

[146] FISH, Stanley. Working on the Chain Gang: Interpretation in the Law and in Literary Criticism. In: W. J. T. Mitchell (ed.). *The Politics of Interpretation*. University of Chicago Press: Chicago, 1983, pp. 271-286. Dworkin responde com uma crítica ao “ceticismo externo” em My reply to Stanley Fish (and Walter Benn Michaels): please don’t talk about objectivity anymore. In: W. J. T. Mitchell (ed.). *The Politics of Interpretation*. University of Chicago Press, Chicago, 1983, pp. 287-313

[147] ALEXY, Robert. *Op. cit.* 2015, p. 74.

[148] *Op. cit.*, 1999, p. 64.

[149] *Ibid.*, pp. 280-281.

[150] *Ibid.*, pp. 275-279.

[151] Apud MARMOR, Andrei. Legal positivism: still descriptive and morally neutral. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=763844##. Acesso em 04/03/2014.

[152] ALEXY, Robert. *Op. cit.*, 2009, p. 83.

[153] *Ibid.*, p. 84.

[154] GUEDES, Néviton. A importância de Dworkin para a teoria dos princípios. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2012-nov-05/constituicao-poder-ronald-dworkin-teoria-principios>>. Acesso em 25/07/2020.

[155] ALEXY, Robert. *Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da justificação jurídica*. São Paulo: Landy, 2001.

[156] ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2015.

[157] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 82424, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 19-03-2004.

[158] ALEXY, Robert. *Op. cit.*, 2015, p. 116-117.

[159] *Ibid.*, p. 594.

[160] *Ibid.*, p. 36.

[161] BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Juízo de ponderação na jurisdição constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 64.

[162] *Apud* BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Op. cit.*, p. 69.

[163] *Op. cit.*, 2015, p. 561.

[164] Não confundir o realismo moral, corrente da metaética, com o *realismo jurídico*, corrente da Filosofia do Direito que já estudamos. O realismo jurídico, ao contrário, *repele* o realismo moral e se aproxima do ceticismo e relativismo axiológico.

[165] MACKIE, J. L. *Ethics: Inventing Right and Wrong*. London: Penguin Books, 1990. Leitor Kindle, posição 126. Citamos Mackie, autor mais moderno, mas poderíamos lembrar também, como sustentando alguma forma de relativismo axiológico, além dos céticos da Antiguidade, Montaigne, David Hume, Max Weber, Carl Schmitt. Isaiah Berlin, apesar de considerar possível o conhecimento dos valores, chega a conclusões parecidas com o seu “pluralismo agônico”. Ver o meu *Neoconstitucionalismo e verdade: limites democráticos da jurisdição constitucional*. 3ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

[166] Esta tese perquire a partir de que momento, na gestação, o novo ser torna-se *senciente*. É uma posição gradualista, mais à vontade com o direito ao aborto precoce, defendida pelo filósofo Jeff McMahan, para quem “um aborto precoce não mata ninguém, apenas impede alguém de vir a existir.” (*Apud* BONELLA, Alcino Eduardo. A ética do aborto. *Revista Filosofia*, São Paulo, Ed. Escala, Ano VI, n. 65, p. 50)

[167] Rafael da Silva Pinto, no seu livro sobre a filosofia de Iris Murdoch, destaca a maneira como a visão moral afeta a realidade. Lembra a controvérsia acerca da circuncisão feminina, quando a pós-doutora pela Universidade de Chicago Fuambai Ahmadu submeteu-se à circuncisão genital como forma de se integrar à tradição de seus ancestrais. Afirma ainda que ela enriqueceu o debate, ao chamar a atenção do mundo para a perspectiva das mulheres da etnia Kono, em Serra Leoa, segundo a qual o clitóris representa o pênis, de maneira que sua excisão faz parte da feminilização da menina e é necessária a seu ingresso no mundo adulto. (PINTO, Rafael da Silva. *A filosofia de Iris Murdoch: peregrinação moral em busca do bem*. São Paulo: AnnaBlume, 2011, p. 33)

[168] Ver também o meu: Limites do direito diante da autonomia moral do indivíduo: os riscos do *máximo ético*. *Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região*, ano XXIV, n. 116, São Paulo, jan./mar. 2013, pp. 69-82.

[169] BOBBIO, Norberto. *Op. cit.*, p. 178.

[170] *Op. cit.*, p. 68.

[171] *Op. cit.*, p. 162.

[172] Ver nesse sentido o meu: Holismo constitucional x discricionariedade legislativa. In: GRANDINO RODAS, João; ATTÍE JUNIOR, Alfredo. (Orgs.). *30 anos da Constituição Federal: retrospectiva, avanços e desafios*. 1ªed. São Paulo: CEDES: Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, 2018, v. 1, p. 561-574.

[173] SAUSSURE, Ferdinand. *Curso de linguística geral*. São Paulo: Editora Cultrix, 1969.

[174] MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 19ª edição, p. 8.

[175] Kelsen, Hans. *Op. cit.*, 1997, p.388.

[176] HART, H.L.A. *Op. cit.*, 2012, p. 161-171.

[177] ALEXY, Robert. *Op. cit.*, 2009, p. 84.

[178] CHEROT, Jean-Yves. Le debat sur le juspositivisme entre Raz et Alexy. **Droit & Philosophie** 9 (2018/2), p. 21-44 (tradução nossa), Num sentido talvez semelhante, Ralph Poscher afirmou que a indeterminação do direito seria um “ponto cego” do positivismo jurídico (POSCHER, Ralph. Insights, Errors and Self-Misconceptions of the Theory of Principles. **Ratio Juris** 22 (2009/4), p. 225/254.

[179] MAXIMILIANO, Carlos. *Op. cit.*, p. 74. Fala-se que os conflitos entre o Poder Judiciário e o Legislativo teriam se acentuado somente após a Segunda Guerra, com o controle de constitucionalidade. Não é assim. Eles estavam colocados de forma muito clara desde as chamadas revoluções liberais. Nesse sentido, para os Estados Unidos, confira-se o Federalista 78, de Hamilton e a própria decisão *Marbury x Madison*. Para a França, Eros Roberto Grau dá conta de dois discursos muito reveladores de Robespierre durante a Revolução, a respeito da criação da *Cour de Cassation*. (GRAU, Eros Roberto. *Op. cit.* 49-52)

[180] A Lei Complementar 118/2005 estabeleceu, no seu art. 3º, disposição interpretativa relativa ao prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de repetição do tributo sujeito a lançamento por homologação. A jurisprudência, contudo, negou o seu caráter interpretativo, invocando inclusive o princípio da separação de poderes.

[181] MAXIMILIANO, Carlos. *Op. cit.*, p. 87-106; 111-139.

- [182] ATIENZA, Manuel. *Op. cit.* Cf. também TOMASZEWSKI, Adatao. A Lógica do Razoável – um ensaio sobre o pensamento de Recaséns Siches e a atuação do operador do direito. **Rev. de Ciênc. Jur. e Soc. Unipar**, n. 1, vol. 1: jul/dez. 1998, P. 121-139.
- [183] *Op. cit.*, 2001, pp. 236-239.
- [184] GRAU, Eros Roberto. *Op. cit.*, p. 30.
- [185] MAXIMILIANO, Carlos. *Op. cit.*, p. 32.
- [186] Apud TOMASZEWSKI, *op. cit.*
- [187] *Op. cit.*, p. 62-63.
- [188] *Op. cit.*, p. 109.
- [189] Apud TOMASZEWSKI. *Op. cit.*
- [190] ATIENZA, Manuel. *Op. cit.*, p. 159.
- [191] *Ibid.*, p. 129-130.
- [192] *Ibid.*, p. 180.
- [193] *Ibid.*, p. 119.
- [194] *Ibid.*, p. 138.
- [195] BOBBIO, Norberto. *Op. cit.*, p. 197.

About The Author

Paulo Gustavo Guedes Fontes

Doutor em Direito do Estado pela USP e Mestre em Direito Público pela Université de Toulouse. Pós-doutor pela Université de Lorraine.
Desembargador do Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Ex-Promotor de Justiça e ex-Procurador da República.

Praise For Author

Do autor há muito de bom a dizer, mas me limito ao reconhecimento de suas qualidades como intelectual, pessoa de verdadeira leitura e de cultura jurídica (mas não só), ponderado, lúcido, firme e íntegro em suas avaliações (consequências de seu amplo conhecimento), com formação acadêmica em respeitáveis instituições do Brasil e da França, e também de suas experiências profissionais (notadamente como Procurador da República, compondo o Ministério Público Federal, e agora como Desembargador no Tribunal Regional Federal da 3ª Região). Mais do que titulação e cargos, Paulo Gustavo Guedes Fontes têm os atributos e as experiências necessárias para a produção de conteúdo sobre Filosofia do Direito combinando profundidade acadêmica e sua utilização concreta, com linguagem didática e voltada para a realidade brasileira contemporânea.

- José Carlos Francisco, Professor de Direito Constitucional e Desembargador do TRF-3

Books By This Author

[Neoconstitucionalismo e Verdade: limites democráticos da jurisdição constitucional](#)

O neoconstitucionalismo acena com uma reaproximação entre o direito e a moral, que seria propiciada sobretudo pelo caráter aberto dos princípios constitucionais. Seus defensores, contudo, têm deixado de enfrentar um problema importante, próprio da relação entre o direito e a moral, que é o de saber se existem ou não verdades no campo moral. Os princípios constitucionais, com sua maior abstração e carga valorativa, seriam parâmetros suficientes para a decisão em temas morais de grande indagação, como o aborto e a eutanásia? Dialogando com autores clássicos e contemporâneos, como David Hume, Ronald Dworkin e Jeremy Waldron, o autor enfrenta a questão e adota a perspectiva de um relativismo moral moderado para criticar alguns postulados do neoconstitucionalismo e da jurisdição constitucional moderna.

Books By This Author

[Pílulas de Filosofia do Direito: 30 doses essenciais](#)

Paulo Gustavo Guedes Fontes é um estudioso atento do Direito e conseguiu o milagre de transformar conceitos filosóficos profundos em algo simples, de fácil entendimento, de fácil alcance... Esta é uma obra de leitura extremamente agradável, que se consome numa só assentada, mas transforma a mente do leitor numa usina de novos pensamentos e riqueza intelectual.

Ricardo César Mandarinó Barretto, Juiz Federal emérito

Table of Contents

- [Title Page](#)
- [Title Page](#)
- [Copyright](#)
- [Dedication](#)
- [Dedication](#)
- [NOTA DO AUTOR À 2ª EDIÇÃO](#)
- [PREFÁCIO](#)
- [Direito, Moral e Justiça](#)
- [1. O conceito de direito](#)
- [1.1. O direito como meio de controle social](#)
- [1.2. O caráter coercitivo do direito](#)
- [1.3. As correntes jusfilosóficas e os critérios de identificação e validade do direito](#)
- [1.4. O elemento moral](#)
- [2. Direito e moral](#)
- [2.1. Conceito de moral](#)
- [2.2. Fundamentos da moral](#)
- [2.3. Correntes da filosofia moral](#)
- [2.4. Relações entre o direito e a moral](#)
- [2.4.1. A questão da conexão conceitual](#)
- [2.4.2. Conexão histórica ou contingencial](#)
- [2.5. Distinções entre o direito e a moral](#)
- [2.6. Teorias dos círculos](#)
- [2.7. Direito, moral e liberdade individual](#)
- [3. Direito e Justiça](#)
- [3.1. Conceito de justiça \(sentido lato, estrito, divergências sobre o conteúdo do conceito\)](#)
- [3.2. A justiça e sua relação com o direito](#)
- [3.3. Justiça e aplicação do direito](#)
- [3.4. A equidade](#)
- [Correntes da Filosofia do Direito](#)
- [1. O jusnaturalismo](#)
- [1.1. Definição. Características gerais](#)
- [1.2. Principais autores](#)
- [1.3. Tese da conexão ou vinculação entre direito e moral](#)
- [1.4. A questão das leis injustas e a fórmula de Radbruch](#)
- [1.5. Fundamentos epistemológicos](#)
- [2. O positivismo jurídico](#)
- [2.1. Definição. Características gerais](#)
- [2.2. Evolução histórica](#)

- [2.3. Principais autores](#)
- [2.4. Principais teses do positivismo jurídico](#)
- [2.4.1. A tese do fato social ou das fontes sociais do direito \(social thesis\)](#)
- [2.4.2. A tese da separação entre direito e moral \(separation thesis\)](#)
- [2.5. Outras questões relevantes](#)
- [2.5.1. A questão da norma fundamental](#)
- [2.5.2. O dever de obediência](#)
- [2.5.3. A questão dos princípios](#)
- [2.5.4. O argumento da democracia](#)
- [2.6. Positivismo inclusivo, exclusivo e normativo](#)
- [2.6.1. Positivismo inclusivo](#)
- [2.6.2. Positivismo exclusivo](#)
- [2.6.3. Positivismo ético ou normativo](#)
- [2.7. Fundamentos epistemológicos](#)
- [2.7.1. Postulados relativos ao conhecimento ético](#)
- [2.7.2. Postulados relativos ao conhecimento do próprio direito. A questão da “neutralidade científica”](#)
- [2.7.3. O enfoque descritivo do positivismo jurídico é possível? É suficiente?](#)
- [3. O realismo e o pragmatismo jurídicos](#)
- [3.1. Definição. Características gerais](#)
- [3.2. Realismo jurídico como descrição do direito](#)
- [3.3. Realismo como proposta normativa](#)
- [3.4. Fundamentos filosóficos e epistemológicos](#)
- [4. Neoconstitucionalismo – Dworkin – Alexy](#)
- [4.1. O neoconstitucionalismo](#)
- [4.2. Ronald Dworkin](#)
- [4.3. Robert Alexy](#)
- [4.4. Avaliação crítica do neoconstitucionalismo](#)
- [A Interpretação do Direito](#)
- [1. Interpretação e hermenêutica. Conceito e relação com a Filosofia do Direito](#)
- [1.1. Conceito](#)
- [1.2. A relação da interpretação com as correntes jusfilosóficas](#)
- [2. Classificação e métodos de interpretação](#)
- [2.1. Interpretação autêntica e doutrinal](#)
- [2.2. Métodos de interpretação](#)
- [2.3. Classificação quanto ao alcance da interpretação](#)
- [3. A superação dos métodos de interpretação mediante puro raciocínio lógico-dedutivo](#)
- [3.1. O método de interpretação pela lógica do razoável](#)
- [3.2. Teorias modernas da argumentação jurídica](#)
- [4. Teoria do ordenamento jurídico. Integração do direito](#)
- [BIBLIOGRAFIA](#)
- [About The Author](#)
- [Praise For Author](#)

- [Books By This Author](#)
- [Books By This Author](#)

Table of Contents

[Title Page](#)

[Title Page](#)

[Copyright](#)

[Dedication](#)

[Dedication](#)

[NOTA DO AUTOR À 2ª EDIÇÃO](#)

[PREFÁCIO](#)

[Direito, Moral e Justiça](#)

[1. O conceito de direito](#)

[1.1. O direito como meio de controle social](#)

[1.2. O caráter coercitivo do direito](#)

[1.3. As correntes jusfilosóficas e os critérios de identificação e validade do direito](#)

[1.4. O elemento moral](#)

[2. Direito e moral](#)

[2.1. Conceito de moral](#)

[2.2. Fundamentos da moral](#)

[2.3. Correntes da filosofia moral](#)

[2.4. Relações entre o direito e a moral](#)

[2.4.1. A questão da conexão conceitual](#)

[2.4.2. Conexão histórica ou contingencial](#)

[2.5. Distinções entre o direito e a moral](#)

[2.6. Teorias dos círculos](#)

[2.7. Direito, moral e liberdade individual](#)

[3. Direito e Justiça](#)

[3.1. Conceito de justiça \(sentido lato, estrito, divergências sobre o conteúdo do conceito\)](#)

[3.2. A justiça e sua relação com o direito](#)

[3.3. Justiça e aplicação do direito](#)

[3.4. A equidade](#)

[Correntes da Filosofia do Direito](#)

[1. O jusnaturalismo](#)

[1.1. Definição. Características gerais](#)

[1.2. Principais autores](#)

[1.3. Tese da conexão ou vinculação entre direito e moral](#)

[1.4. A questão das leis injustas e a fórmula de Radbruch](#)

[1.5. Fundamentos epistemológicos](#)

[2. O positivismo jurídico](#)

[2.1. Definição. Características gerais](#)

[2.2. Evolução histórica](#)

[2.3. Principais autores](#)

[2.4. Principais teses do positivismo jurídico](#)

- [2.4.1. A tese do fato social ou das fontes sociais do direito \(social thesis\)](#)
- [2.4.2. A tese da separação entre direito e moral \(separation thesis\)](#)
- [2.5. Outras questões relevantes](#)
 - [2.5.1. A questão da norma fundamental](#)
 - [2.5.2. O dever de obediência](#)
 - [2.5.3. A questão dos princípios](#)
 - [2.5.4. O argumento da democracia](#)
- [2.6. Positivismo inclusivo, exclusivo e normativo](#)
 - [2.6.1. Positivismo inclusivo](#)
 - [2.6.2. Positivismo exclusivo](#)
 - [2.6.3. Positivismo ético ou normativo](#)
- [2.7. Fundamentos epistemológicos](#)
 - [2.7.1. Postulados relativos ao conhecimento ético](#)
 - [2.7.2. Postulados relativos ao conhecimento do próprio direito. A questão da “neutralidade científica](#)
 - [2.7.3. O enfoque descritivo do positivismo jurídico é possível? É suficiente?](#)
- [3. O realismo e o pragmatismo jurídicos](#)
 - [3.1. Definição. Características gerais](#)
 - [3.2. Realismo jurídico como descrição do direito](#)
 - [3.3. Realismo como proposta normativa](#)
 - [3.4. Fundamentos filosóficos e epistemológicos](#)
- [4. Neoconstitucionalismo – Dworkin – Alexy](#)
 - [4.1. O neoconstitucionalismo](#)
 - [4.2. Ronald Dworkin](#)
 - [4.3. Robert Alexy](#)
 - [4.4. Avaliação crítica do neoconstitucionalismo](#)

[A Interpretação do Direito](#)

- [1. Interpretação e hermenêutica. Conceito e relação com a Filosofia do Direito](#)
 - [1.1. Conceito](#)
 - [1.2. A relação da interpretação com as correntes jusfilosóficas](#)
- [2. Classificação e métodos de interpretação](#)
 - [2.1. Interpretação autêntica e doutrinal](#)
 - [2.2. Métodos de interpretação](#)
 - [2.3. Classificação quanto ao alcance da interpretação](#)
- [3. A superação dos métodos de interpretação mediante puro raciocínio lógico-dedutivo](#)
 - [3.1. O método de interpretação pela lógica do razoável](#)
 - [3.2. Teorias modernas da argumentação jurídica](#)
- [4. Teoria do ordenamento jurídico. Integração do direito](#)

[BIBLIOGRAFIA](#)

[About The Author](#)

[Praise For Author](#)

[Books By This Author](#)

[Books By This Author](#)

Índice

Title Page	1
Title Page	2
Copyright	3
Dedication	4
Dedication	5
NOTA DO AUTOR À 2ª EDIÇÃO	9
PREFÁCIO	10
Direito, Moral e Justiça	13
1. O conceito de direito	14
1.1. O direito como meio de controle social	15
1.2. O caráter coercitivo do direito	16
1.3. As correntes jusfilosóficas e os critérios de identificação e validade do direito	18
1.4. O elemento moral	21
2. Direito e moral	22
2.1. Conceito de moral	23
2.2. Fundamentos da moral	24
2.3. Correntes da filosofia moral	26
2.4. Relações entre o direito e a moral	28
2.4.1. A questão da conexão conceitual	29
2.4.2. Conexão histórica ou contingencial	31
2.5. Distinções entre o direito e a moral	33
2.6. Teorias dos círculos	34
2.7. Direito, moral e liberdade individual	36
3. Direito e Justiça	37
3.1. Conceito de justiça (sentido lato, estrito, divergências sobre o conteúdo do conceito)	38
3.2. A justiça e sua relação com o direito	42
3.3. Justiça e aplicação do direito	45
3.4. A equidade	47

Correntes da Filosofia do Direito	48
1. O jusnaturalismo	49
1.1. Definição. Características gerais	50
1.2. Principais autores	52
1.3. Tese da conexão ou vinculação entre direito e moral	55
1.4. A questão das leis injustas e a fórmula de Radbruch	57
1.5. Fundamentos epistemológicos	59
2. O positivismo jurídico	61
2.1. Definição. Características gerais	62
2.2. Evolução histórica	63
2.3. Principais autores	64
2.4. Principais teses do positivismo jurídico	66
2.4.1. A tese do fato social ou das fontes sociais do direito (social thesis)	67
2.4.2. A tese da separação entre direito e moral (separation thesis)	68
2.5. Outras questões relevantes	69
2.5.1. A questão da norma fundamental	70
2.5.2. O dever de obediência	72
2.5.3. A questão dos princípios	73
2.5.4. O argumento da democracia	74
2.6. Positivismo inclusivo, exclusivo e normativo	75
2.6.1. Positivismo inclusivo	76
2.6.2. Positivismo exclusivo	77
2.6.3. Positivismo ético ou normativo	78
2.7. Fundamentos epistemológicos	79
2.7.1. Postulados relativos ao conhecimento ético	80
2.7.2. Postulados relativos ao conhecimento do próprio direito. A questão da “neutralidade científica	81
2.7.3. O enfoque descritivo do positivismo jurídico é possível? É suficiente?	82
3. O realismo e o pragmatismo jurídicos	84
3.1. Definição. Características gerais	85

3.2. Realismo jurídico como descrição do direito	86
3.3. Realismo como proposta normativa	87
3.4. Fundamentos filosóficos e epistemológicos	88
4. Neoconstitucionalismo – Dworkin – Alexy	89
4.1. O neoconstitucionalismo	90
4.2. Ronald Dworkin	92
4.3. Robert Alexy	95
4.4. Avaliação crítica do neoconstitucionalismo	98
A Interpretação do Direito	101
1. Interpretação e hermenêutica. Conceito e relação com a Filosofia do Direito	102
1.1. Conceito	103
1.2. A relação da interpretação com as correntes jusfilosóficas	104
2. Classificação e métodos de interpretação	106
2.1. Interpretação autêntica e doutrinal	107
2.2. Métodos de interpretação	108
2.3. Classificação quanto ao alcance da interpretação	110
3. A superação dos métodos de interpretação mediante puro raciocínio lógico-dedutivo	111
3.1. O método de interpretação pela lógica do razoável	112
3.2. Teorias modernas da argumentação jurídica	114
4. Teoria do ordenamento jurídico. Integração do direito	116
BIBLIOGRAFIA	118
About The Author	131
Praise For Author	132
Books By This Author	133
Books By This Author	134